

商法

目录

绪论	3
第 1 章 商法的一般原理	5
第 1 节 商法概述	5
第 2 节 商法的渊源与体系	11
第 3 节 商事纠纷及其解决机制	14
第 2 章 商事主体	15
第 1 节 商事主体概述	15
第 2 节 商业名称	18
第 3 节 商事账簿与商事审计	21
第 4 节 商事登记制度	25
第 3 章 商事行为	28
第 1 节 商事行为概述	28
第 2 节 营业	32
第 3 节 连锁经营与特许经营	34
第 4 节 电子商务	35
第 5 节 商事运输	38
第 4 章 公司法	40
第 1 节 公司法概述	41
第 2 节 公司的资本制度	45
第 3 节 股份与股权	48
第 4 节 公司的组织机构	52
第 5 节 公司的合并与分立	56
第 6 节 公司的解散与清算	58
第 5 章 非公司企业法	60
第 1 节 个人独资企业法	60
第 2 节 合伙企业法	63
第 3 节 其他非公司企业法	68
第 6 章 商业银行法与支付法	70
第 1 节 商业银行法	71
第 2 节 商事支付法	76
第 3 节 票据法	80
第 7 章 保险法	87
第 1 节 保险法概述	87
第 2 节 保险法的基本原则	91
第 3 节 保险合同	95
第 4 节 保险业法	100
第 8 章 证券法	104
第 1 节 证券法的基本问题	104
第 2 节 证券市场主体法律制度	109
第 3 节 证券发行与承销法律制度	113
第 4 节 证券上市与交易法律制度	117

第 5 节 证券投资者保护法律制度	123
第 6 节 证券监督管理机构	125
第 7 节 证券违法行为法律责任	127
第 9 章 期货交易法	130
第 1 节 期货交易法概述	130
第 2 节 期货交易参与者	133
第 3 节 期货交易规则	136
第 4 节 期货市场的监管	138
第 10 章 商事信托与投资基金法	139
第 1 节 商事信托概述	139
第 2 节 商事信托的设立和生效	140
第 3 节 商事信托财产	143
第 4 节 信托当事人	144
第 5 节 信托的变更与终止	147
第 6 节 投资基金	149
第 11 章 破产法	153
第 1 节 破产法概述	153
第 2 节 破产财产的清理	157
第 3 节 破产重整制度	161
第 4 节 破产和解制度	164
第 5 节 破产清算制度	165

课程知识框架

章节	重要程度	章节	重要程度
绪论	★★	第 6 章 商业银行法与支付法	★★
第 1 章 商法的一般原理	★★	第 7 章 保险法	★★★
第 2 章 商事主体	★★★	第 8 章 证券法	★★★
第 3 章 商事行为	★★★	第 9 章 期货交易法	★★
第 4 章 公司法	★★★	第 10 章 商事信托与投资基金法	★★
第 5 章 非公司企业法	★★★	第 11 章 破产法	★★

课程重点

商法学课程有两部分内容：

- 1.第一部分：第 1 章——第 3 章。主要介绍商法学基础理论知识，包括商法的一般原理、商事主体和商事行为等内容。
- 3.第二部分：第 4 章——第 11 章。主要介绍具体的商事部门法内容，包括公司法、非公司企业法、商业银行与支付法、保险法、证券法、期货交易法、商事信托与投资基金法、破产法。

课程目标

- 1、能够形成较为完整的民商法学理论体系，理解和掌握商法学的基本理论，在准确理解商法与其他部门法关系的基础上把握商法理论的特殊性，构建完善的商法理论体系；
- 2、掌握各主要商事法律制度的基本概念和框架体系，进而从整体上掌握商法基本的知识结构体系；
- 3、形成正确的商法思维和伦理观念，把握商法的内在理念、运行规律；
- 4、具备基本的商法适用技能，即通过对于具体法律规则的内在原理与适用要件的解析，能够运用商法规范为一般性的商事活动和商事纠纷提供可行的解决方案

绪论

本章重难点分析

- 1.了解商法学的研究对象
- 2.了解商法学的功能与发展历史
- 3.认识马克思主义理论与中国特色社会主义商法学

一、商法学的研究对象

商法学是以商法的一般理论与制度及商事部门法理论与制度为研究对象的部门法理论与学科

商法学的研究首先应以商法基础理论为研究对象，回答商法实践中的一般理论问题

商法学还需要以商事部门法为研究对象，回答商法实践中具体的部门法理论问题二、商法学的功能

- 1.商法学有助于建构和发展中国特色社会主义商法
- 2.商法学有助于完善中国特色社会主义商事制度，维护社会主义市场经济秩序
- 3.商法学有助于推动当代中国法治文化观念的变革
- 4.商法学有助于树立社会商业道德，推动社会主义精神文明建设
- 5.商法学是我国实现国际经济战略的重要法治理论依托

三、商法学的历史发展

（一）西方商法学发展概述

1.大陆法系国家

商法学因各国民商分立或民商合一的不同立法模式也存在差异

民商合一的国家虽然存在实质意义上的商法，但商法学在法学教学体系里仍被整体归入民法教学中，没有获得独立的地位

民商分立的国家的商法学课程体系存在不同，但是在教学方法或者研究方式的教授上，大陆法系作为成文法国家，其商法教学更加注重法教义学，商法学学生多以成文法学习为重，以判例学习为辅

2.英美法系国家

英美法系国家没有对部门法进行详细划分，商法学仅被作为服务于课堂教学的教学方法商法学是一门以判例为基础的学科

（二）中国商法学发展概述

1.清末至民国时期

我国古代没有近现代意义上的商法。商法在我国始于清朝末期，清政府在推行新政时，把制定商法典作为振兴工商业的治国大策之一

辛亥革命后，新建立的民国政府在大清商事法律的基础上重新颁布了一批商事法律

国民政府采取了民商合一的立法体例，商法学被划入民法学的范畴而被并称为民商法学

2.中华人民共和国成立至 20 世纪 80 年代

1978 年经济法学兴起，商法学被纳入其中

3.20 世纪 80 年代末至 90 年代末

1993 年 11 月召开的党的十四届三中全会，该会议通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》明确指出我国要加快经济立法，进一步完善民商法

1997 年国家教委发布的《关于普通高等学校法学专业开设专业主干课程的通知》中，首次明确将“商法学”列为法学专业 14 门核心课程之一

四、马克思主义理论与中国特色社会主义商法学

中国特色社会主义商法学理论研究以马克思主义为指导，具体而言，包括如下五个方面

- 1.商法学需要在保持国际性的同时坚持其自身的国内性
- 2.商法学理论研究需要关注商事交易实践
- 3.商法学应当以商事活动的营利性为核心构建商法理论体系
- 4.马克思主义理论还为商法学认识商人阶层和商事行为的特殊性提供了理论指导
- 5.商法学的研究和学习应当注意商法与民法的内在联系与相互作用

五、学习商法学的方法

- 1.商法的学习需要注意商法的实践性
- 2.商法的学习需要综合运用各种研究方法
- 3.商法的学习需要培育商法思维
- 4.商法的学习还需要坚持基础理论和商事部门法相结合的方法

5.在学习商法的过程中，还需要关注经济学、社会学和历史学等社会学科方面的知识

第1章 商法的一般原理

本章重难点分析

- 1.了解商法学的研究对象
- 2.了解商法学的功能与发展历史
- 3.认识马克思主义理论与中国特色社会主义商法学

第1节 商法概述

一、商法的概念和调整对象

（一）商法的含义

商法，又称商事法，是指调整商事主体参加的商事关系之特别私法。商法和民法均为私法，都调整人身关系和财产关系。但相对于民法，商法有以下特点：

1.商法是商人法

是旨在规范商事主体地位、组织及营业的法律。商事主体，既包括公司企业、合伙企业和个人独资企业，也包括个体工商户、农村承包经营户和合作社等。传统商法是从商人习惯和交易惯例中产生出来的，现代商法则侧重于规范企业、企业经营者的法律地位、组织形态和营业行为等事项。

2.商法是私法

商法是规范平等主体之间人身关系和财产关系的法律。商法在调整商事主体之间的商事关系时，既要遵循民事主体地位平等、意思自治、公平、诚实信用等基本原则，又要秉承保障商事交易自由、平等交换、便捷安全等原则。

3.商法是特别私法

民法是普通法，商法是特别法。商法可再分为商事普通法和商事特别法。商事普通法，普遍适用于调整各种商事关系，通常是指商法典；商事特别法，适用于调整特殊的商事关系，既包括物权法和合同法等法律中的特别规定，又包括公司法、证券法、票据法、保险法、破产法等。

（二）商法的调整对象

商法的调整对象是商事关系。商事关系是一种特殊的民事关系，主要指商人与企业相互之间发生的，或者商人或企业与消费者之间发生的人身关系和财产关系，它在主体、客体和内容上，区别于一般民事关系。

1.商事关系的主体

商事主体是特殊的民事主体。民事主体若要取得商事主体资格，通常要先行办理商事登记。商事主体既可以与其他商事主体产生商事关系，也可以与其他民事主体产生商事关系。

2.商事关系的客体

即商事权利义务关系指向的对象。商事主体利用营业资产并从事经营活动，与其他民事主体之间形成特殊的权利义务关系，商事关系的客体既包括动产和不动产，又包括营业或者营业资产等，还包括其他权利或利益。

3.商事关系的内容

即商事权利义务关系。在双方或多方商事关系中，各方当事人按照意思自治等规则确定相互之间的权利义务关系。在单方商事关系中，商事主体既要遵循商法和民法原则，又要遵守消费者权益保护法的特别规定。

二、商法的基础概念

（一）商法的基础概念

传统商法的基础概念主要是商、商事、商人、商行为、营利事业和营业。

1.商和商事

在我国商法学上，“商”在限定法律关系的主体时，是指商人或企业等商事主体；在限定事业或行为时，是指营利事业或商行为。

“商事”是指商人从事的、以营利为目的的各种活动或事务。商事活动的主体是商人或企业，商事活动具有营利性。

在商法对商事活动有特别规定时，应当优先适用商法规定；商法没有规定的，适用商事习惯；商事习惯没有规定的，适用民法。

2.商人

在现代社会，商人组织形态多种多样，既包括采用无限责任组织形式的商业组织，以及采用有限责任组织形式的商业组织，也包括商自然人及其衍生而来的个体工商户和个人独资企业，甚至包括合伙企业和公司企业等组织形态。

商人已不限于以买卖为职业的人，而是泛指持续从事经营活动、具有专业技能的个人和组织。

3.商行为

商行为是指商人经营或从事营利事业的各种营利行为。

商行为是商人实施的行为。根据商事登记法律的规定，商人有义务办理商事登记；凡登记为商人者，当然具有商人资格，商人实施的行为应当推定为商行为。未办理商事登记而以

从事经营活动为职业的人，应当推定为商人。

商行为限于营利事业范围内的行为。商人是否将所得利益分配给投资者，不是商行为的认定标准。

商行为包括法律行为及其他行为。凡属于法律行为者，以意思表示为其构成要素，并产生当事人意定的法律效果；凡属于其他行为者，不以意思表示为其构成要素的，依法将产生法定效果。

4. 营利事业

营利的认定，有目的和手段两个分析角度。行为人以营利为目的而从事某种持续性的活动的，可认定为营利事业。

如果行为人的营利目的虽不明显，但采用了经营或营业的形式，应当推定为营利事业。

5. 营业

营业是指运营中的营利事业，既包括组织和经营活动，也包括财产关系。相应地，营业可分为主观营业和客观营业。

主观营业，指各种营利事业之经营活动，属于法律关系之内容的范畴。商人从事经营活动的法律效果，包括意定效果和法定效果。客观营业，指营业所依赖的财产或者资产，属于法律关系之客体的范畴，也可称为营业资产。

（二）商法基础概念的发展

1. 商法基础概念的意义

首先，商法基础概念可以整合具体的商法术语和范畴。

其次，商法基础概念有助于集中表达商法的独特性。最后，商法基础概念是促进民法发展的重要力量。

2. 商法基础概念的变化和生成

一方面，企业和经营者概念进入现代商法。另一方面，营业概念的地位提升。

三、商法的原则

（一）商法原则的含义和地位

商法原则是指由立法者规定的，反映商法的本质属性，贯彻于商事活动的始终，统领商法立法和司法活动的根本准则。我国商法学界所称的商法原则，主要是学说上的原则，而不是实定法上的原则。

商法调整商事主体之间的商事关系，遵循民法的基本原则，同时秉承保障商事交易自由、等价有偿、便捷安全等原则。

（二）经营自由原则

经营自由，又称经商自由、交易自由或营业自由，是指除依照法律规定或整体利益不得从事经营活动之外，行为人有权自主决定从事经营活动，即享有是否从事经营活动的自由和从事何种经营活动的自由。

经营自由的限制，包括法定限制和行业限制。法定限制，是指对权利人经营自由加以限制的法律规定，如公务员和未成年人不得从事营业等。行业限制也称整体利益限制，指权利人未事先取得某种特殊资格，即不得从事特定营业的限制。

（三）平等交换原则

平等交换，是指商事主体在从事营业或财产交易中，应当基于等价交换而确定商事主体之间的权利义务。

在商事关系中，“等价”的认定标准带有不确定性，是否“有偿”取决于商事主体的约定，但商事主体仍应当遵循“平等交换”的原则。任何人不得非法剥夺商事主体的财产和权利。

（四）企业维持原则

1.企业主体地位的维持

独资、合伙或公司企业，有权以自己名义起诉和应诉，直接承受诉讼胜败的后果。

2.资本充实规则

资本充实是指公司在存续期间，应当尽力保持与其营业相适应的实际资产，以降低公司经营风险，维持公司的偿付能力和长期存续。

3.盈利分配规则

4.企业重整规则

（五）交易便捷原则

交易便捷原则的核心是减少烦琐的交易手续、降低交易成本。

1.形式自由

商法重视效率价值，在法律行为形式要件上的要求较低。

2.权利外观

权利外观也称信赖保护。商法承认权利外观表象在权利认定上的优先效力，即在企业设立上遵循登记或注册主义，在权利认定上采用登记或注册等方式。

3.短期时效

在我国，处理商事纠纷应当适用《民法典》关于诉讼时效的一般规定。如果商人或企业

约定了较短的质量检验期限，应当按照意思自治原则予以认可。

（六）交易安全原则

1.公示主义

商人或企业对于涉及利害关系人利益的客观事实，必须依照法律和行政法规的规定，向公众进行公示，以便利害关系人知晓。

2.强制主义

强制主义又称干涉主义，指国家采用公法手段，对商事关系的某些内容做出强制性规定。

3.加重责任

在商法上，加重责任主要包括严格责任和连带责任，此外还涉及社会责任。

（七）守法经营原则

企业守法经营，指企业应当遵守商法有关经营的规定并履行其他特殊义务。

1.有关商事登记的义务

任何人从事商事活动，除非法律、行政法规另有规定，必须依法办理商事登记。

未经登记而从事商事活动的，属于无照经营，依法应予查处和取缔。登记事项的变更及企业注销等事项，应当办理商事登记。企业变更或注销未经登记的，工商登记机关有权依法予以处罚。

2.有关会计账簿的义务

会计账簿是真实反映企业经营状况的资料，涉及投资者和债权人的利益，也是国家对商事活动实施监督的基础。除法律或行政法规另有规定者外，企业必须依法建立会计制度和会计账簿。

3.有关经营活动的特殊义务

四、商法的产生、变迁与展望

（一）中国商法的产生和变迁

在夏商与西周时代，我国已出现了商人阶层以及小商人和合伙等商人形式。自春秋战国至明清时代，古代律法均有涉及商的内容。

及至清朝，古代商法进入转型期。在商人组织上，不仅延续了从前的小商人和合伙，还出现了行会、会馆和工商业公所及公司等商人形式。

中华人民共和国成立后，中央人民政府政务院于 1950 年制定《私营企业暂行条例》，集中规定了独资、合伙和公司的组织形式。

改革开放以来，我国陆续制定了大量商法规范，我国制定了《公司法》《合伙企业法》

《个人独资企业法》《证券法》《票据法》《破产法》《保险法》《海商法》等单行商事法律，《民法典》也包含了大量的商事规范。

（二）西方中世纪商法

在古希腊、古罗马时代已形成调整商人和商人活动的习惯法。在古罗马时代，《万民法》记载了很多商事习惯法的内容，对后世商法产生了深远影响。

中世纪商法泛指当时存在的各种贸易规则组成的体系。它是商人自治法和习惯法，旨在保护商人和工商业活动，带有裁判法属性，由商人行会或其组织的裁判机构做出裁断。

（三）西方近代商法

在 16 世纪，欧洲国家陆续开启了商法系统化和民法法典化的进程。法国、德国、西班牙、葡萄牙、匈牙利等采用了民商分立体系。瑞士及北欧诸国采用了民商合一体系。意大利则从民商分立转为民商合一。北美、非洲和亚洲地区的前殖民地国家受原宗主国的影响，采用了民商分立体系。

近代商法以民商分立为常态，以民商合一为例外。

讲解归纳与举例

【单选题】下列关于商法的理解，不正确的是

- A.商法调整的是商事关系
- B.商人与消费者之间发生的财产关系属于商法
- C.商事行为以营利为目的
- D.商行为仅包括买卖行为

【答案】D

【解析】买卖是最主要的商业形式，随着现代商业的发展，运输、仓储、信贷、代理等逐渐

从买卖中独立出来，成为新的商业形式。

【名词解释题】经营自由原则

【参考答案】经营自由，又称经商自由、交易自由或营业自由，是指除依照法律规定或整体利益不得从事经营活动之外，行为人有权自主决定从事经营活动，即享有是否从事经营活动的自由和从事何种经营活动的自由

【名词解释题】资本充实

【参考答案】是指公司在存续期间，应当尽力保持与其营业相适应的实际资产，以降低公司经营风险，维持公司的偿付能力和长期存续。

第2节 商法的渊源与体系

一、商法的渊源

（一）商法渊源的概念和分类

商法的渊源，即商法规范的存在或表现形式，具体而言，是指具有法的效力的商法规范借以表现的形式。我国商法主要采用成文法形式。

一般而言，商法渊源分为国内法渊源和国际法渊源。

（二）我国商法的正式渊源

正式渊源，是指国家立法机关依照法定立法程序制定的法律文件，也包括立法机关认可的有权机关依照法定程序制定的规范。

我国商法的正式渊源包括：

1.宪法

宪法是国家全面规范社会、经济、政治生活的根本大法，直接或间接规范了商事关系，是我国商法的正式渊源。

2.民商事法律

民商事法律是全国人民代表大会或其常委会依法制定的、规范民商事关系的规范性文件，是我国商法的主要渊源。

民商事法律可分为一般法和特别法。民商事一般法，主要包括《民法典》等；民商事特别法，主要包括《公司法》《票据法》《证券法》《保险法》《破产法》《海商法》《证券投资基金法》等。

3.行政法规

行政法规是国务院为了履行宪法赋予的管理职权和执行法律而依法制定的规范性文件。比如《公司登记管理条例》《企业法人登记管理条例》和《商业特许经营管理条例》等。

4.地方性法规

地方性法规是省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会，以及设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需要，在与宪法、法律、行政法规不相抵触的前提下依法制定的法律规范文件。

5.自治条例和单行条例

民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点，制定自治条例和单行条例。

6.国务院部门规章

根据《立法法》的规定，国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构，可以根据法律和国务院的行政法规、决定、命令，在本部门的权限范围内，制定规章。

7.地方政府规章

8.最高人民法院具体应用法律的解释（司法解释）

（三）我国商法的非正式渊源

非正式渊源，是指立法机关及其认定的有权机关以外的其他组织制定的、不违反法律规定并发生实质约束效力的规范。

从我国商法实践来看，非正式渊源主要包括：1.最高人民法院公告的案例；2.最高人民法院发布的指导性案例；3.交易习惯。

（四）我国商法的国际法渊源

我国商法的国际法渊源，主要分为国际商事条约、行政协定和国际商事惯例。

1.国际商事条约

国际商事条约是指以国家名义缔结、参加、承认的单边或者双边国际商事条约、协定和具有条约性质的文件。

2.行政协定

行政协定，是指两个或者两个以上的政府之间签订的有关政治、贸易、法律、文件等方面的协议。

（五）商法渊源的适用和效力

在我国，习惯和习惯法在商法渊源中的地位有待明确，通常遵循先适用商事特别法、后

适用民事普通法的原则。

二、商法的体系

（一）商法体系的概念

商法体系，是指商法不同部分经过分类组合而形成的、呈现体系化的有机联系的整体。在不同国家，商法体系有所不同。

（二）我国的商法体系

对于我国的商法体系，有实然和应然两个观察角度。

商法的实然体系，是指基于我国立法的现状，将有关商事法律分类组合而形成的体系化商法。通常认为，我国采用民商合一体系。

商法的应然体系，是商法学术界基于某种商法学说而构建的体系化商法。我国未来的商法体系应当主要包括以下内容：1.商法典或商法通则；2.商主体制度；3.商行为制度；4.特别商法。

三、商法与其他法律部门的关系

（一）商法与民法

商法与民法均为私法，学术界通常合称为“民商法”。一般认为，民法是私法的普通法，商法是私法的特别法，商法规范是民法规范的例外和补充。

（二）商法与经济法

通常认为，经济法是调整经济管理关系、维护公平竞争关系、组织管理性的流转和协作关系的法律部门。经济法调整的社会关系，具有主体上的特定性、内容上的经济性和专业性、法益上的复合性、手段上的综合性、过程上的行政主导性和政策性等特征，因而有别于商法。

讲解归纳与举例

【多选题】我国商法的正式渊源包括

- A.宪法
- B.法律
- C.行政法规
- D.规章
- E.司法解释

【答案】ABCDE

【解析】我国商法的正式渊源包括：（1）宪法；（2）民商事法律；（3）行政法规；（4）地方性法规；（5）自治条例和单行条例；（6）国务院部门规章；（7）地方政府规章；（8）司法解

释。

第3节 商事纠纷及其解决机制

一、商事纠纷解决的基本模式

商事纠纷，是指因商事组织之设立或其他商事交易而发生的纷争。

在现代社会，商事纠纷的解决大体有两种模式：一为法院模式，即通过国家法院解决商事纠纷。二为法院外模式，即在法院以外，以调解、仲裁等各种替代方式解决商事纠纷。

二、调解与仲裁解决商事纠纷的程序特征

调解与仲裁，是法院外解决商事纠纷最为重要和常见的两种形式。

（一）商事调解的程序特征

广义而言，调解包括法院内调解和法院外调解。狭义而言，调解仅指法院外的调解。在我国，调解也可以区分为法院内的调解、人民调解员的调解以及其他形式的调解。

法院外的商事调解作为一种商事纠纷的解决程序，具有如下特征：

第一，调解程序的自愿性。

第二，调解员的中立性。

第三，调解程序的保密性。

第四，调解协议的“软司法拘束力”。调解协议如欲取得强制执行力，仍需经过法院确认。

（二）商事仲裁的程序特征

商事仲裁是指基于契约性或非契约性商事关系引起争议的当事人，根据其在争议发生前或争议发生后所达成的协议，自愿将争议提交中立的第三者进行裁判的争议解决程序。

商事仲裁具有如下特征：

第一，仲裁程序的自愿性。

第二，仲裁员的专业性。

第三，仲裁程序的便捷性。

第四，仲裁程序的保密性。

第五，仲裁裁决的强司法效力性。具有稳定的法律拘束力，不能随意被法院撤销，具有强制执行力。

三、商事法院（法庭）与商事审判

（一）商事法院的含义

商事法院是指专门负责裁判涉及商人或商事活动纠纷的法院。我国目前并无专门的商事

法院，由普通法院内设的民事庭（或者商事庭，以前称经济庭）处理商事纠纷。

（二）商事审判程序的特征

第一，商事法院推行“参与裁判制”，审判组织的组成具有极强的民间性。

第二，商事法院实行宽容的审理程序。

（三）商事审判的理念

1.维持团体交易关系的理念

2.增进交易效率的理念

3.增进交易安全的理念

四、商事法律责任

商事法律责任具有如下特征：

第一，商事交易以自由为原则，多以契约方式展开。

第二，法定责任的严格性。

第三，追责时效的特殊性。

讲解归纳与举例

【多选题】商事仲裁的特征包括

A.仲裁程序的自愿性

B.仲裁员的专业性

C.仲裁程序的便捷性

D.仲裁程序的保密性

E.仲裁裁决的强司法效力性

【答案】ABCDE

【解析】商事仲裁具有如下特征：仲裁程序的自愿性；仲裁员的专业性；仲裁程序的便捷性；仲裁程序的保密性；仲裁裁决的强司法效力性。

第2章 商事主体

本章重难点分析

1.了解商事主体的概念、特征与种类。

2.了解商业名称的构成、选定及其保护问题。

3.认识商业账簿的种类，了解商事审计。

4.了解并理解商事登记的种类、程序和效力。

第1节 商事主体概述

一、商事主体的概念与特征

商事主体，又称商事法律关系主体、商主体，是指依照商法的规定具有商事权利能力和商事行为能力，能够以自己的名义独立从事商事行为，在商事法律关系中享有权利和承担义务的个人和组织。

商事主体具有以下基本法律特征：

1.商事主体由商法法定

2.商事主体依法具有商事能力

商事主体的商事能力包括商事权利能力和商事行为能力。商事权利能力是指商法所赋予的、商事主体能够参加商事法律关系，并在其中享有商事权利和承担商事义务资格或能力。商事行为能力则指在法律规定的范围内，商事主体通过自己的行为或意志独立进行商事活动，并取得商事权利和承担商事义务的一种资格或能力。

3.商事主体的身份或资格经商事登记而取得

商事主体本质上属于法律的拟制，是因法律赋予其权利能力和行为能力而成为商事主体的，在程序上，这种主体身份或资格的取得必须经过商事登记。

4.商事主体以从事营利性活动为其常业

商事主体的商事行为通常以营业的方式进行，即以获取利益为目的，连续、稳定地从事范围确定的经营活动。

二、商事主体的种类

（一）商个人

商个人，又称商个体、商自然人、个体商人，是指依法定程序取得商事主体资格的自然人或公民。

第一，商个人作为商法确认的主体，须经法定核准登记，才能享有商事权利能力和商事行为能力，并在核准登记的范围内从事商事行为。

第二，商个人的权利与自然人的权利不同，与一般自然人人身相关的权利，如自然人所享有的劳动的权利、结婚的权利、选举和被选举权，与商个人无关。

第三，商个人所从事的是商事行为，即以营利为目的的经营性行为；非营利的行为，如自然人的消费行为，就不属于商个人的行为。

第四，商个人对其经营债务须承担无限责任。商个人对其经营活动形成的债务，不以投入经营的财产为限负责，而以该自然人的全部财产负责，构成商个人的自然人或家庭户必须以其全部财产对商个人的债务承担连带责任。

我国《民法典》和有关法律法规规定，个体工商户、农村承包经营户、个人独资企业主均须承担无限责任。

（二）商法人

商法人，指按照法定要件和程序设立的，具有法人资格，能够独立进行商事经营活动，并享有商事权利和承担商事义务的各种商事企业。

第一，商法人是具有独立法律人格的法人组织，具备一般法人必须具备的基本条件和特点，包括依法成立、有自己的组织机构和场所、拥有独立财产、承担独立责任。

第二，商法人的设立和活动由商法规范调整，其设立依照商法规定的条件和程序，通常以注册登记方式进行。

第三，商法人以营利为目的，具有特殊的从事商事行为的权利能力和行为能力，有权在其目的范围内开展经营活动，并承担相应的法律义务和责任。

（三）商合伙

商合伙，是介于商个人和商法人之间的一种商事主体，是指两个或两个以上的合伙人按照法律和合伙协议的规定共同出资、共同经营、共享收益、共担风险，普通合伙人对合伙经营所产生的债务承担无限连带责任，有限合伙人对合伙债务承担有限责任的商事组织。

第一，商合伙由两个以上的合伙人组成；合伙人可以是自然人、法人或其他组织。

第二，商合伙是非法人企业。

第三，商合伙依商事法成立并受商法规范调整。

第四，商合伙以营利为目的。

三、商事主体的商事能力

（一）商事能力的概念

商事能力，又称商事主体资格，指商事主体独立从事商事活动，享有权利和承担义务的资格和能力，包括商事权利能力和行为能力。

第一，商事能力是权利能力与行为能力的统一。

第二，商事能力的内容具有差异性。

第三，商事能力因商事登记而确定。

（二）关于商事能力的特别限制

1. 未成年人商事能力的限制

在我国，一般认为企业主应当具备完全行为能力，原则上未成年人不得设立独资企业从事营业活动。

2.公务人员商事能力的限制

我国对党政机关及其干部从事商事经营活动，进行了严格的限制。

3.外国人商事能力的限制

按照我国法律设立的具有我国商事主体资格的外商投资企业，在依法核准的经营范围内从事经营活动；外国企业依法设立分支机构从事经营活动；外国企业依法设立常驻代表机构；外国企业经批准直接从事生产经营活动。

讲解归纳与举例

【单选题】有关商个人的论述正确的是

- A.商个人是自然人的别称
- B.作为法律主体，商个人主要享有商法上的权利，承担商法上的义务
- C.商个人与自然人的各项权利重合
- D.商个人的财产责任能力是独立的，承担有限责任

【答案】B

【解析】商个人，是指依法定程序取得商事主体资格的自然人或公民。

第2节 商业名称

一、商业名称概述

（一）商业名称的概念

商业名称又称商号，是商事主体在从事商事行为时表彰自身身份并区别于其他主体而使用的名称。我国现行立法并未使用商业名称的概念，而使用企业名称和字号。

（二）关于商业名称的法律规范

我国有关商业名称管理的法律规范，最主要的是2020年国务院修订后发布的《企业名称登记管理规定》。此外，在《民法典》《反不正当竞争法》《公司登记管理条例》《企业法人登记管理条例》《企业法人登记管理条例施行细则》《商标法》中也存在少量关于商号的规定。

（三）商业名称的法律特征

商业名称作为商事主体从事营业行为时使用的名称，具有下列法律特征：第一，商业名称的使用者是商事主体。

第二，商业名称是商事主体在营业活动中使用的名称。第三，商业名称具有主体间的区别功能。

（四）商业名称与字号、商标 1.商业名称与字号

字号通常是指商业名称中的表彰商事主体的特殊文字，是商业名称的核心部分，一般由

两个或两个以上的文字组成。例如“全聚德”“狗不理”“凤凰”“红塔山”等。

商业名称是商事主体的全称，而字号则是商业名称的构成部分或核心部分。商事主体为保护其字号，也可以将其注册为商标。

2.商业名称与商标

商标是生产经营者或者服务者在其商品或服务上使用的，由文字、图形、字母、数字、颜色组合及其他要素的组合构成的区别商品或服务来源的标记。

商业名称与商标的区别：

第一，商业名称用于区分不同的商事主体，而商标则用来区分不同的商品。

第二，一个商事主体只能有一个商业名称，但可以有多个商标。

第三，商业名称只能以文字形态存在，而商标可以以文字、图形、数字、字母、颜色及其组合的形态来表示。

第四，一个商事主体可以没有商标，但是必须有自己的商业名称

第五，商业名称的空间效力范围以核准机关辖区为限，而商标的专用权在全国范围内有效。

二、商业名称的构成、选定和取得

（一）商业名称的构成

商业名称的构成是指商业名称应当由哪些要素组成。根据《企业名称登记管理规定》第7条的规定，商业名称必须具备下列要素：

1.行政区划

除法律、法规另有规定外，企业名称中应当冠以所在地县级以上行政区划的名称或地名，一般不得使用“中国”“中华”或者冠以“国际”等

2.字号

字号是商业名称中的核心要素，同时也是商业名称中企业唯一可以自己创设的要素。字号应当符合下列要件：（1）字号应当由两个以上的字组成；（2）字号应当具有显著特征；（3）不得违反禁止性规定。

3.行业或经营特点

行业是商事主体经营活动所属的国民经济的工业或者商业的类别。商事主体应当根据其主营业务及国家行业分类标准，在企业名称中标明所属行业或经营特点。

4.组织形式

组织形式反映了商事主体的组织结构和责任形式。商事主体应当将自己所采用的组织形

式在商业名称中标明。例如采用有限责任公司形式的，应当在商业名称中标明“有限责任公司”或者“有限公司”字样；采用股份有限公司形式的，应当在商业名称中标明“股份有限公司”字样。

（二）商业名称的选定

关于商业名称的选定，目前各国法律中主要存在两种立法主义，即商业名称选定的严格主义和自由主义。

严格主义又称真实主义，是指商事主体选定的商业名称必须与其名称或者营业内容相一致，不符合的，均不予承认，且无法转让或者继承自由主义规定，商事主体的商业名称由当事人自由选择，法律原则上不加限制。

（三）商业名称的取得

我国商业名称的取得必须经过登记，这是取得商业名称权的唯一途径。

1.商业名称登记的概念和种类

商业名称的登记是指商事主体将其选定的商业名称依照法定程序，在登记机关办理注册手续。商业名称登记可以分为下列类型：

创设登记；变更登记；转让登记；废止登记；撤销登记

2.商业名称登记的效力

商业名称一经登记，商事主体就取得了该商业名称的专用权，从而产生以下两方面的效力：

第一，排他效力。是指商事主体取得商业名称权，就取得了在一定地域范围内排除他人登记和使用与该商业名称相同或者相类似的商业名称的权利。

第二，救济效力。商事主体经登记而取得商业名称的专用权，如果其他商事主体侵犯其专用权，所有人可以请求其停止侵害，如造成损失，可以要求赔偿损失。

三、商业名称权及其保护

（一）商业名称权的概念和性质

商业名称权，即商业名称专用权，是指商业名称经登记，商事主体取得该商业名称的专有使用的权利。

商业名称权兼具人格权和财产权的双重属性。一方面，商业名称依附于商事主体而存在，自身不能单独存在，因此具有人格权的性质。另一方面，商业名称具有财产价值，可以许可他人使用，可以转让，因而又具有财产权的性质。商业名称权具有以下特征：
地域性；公开性；可转让性；时间上的无限性。

（二）商业名称权的权能

商业名称权包括下列四个方面的权能：

专有使用权；许可使用权；商业名称变更权；商业名称转让权

（三）商业名称权的保护

法律对于商业名称权的保护主要体现在两个方面：

一是同一商业名称登记的排除。

二是同一商业名称或类似商业名称使用的排除。

讲解归纳与举例

【多选题】在我国，商业名称包括

- A.企业名称
- B.个体工商户
- C.字号
- D.图形商标
- E.文字商标

【答案】ABCE

【解析】在我国，依照法律和法规的规定，商业名称包括企业名称、个体工商户和个人合伙的字号，商业名称只能以文字形态存在。

第3节 商事账簿与商事审计

一、商事账簿的概念与法律意义

商事账簿是商事主体为记载和表明其营业活动和财产状况，根据会计原则，依法制作的书面簿册。商法理论中将商事账簿分为形式商事账簿和实质商事账簿。

形式商事账簿是指按商事会计法规定所制作的账簿，专指制作账簿，也可以说是狭义的商事簿。实质商事账簿指商事主体设置的反映商事主体活动的一切账簿，它在内容上不仅包括正式账簿，还包括各种会计报表、年度决算报告及各种财产债务清册，可以说是广义上的商事账簿。

本章所称商事账簿，主要指广义上的商事账簿。商事账簿的法律功能主要表现为：

第一，对商事主体自身而言，制作商事账簿可以了解其自身的营业状况和财务状况，以此作为计算盈利、分配利润的依据，并且通过对商事账簿的分析，设计企业的发展战略、发展规划，及时调整经营决策。

第二，对交易相对人而言，可以通过商事账簿了解某一商事主体的营业状况、资信能力，并据此对该商事主体的经营能力和发展前景做出判断，进而做出是否与之交易、是否对其投

资的决策，以便更好地维护自身的利益。

第三，对股东而言，商事账簿不仅是其掌握企业的财产、营业和盈利状况的依据，还是投资者分取股息、红利以及确定其股权价格和企业剩余财产的依据。同时，在强制信息披露制度之下，商事账簿的相关信息也是公司信息披露的重要内容。

第四，对有关国家主管机关而言，商事主体制作的商事账簿是政府主管部门了解商事主体经营状况，并对其进行财务、物价检查，经营效益考核和审计的主要依据，进而实现对其营业活动的监管，以确保社会公众的交易安全。国家税务部门也以商事账簿作为征纳税款的依据。

第五，在民事诉讼中，商事账簿具有重要的证据效力。

二、设置商事账簿的原则

1.强制主义原则。大陆法系国家多采此原则。法律既规定商事主体必须设置账簿，又对账簿种类、内容及记载方法有详细规定，还规定政府有关部门对商事账簿制作及其内容进行审查与监督。

2.自由主义原则。即法律不直接规定商事主体必须设立账簿，对于商事账簿是否设置，纯粹是商人的自由，法律不干涉。此种立法原则大多为英美法系国家所采用。

3.折中主义原则。即法律上仅规定商事主体有置备商事账簿的义务，但并不规定商事账簿的记载内容、形式和方法，也未规定国家主管机关的监管。

我国要求各类商事主体制作或繁或简的商业账簿，采取的是强制主义原则。

三、商事账簿的种类

商事账簿主要有三种：会计凭证、会计账簿和会计报表。

（一）会计凭证

会计凭证，指记录商事主体营业活动及收支情况的凭证和证明。

根据规定，商事主体在开展经营活动时的货币收付、款项结算、货物进出、财产增减等都必须由经办人取得或填制会计凭证，并以此作为结算的依据。

会计凭证所记载的内容必须真实、客观和可靠，任何人不得提供和制作虚假会计凭证。

1.会计凭证的种类

按其填制程序和作用，会计凭证分为原始凭证和记账凭证两类。

原始凭证，又称单据，是在经济业务发生或完成时取得或填制的，用以载明经济业务实际执行和完成情况，明确经济责任，并作为记账原始依据的一种会计凭证。原始凭证包括购货时取得的发票和结算凭证，付款时由收款人提供的收据及商业主体自己制作的发货单、收

货单及收料单。

记账凭证是根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表编制的、用以记载经济业务的性质、直接作为记账依据的一种凭证。

2.会计凭证的审核

会计凭证的审核包括形式审核和实质审核。形式审核是审核会计凭证的填制和置备是否符合规定和要求，如内容、项目是否齐全、清楚，记账凭证与原始凭证是否一致等。实质审核是指按有关法律法规规定，审查会计凭证所记录的业务内容的合理性、合法性。

（二）会计账簿

1.会计账簿的概念和作用

会计账簿，指商事主体的会计人员以会计凭证为依据，按照一定程序和方法制作的，具有固定格式且相互连结的账页所组成的，用以连续、系统、全面记载商事主体各项经营活动的簿册。固定格式的簿册通常由主管部门统一印制而提供。

会计账簿的作用包括：能够提供全面、系统的会计信息，成为会计报表编制的依据；是进行资产评估的基础，便于对商事主体财产物资进行安全与完整的监管，以维护所有者的合法权益；提供经营成果的详细资料，为经营利润的分配和各项计划执行情况的考核评价提供依据，并成为商事主体决策的重要依据；为审计检查提供依据。

2.会计账簿的种类

会计账簿按照用途可分为序时账簿、分类账簿和辅助账簿。

序时账簿，又称日记账，分为普通日记账和特种日记账两种，是按照经济业务发生时间的先后顺序逐日逐笔登记的账簿。常见的日记账账簿有现金日记账、银行存款日记账和转账日记账。

分类账簿是按照会计科目分门别类登记各项经济业务的账簿，包括总账和明细账，其中总账是按照一级会计科目设置的总分类账，而明细账是按照明细会计科目设置的明细分类账。分类账簿可以分别反映各个会计要素及其构成的内容和增减变化情况。

辅助账簿，又称备查账簿，是对某些在日记账和分类账等主要账簿中不能记载或记载不全的项目进行补充登记的账簿，是某些经济业务中重要的辅助资料，如受托加工材料登记簿、代销商品登记簿。

（三）会计报表

1.会计报表的概念和作用

会计报表，又称会计表册，指根据会计账簿及其他会计资料，按照统一的格式、内容和

方法编制的,以综合反映商事主体在一定时期内的生产经营成果和财务状况的一种书面报告和表册。会计报表主要包括资产负债表、损益表、现金流量表、财务状况说明书以及利润分配表。

2.会计报表的种类

按照编制时期是否确定,会计报表可分为定期报表和不定期报表。

定期报表是按固定日期编制的会计报表,包括年度会计报表、季度会计报表和月份会计报表。不定期报表是不定期地编制和反映企业日程或特殊情况的会计报表。

按照用途和作用,会计报表可分为主要会计报表和附属会计报表。

主要会计报表又称主表,是总结反映企业一定期间的经营成果和财务状况及其变动的报表。附属会计报表又称附表,用以补充说明主表中某些项目的详细情况。

按照所反映的资金运动状态,会计报表可分为静态报表和动态报表。

静态报表是反映企业资金运动处于相对静止状态时的情况的会计报表,如反映企业某一特定日期资产、负债和所有者权益情况的资产负债表。动态报表是指反映企业资金运动状况的会计报表,如反映企业一定期间的经营成果的损益表。

按照编制的主体,会计报表可分为个别会计报表和合并会计报表。这种分类是在企业进行对外投资的情况下形成的。

四、商事账簿的保管

我国对商事账簿的保管也采取期限限制,财政部和国家档案局 1984 年制定的《会计档案管理办法》,对会计档案的范围、立卷、归档、保管、借阅、交换、保存期限以及销毁都做了规定。

该管理办法规定,会计档案分为永久和定期两种,因账簿种类的不同而有所差别。永久会计档案如涉及外事的会计凭证、年度决算报表永久保存,各种账簿和凭证至少保存 10 年,月报、季报保存 3—5 年。(此处说的是上段:1984年制定的《会计档案管理办法》标准该标准2015年修订后,标准是:会计凭证、会计账簿等保存期限调整为 30 年,月报、季报保存10年.以最新修改为准)

五、商事审计

对商事主体的商事账簿的审计,可以称为商事审计。

我国的审计分为国家审计、内部审计和社会审计三种类型。商事审计属于社会审计。

1.商事审计的意义

商事审计的重要意义是由商事账簿本身的意义和法律效力决定的,经过审计的商事账簿与未经审计的商事账簿,其作用完全不同,缺少了审计的保障,就不能对商事账簿的真实性、公允性和合法性做出核查和评价,商事账簿本身就失去了其应有的法律意义,无法发挥其应

有的功能和作用。

2. 商事审计的职能

与一般审计相同，商事审计主要有以下三个方面的职能：

（1）经济监督，是指审计对经济活动运行的真实、正确、合法所具有的监察和督导功能。

（2）经济鉴证，是指对被审计单位会计报表及其他经济资料进行检查和验证，确定其财务状况和经营成果是否真实、公允、合法、合规，并出具书面证明，以便为审计的授权人或委托人提供确切的信息，并取得于社会公众的一种职能。

（3）经济评价，包括评定和建议两个方面。

3. 商事审计的目标

（1）真实性。

（2）完整性。

（3）合法性。

（4）准确性

（5）公允性

（6）表达与揭示

4. 商事审计报告

审计报告是审计机构或审计人员在完成某一项审计工作后，向委托或授权者提交的全面反映审计情况、分析结论、评价结果及其处理意见的一种书面报告。

根据审计结果和被审计单位对有关问题的处理情况，出具四种基本类型的审计报告：无保留意见的审计报告、保留意见的审计报告、否定意见的审计报告、无法（拒绝）表示意见的审计报告。

讲解归纳与举例

【名词解释题】 商事账簿

【参考答案】 商事账簿是商事主体为记载和表明其营业活动和财产状况，根据会计原则，依法制作的书面簿册。

【名词解释题】 会计凭证

【参考答案】 会计凭证，指记录商事主体营业活动及收支情况的凭证和证明。

第4节 商事登记制度

一、商事登记概述

（一）商事登记的概念

商事登记，也称商业登记，是指为取得、变更或终止商事主体资格，依照法律法规规定的程序，向主管机关提出申请，并由主管机关依法对申请事项审查、登记的一种法律行为和法律程序。简言之，商事登记主要是指商事主体登记。

（二）商事登记的特征

- 1.创设性：商事主体资格或其特定商事能力的起始取决于商事登记行为生效的时间。
- 2.要式性：必须依法定程序登记、向法定机关申请、内容符合法律要求、采取法定格式、符合法定条件。
- 3.公法性：是国家公权力介入商事活动的一种方式。

（三）商事登记的意义

- 1.确认商事主体的商事活动资格，保护商事主体的合法营业活动。
- 2.公示。
- 3.有利于国家监督管理，维护良好的社会经济秩序。

（四）商事登记的法律规范

我国目前尚未形成统一的商事登记法，调整商事登记关系的法律散见于众多的民事、商事实体法、程序法中，其中主要有《企业法人登记管理条例》《企业法人登记管理条例施行细则》《公司登记管理条例》《合伙企业登记管理办法》《企业名称登记管理规定》等。

二、商事登记管理机关与登记原则

（一）商事登记管理机关

商事登记的管理机关是指按照商事登记法的规定，接受商事登记申请，并具体办理商事登记的国家主管机构。

我国采取行政登记主义。市场监督管理部门”是履行统一登记市场主体职责的机关。

（二）商事登记原则

- 1.强制登记原则
- 2.全面审查原则
- 3.登记公开原则

三、商事登记的种类和程序

（一）设立登记

设立登记是指商事主体的创设人为设立商事主体而向登记机关提出申请，并由登记机关办理登记的法律行为。

商事主体的设立登记是所有登记中最基础的类型。

我国《民法典》第 77 条规定：“营利法人经依法登记成立。”

商事主体的设立登记可以分为商事企业（包括商法人和商合伙）的设立登记和商个人的设立登记。

商事企业设立登记的主要事项是：商号、商事企业的住所、营业场所、负责人或法定代表人的姓名、开业日期、经济组织形式、经营范围、经营方式、资金总额、职工人数以及其他有关事项。

商个人设立登记的主要事项是：商号、营业地址或流动营业的区域范围、姓名、住所、开业日期、经营范围、经营方式、资本总额、从业人数。

我国的设立登记主要分为五个阶段：

- 1.企业名称自主申报
- 2.申请与受理
- 3.审查：形式审查为主、实质审查为辅
- 4.核准发照
- 5.公告

（二）变更登记

商事主体登记注册的事项在登记注册后发生变化的，应在法定期限内向原登记机关申请变更登记，未经核准变更登记的，不得擅自改变。

我国《民法典》第 64 条规定：“法人存续期间登记事项发生变化的，应当依法向登记机关申请变更登记。”

（三）注销登记

商事主体终止营业时，应当向原登记机关申请办理注销登记。

我国《民法典》第 72 条规定，“清算结束并完成法人注销登记时，法人终止”。

四、商事登记的效力

（一）对商事主体的效力

在我国，根据工商登记法规的规定，商事登记不仅是商法人取得法人资格的前提条件，也是非法人的商事主体取得商事经营资格的前提条件。我国法律严禁未经登记的无照经营行为。

（二）对第三人的效力

- 1.必须在商事登记簿上登记的事项未履行登记或未予以公告的，任何该必须登记事项的参与

人都不得以该事项来对抗第三人

2.应登记事项在得到正确登记和公告之后对第三人生效 3.已登记事项在公告发生差错的情况下对第三人的效力五、商事登记制度改革

工商登记制度改革的内容主要有：

一是放宽公司注册资本登记条件。

二是将企业年检制度改为年度报告制度，任何单位和个人均可查询，使企业相关信息透明化。

三是按照方便注册和规范有序的原则，放宽市场主体住所（经营场所）登记条件，由地方政府具体规定。

四是大力推进企业诚信制度建设。

五是推进注册资本由实缴登记制改为认缴登记制，降低开办公司成本。

讲解归纳与举例

【单选题】我国的商事登记管理机关是

- A.市场监督管理部门
- B.税务部门
- C.财政部门
- D.审级部门

【答案】A

【解析】我国采取行政登记主义，市场监督管理部门是履行统一登记市场主体职责的机关。

第3章 商事行为

本章重难点分析

- 1.了解并掌握商事行为的概念、特征与分类
- 2.区分营业的不同种类
- 3.了解电子商务行为主体、方式，商事运输类型

第1节 商事行为概述

一、商事行为的概念

商事行为，又称商行为、商业行为、营业行为，是指商人经营或从事营利事业的各种营利行为。

我国至今没有商法典和商法通则，商事行为在我国不是一个法定概念。学理上通常认为，商事行为是指法律主体以营利为主要目的而实施的，并且通常具有连续性的经营行为；企业

的经营行为一般被视为商事行为，但明显不以营利为目的的行为除外。

二、商事行为的特征

1.商事行为是以营利为目的的法律行为

商事行为是一种以营利为目的的经营行为，追求利益最大化。

2.商事行为是经营性行为

经营性是指商事行为具有连续性、计划性、职业性，它表明商事主体至少在一段时间内连续地、不间断地从事某种同一性质的营利活动，为职业性营利行为。经营性应具备五要素：行为以营利为目的；营利性活动有计划性；营利性活动呈经常性；行为人活动有连续性；职业登记性

3.商事行为是商事主体所从事的行为

在我国现行商法模式下，企业作为商事主体可以实施商事行为，一般民事主体亦可以作为商个人实施商事行为。商事主体所实施的不以营利为目的之行为不能视为商事行为。

4.商事行为是体现商事经营特点的行为

商事经营的重要特征包括：较高的技术性；强调公开性；注重商事效率与外观主义；

5.商事行为是受法律严格规范和约束的行为

商事行为是法律赋予商人的一种特权行为，但对商事行为又予以特别约束和规范，赋予行为人特别的义务和责任

三、商事行为的分类

（一）单方商事行为与双方商事行为

根据商事行为的双方是否均为商人，将商事行为分为单方商事行为和双方商事行为。

单方商事行为，亦称混合交易行为，是指行为人一方为商事主体而另一方不是商事主体所从事的行为。销售商与消费者之间的买卖行为，银行与储户之间的存款行为等均属此类。双方商事行为是指当事人双方都作为商事主体而从事的行为。

（二）一般商事行为与特殊商事行为

根据商法对商事行为进行调整的共性和特性的不同，将商事行为分为一般商事行为和特殊商事行为。

一般商事行为是指在商事交易中具有共性，并受商法规则调整的行为。主要涉及商事物权行为、商事债权行为、商事交易结算行为、商事给付行为、商事交易中的谨慎义务等。

特殊商事行为是指在商事交易中具有个性，并受商法中的特别法（专门法、单行法）或特别规则调整的商事行为。如商事买卖、商事运输、商事代理、期货、银行、信托、电子商

务等。

（三）绝对商事行为与相对商事行为

根据行为的客观性质和是否附加条件为标准，将商事行为分为绝对商事行为和相对商事行为。

绝对商事行为，亦称客观商事行为，指仅根据行为的形式或性质以及法律的规定而必然确定为商事行为的行为。一般情况下，投机性买卖行为、票据行为、证券交易行为、融资租赁行为、保险行为、海商事行为等都属于绝对商事行为。

相对商事行为，亦称主观商事行为、营业商事行为，它是指在法律所列举的范围内，仅由商人实施或仅基于营利性目的实施时方可认定为商事行为的行为。相对商事行为被视为主观意义上的商事行为，主体的商人资格与行为的营利性是主观认定的依据。

（四）基本商事行为与辅助商事行为

依据商事行为在同一经营活动中引起商事关系成立的作用不同，将商事行为分为基本商事行为和辅助商事行为。

基本商事行为是指直接从事经营的商事行为。

辅助商事行为，又称附属商事行为，是指行为本身并不直接达到商事主体欲达到的营利目的，但能对以营利为目的的商事行为的实现起辅助作用的商事行为，它是依附于商人身份及其他商事行为的商事行为，如代理行为、广告行为等。

四、特殊商事行为规则

（一）商事买卖

商事买卖是商法中重要、常见的特殊商事行为之一，它是指出卖人转移标的物的所有权于买受人、买受人支付价款的商事法律行为。

商事买卖规则主要有严格限制商事买卖合同中的免责条款、最大限度自治和简约、保护普通民众、无过错责任、短期时效等原则。

（二）商事代理

商事代理是最基本的商事行为之一，狭义的商事代理是指具有商人身份的人以自己的名义或以委托人的名义，为委托人买卖或提供其他服务，并从中获取佣金的营业性活动；广义的商事代理还包括商业雇用人对企业的代理活动，如经理或其他雇员的代理。

商事代理的特点和规则主要体现在：

- 1.商事代理可以为非显名代理。
- 2.商事代理权的存续基于营业存续。

3.商事代理权的权限较大。商事行为的代理，在不违背被代理人授权意思的范围内，可以实施未被委托的行为。

（三）商事居间

商事居间是指商事主体为获取一定的报酬（佣金）而从事的为委托人与第三人订立合同提供缔约机会或进行介绍，以促成合同订立的行为。

商事居间以民事居间关系为其构成和存在的基础。

（四）商事行纪

商事行纪是指商事主体以自己的名义为委托人购买或销售货物、有价证券等，由此获取报酬，并以此作为职业性经营的行为。

（五）商事留置

商事留置是指在双方商事行为中，债权人为了实现其债权，留置债务人的物或有价证券，并在其不履行义务时，变卖或对标的物折价以受偿其债权的行为。

（六）商事保证

商事保证是指在商事经营中，保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

商事保证的特殊规则：1.商事保证的独立性；2.商事保证的单独性；3.商事保证形式的严格性；4.商事保证的保证人通常无先诉抗辩权。

（七）商事债权的时效制度

商事债权的时效是指商事债权失效的权利性质和失效的时间计算。

（八）商事信用

商事信用是英美法系国家商法的概念，指在商品销售、提供服务、提供贷款等商事交易中取得商品、接受服务或贷款的一方，同意在规定的未来某日期支付货款、服务报酬、贷款本息的承诺。这种承诺代表一种保证，体现了信守诺言的行为。

（九）融资租赁

融资租赁是融合了买卖、租赁和金融信贷的一种商事行为，是指出租人和承租人双方商事主体约定，出租人根据承租人的决定，向承租人选定的第三人（供货方）购买承租人选定的物品，然后将其租给承租人长期使用，以收取承租人支付的租金的方式来收回投资的一种商事行为。

（十）商事仓储

商事仓储是由商事主体所从事的仓库经营，即保管人对存货人交付的仓储货物进行储存

和保管的商事行为。

（十一）商事运输

商事运输包括货运和旅客运输。

讲解归纳与举例

【单选题】特殊商事行为不包括以下哪项？

A.商事代理 B.辅助商人 C.商事行纪 D.商事居间

【答案】B

【解析】特殊商事行为通常包括商事买卖、商事行纪、商事运输、商事仓储、商事居间、商事代理、商事期货、商事信托、商事票据、商事保险、海商、商事特许经营等内容。

第2节 营业

一、营业概述

（一）营业的概念和特点

“营业”是指运营中的营利事业，既包括组织和经营活动，也包括财产关系。营业制度主要包括营业构成、营业权、营业自由与限制、营业场所、营业资产、营业转让等。

营业具有以下特点：

- 1.营业只能是商事主体所从事的组织行为。
- 2.营业的内容不仅仅应该遵守法律，而且应该为人知悉、不违背善良风俗。
- 3.营业可以成为权利的客体，具有财产属性，可以增值和贬值，可以转让、出资、租赁、担保等。
- 4.营业是综合性行为，包括具体经营行为和组织管理行为。

（二）营业权

营业权是指商事主体基于平等的主体资格和营业机会，自由选择特定商事领域进行经营，从事以营利为目的的活动而免受国家法律之外的不合理限制和其他主体干预的权利。

在我国，营业权不是一个法定权利，而是一种推定权利。

（三）营业权的保护

营业权的保护可分为宪法保护、民法保护、竞争法保护、刑法保护。

二、营业资产

（一）营业资产的概念

营业资产，又称营业财产（即客观意义上的营业），是指商事主体所拥有的、基于营利目的而形成的并用于营业活动的全部财产。

（二）营业资产的特征

营业资产具有特殊的法律属性：**1.**营业资产具有财产属性，也称资本属性；**2.**营业资产的价值实现既取决于财产，更依赖于营业；**3.**营业资产具有整体性、确定性、可转让性特点；**4.**具有独立性，独立为实现特定营业目的而结合；独立构成特定化资产；独立资产价值大于各项财产累加的价值总和；独立于资产权利人的其他财产。

（三）营业资产的分类

营业资产通常可以做出如下分类：

1.有形财产与无形财产：从资产的静态状态分类。

有形财产是指具有物理外观的财产，如商品、现金、有价证券、器具、原材料等。

无形财产包括商誉、商业名称、商业秘密、客户资源、知识产权和地理位置等。

2.积极财产与消极财产：从资产与负债角度分类。

积极财产包括物（不动产、动产等）、权利（物权、债权、专利权、商标权、著作权等）、无形资产（商业秘密、商誉、客户资源等）；消极资产包括营业过程中各种负债形成的资产。

三、营业转让

（一）营业转让的概念

营业转让是指商事主体将其所拥有的组织化的营业全部或者部分转让给受让人的行为，它既包括经营者地位的转移，也包括营业财产的转让，其实质是特定经营权的让与。

（二）营业转让合同

营业转让合同是指出让人与受让人之间基于意思自治原则就营业转让中的标的、权利、义务等事宜做出的合意约定。

1.营业转让合同的客体：营业资产

2.营业转让人的义务：营业转让义务、竞业禁止义务、营业的瑕疵担保义务

3.营业转让合同中的第三人保护

讲解归纳与举例

【多选题】下列哪些属于营业资产

A.商品

B.股票

C.商业秘密

D.商业信誉

E.动产

【答案】ABCDE

【解析】营业财产包括不动产、动产、债权及债务、有形资产及无形资产等。

第3节 连锁经营与特许经营

一、连锁经营概述

（一）连锁经营的概念

连锁经营是指若干商事主体在商品销售营业中，通过共同取得同一特许经营权、使用统一商号等方式，经营同类商品、接受同一货源、进行统一管理、共享规模效益，但各自分散独立核算经营的一种现代商业经营模式。

连锁经营是一种特殊的商事行为。

（二）连锁经营的分类

在我国，依据经营权和所有权之间的集中程度作为标准，将连锁经营分为直营连锁、特许连锁和自由连锁三种类型。

直营连锁又称正规连锁，是指由连锁总部直接投资、经营、管理各个连锁分店的连锁经营模式。

特许连锁，是指特许人以特许经营合同的形式，将自己所拥有的产品或业务、商号、商标、标识、专利和专有技术、经营和管理模式等授予被特许人使用，被特许人在特许权限范围内从事经营活动，并按特许合同约定向特许人支付相应报酬的经营模式。特许连锁具有所有权集中和经营权分散、特许人与被特许人之间具有纵向合同关系而非产权关系等法律特点。自由连锁又称自愿连锁，是指由产权独立的零售商自愿组成的，实行集中进货、统一制定销售战略、统一使用物流及信息等设施的契约型联合经营模式。自由连锁中各连锁分支机构均为独立法人，各自的资产所有权关系不变。

（三）连锁经营的组织机制

连锁经营的组织机制由连锁总部、连锁分店、连锁配送中心组成。

连锁总部又称总公司，是指以自己独立的财产发起或主导连锁企业开展连锁经营活动，并始终位于连锁经营活动的组织或统领地位，独立承担责任的商人。

连锁分店又称连锁门店，是指连锁经营总部之下的不同产权形式的分支机构，是构成整个连锁体系的基本组织单位。

连锁配送中心是指隶属或独立于连锁总部，承担各连锁分店所需商品的运输、仓储、加工、集配等任务的综合流通机构，其核心是销售代理和商品配送。

（四）连锁经营的法律特征

- 1.经营管理的规范性
- 2.内部架构和运营的组织性 3.外部活动的统一性

二、特许经营概述

（一）特许经营法律关系

特许经营关系是一种复合契约关系。

- 1.是营业合作契约关系；
- 2.是特许权授予契约关系；
- 3.包含买卖、租赁、培训、开店、货物运输等商业契约关系。特许经营法律关系由主体、客体和内容构成。

特许经营法律关系的主体包括特许人、被特许人、分区特许经营中的分特许人等。商业实务中，特许人常被称为“总部”，被特许人则被称为“加盟商”或“加盟店”。特许经营法律关系的客体是特许经营权。

（二）特许经营合同

特许经营合同是特许人和被特许人缔结的，由特许人授予被特许人特许权，双方基于特许经营而确立的权利、义务以及由此而产生的各种关系的合意。

根据我国法律规定，特许经营合同必须采用书面形式。

讲解归纳与举例

【多选题】连锁经营包括哪些类型

- A.直营连锁 B.特许连锁
C.自由连锁 D.分公司
E.子公司

【答案】ABC

【解析】在我国，将连锁经营分为直营连锁、特许连锁和自由连锁三种类型。

第4节 电子商务

一、电子商务法概述

电子商务是指以数据电文为交易手段进行的商务活动。

电子商务法是指调整以数据电文为交易手段进行的商务活动中所产生的社会关系的法律规范的总称。

数据电文，按照《联合国国际贸易法委员会电子商务示范法》的规定，是指“经由电子手段、光学手段或类似手段生成、储存或传递的信息，这些手段包括但不限于电子数据交换、

电子邮件、电报、电传或传真”。

二、电子商务行为主体

（一）电子商务行为主体的概念

电子商务行为主体，是指通过电子商务方式进行交易的企业、个人和其他组织。

根据电子商务主体在电子商务交易中的角色及功能的不同，可将其区分为电子商务交易的当事人、网络服务提供商及电子结算中介方等。

所有网络用户，无论是企业、个人，还是其他组织，甚至政府部门，都有可能成为电子商务行为主体。

（二）电子商务企业的法律形态

电子商务企业，是指以互联网为基础，以网站或网页形态出现的虚拟企业。

电子商务企业形态主要分为三种：企业网站；在线商店，包括在线超市和在线专卖店；在线交易平台。

三、电子商务行为方式

（一）电子商务合同的概念

电子商务合同是当事人之间通过信息网络以电子形式达成的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

（二）电子代理人

电子商务合同主体中最为特殊的角色是“电子代理人”。电子代理人，是指被用来独立地进行某一行为、对电子记录或履行独立做出反应，而在做出此种行为或反应时全部或部分地无须人为检查或行为的计算机程序或其他自动化装置。

（三）电子商务合同的订立——电子签名

1. 电子签名的概念和使用范围

电子签名，又称电子签章，是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

在我国，是否使用电子签名，是一种“私法自治”的安排——民事活动中的合同或者其他文件、单证等文书，当事人可以约定使用或者不使用电子签名、数据电文。

2. 电子签名的合法性

当事人决定使用电子签名，电子签名与数据电文在发送、原件表现形式、保存方式、证据审核等方面，仍须符合法律的强制性规定。

3. 电子签名的效力

可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。4.电子签名的认证

在我国，电子签名需要第三方认证的，应由依法设立电子认证服务提供者提供认证服务。

四、电子支付

（一）电子支付的概念与特征

电子支付是电子交易的当事人，包括消费者、厂商和金融机构，使用电子手段进行的货币支付或资金流转。

电子支付的特征：

- 1.电子支付是采用数字化方式实现支付目的支付行为。
- 2.电子支付是在一个开放的系统平台中使用先进的通信手段完成。
- 3.电子支付一般涉及多方当事人。
- 4.电子支付的支付效率较高。

（二）电子支付的类型

按照不同标准可对电子支付的类型做不同区分。

- 1.自动柜员机交易、销售点终端交易、电话支付、移动支付和网上支付等不同类型
- 2.智能卡、电子现金与电子钱包、电子支票、电子资金划拨等不同类型
- 3.网络支付；预付卡的发行与受理；银行卡收单；中国人民银行确定的其他支付服务

（三）第三方支付

1.第三方支付的概念

所谓第三方支付，系指银行及非银行金融机构之外的“非金融机构”所从事的支付服务。

2.第三方支付电子支付的类型

从国内外实践来看，第三方支付电子支付有以下两种模式：一是支付通道模式，即支付平台向消费者提供银行网关的代理服务，消费者直接进入银行账户，由银行完成转账，典型代表是美国的 PayPal。二是支付平台账户模式，用户在支付平台设立虚拟账户，对账户进行充值、收款和付款，典型代表是支付宝。

讲解归纳与举例

【多选题】下列哪些支付方式属于电子支付

- A.支付宝
- B.微信支付
- C.PayPal
- D.ATM 机交易

E.网上转账

【答案】ABCDE

【解析】电子支付是采用先进技术，以数字化方式来完成信息传输，进而实现支付目的的支付行为。

第5节 商事运输

一、商事运输概述

商事运输是指基于营利目的及营业需要而由商事主体实施的货物运送行为。商事运输与民事运输的主要区别在于：

- 1.运送主体不同。商事运输是商事主体实施的运送行为，商事主体实施该运送行为是基于营利及营业目的。
- 2.运送标的不同。民事运输一般指旅客的运送，也包括偶然的货物运送。广义的商事运输也包括货物运送及旅客运送，而狭义的商事运输仅指货物运送行为。
- 3.基于运输工具及运输方式的不同，商事运输可以区分为陆上商事运输、海上商事运输、航空运输及多式联运。

二、陆上商事运输

陆上商事运输主要包括铁路运输与公路运输。

（一）铁路运输

铁路运输中的铁路包括国家铁路、地方铁路、专用铁路和铁路专用线。

1.铁路运输承运人

铁路运输承运人，是指铁路运输企业。通常须获得特定资质许可，方能从事铁路运输行为。

2.铁路运输合同

铁路运输合同是明确铁路运输企业与旅客、托运人之间权利义务关系的协议。铁路运输合同属于公共商事行为，法律形式、运送标的物、合同价格条款、变更与解除等方面受限。陆上商事运输主要包括铁路运输与公路运输。

3.承运人责任

铁路运输企业在运输过程中，应当承担优先运输、准点与安全运输、足额运输等责任。

（二）公路运输

公路按其在公路路网中的地位分为国道、省道、县道和乡道，并按技术等级分为高速公路、一级公路、二级公路、三级公路和四级公路。

1.公路运输承运人

公路运输承运人须是经过国务院交通行政主管部门批准并持有运输经营许可证的单位和人。

2.公路运输合同

公路运输应签订运输合同，可以书面形式、口头形式或其他形式订立。3.承运人责任
从事公路货物运输的承运人须持有经营公路货物运输的营业执照。

三、海上商事运输

海上商事运输，是指在海域上以船舶为工具所进行的货物运送行为，可以分为国际海上货物运输和国内海上货物运输，包括海江之间、江海之间的直达货物运输。

（一）海上货物运输合同

是指承运人收取运费，负责将托运人托运的货物经海路由一港运至另一港的合同。在海上货物运输中，提单是极为重要的法律文件。

（二）承运人责任

1.承运人的合同责任

承运人应当妥善地、谨慎地装载、搬移、积载、运输、保管、照料和卸载所运货物，按照约定的、习惯的或者地理上的航线将货物运往卸货港。

2.实际承运人的责任

在海上货物运输中，承运人将货物运输或者部分运输委托给实际承运人履行的，承运人仍然应当依法对全部运输负责。对实际承运人承担的运输，承运人应当对实际承运人的行为或者实际承运人的受雇人、代理人在受雇或者受委托的范围内行为负责。

四、航空运输

航空运输分为公共航空运输与通用航空运输。

（一）航空运输承运人

在我国，从事经营性通用航空运输，仅限于企业法人，而且应当向国务院民用航空主管部门申请领取通用航空经营许可证，并依法办理工商登记。从事非经营性通用航空运输的，应当向国务院民用航空主管部门办理登记，方能取得承运人资格。

（二）航空运输合同

在航空运输过程中，应当订立航空运输合同。客票和航空货运单可作为证明航空运输合同存在的证据。

（三）承运人责任

因发生在航空运输期间的事件，造成货物毁灭、遗失或者损坏的，承运人应当承担责任。承运人不承担责任的情形包括：（1）货物本身的自然属性、质量或者缺陷；（2）承运人或者其受雇人、代理人以外的人包装货物的，货物包装不良；（3）战争或者武装冲突；（4）政府有关部门实施的与货物入境、出境或者过境有关的行为。

货物在航空运输中因延误造成的损失，应由承运人承担责任，但是，承运人证明本人或者其受雇人、代理人为了避免损失的发生，已经采取一切必要措施或者不可能采取此种措施的，不承担责任。

五、混合运输：多式联运

多式联运，是指多式联运经营人以两种以上的不同运输方式，负责将货物从接收地运至目的地交付收货人，并收取全程运费的行为。

多式联运经营人是指本人或者委托他人以本人名义与托运人订立多式联运合同的人。在多式联运过程中，货物的毁损、灭失发生于多式联运的某一运输区段的多式联运经营人的赔偿责任和责任限额，适用调整该区段运输方式的有关法律规定。

六、商物流

商物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。

讲解归纳与举例

【多选题】商事运输包括以下哪些类型

- A.铁路运输
- B.公路运输
- C.海上货物运输
- D.公共航空运输
- E.多式联运

【答案】ABCDE

【解析】商事运输可以区分为陆上商事运输（铁路和公路）、海上商事运输、航空运输（公共和通用）及多式联运。

第4章 公司法

本章重难点分析

- 1.了解并掌握公司的分类、种类、设立规则
- 2.掌握公司的资本制度类型

- 3.掌握股份与股权的概念和内涵
- 4.了解并掌握公司的组织机构
- 5.了解公司的分立、合并、解散与清算相关程序

第1节 公司法概述

一、公司的概念与特征

（一）公司的概念

依据我国《民法典》和《公司法》的规定，在我国，公司是指在中国境内由股东出资依法设立的，以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的营利法人。

（二）公司的特征

1.营利性

一是设立公司的目的是获取利润。二是公司应连续地从事同一性质的经营活动。

2.社团性

社团性亦称联合性，是指公司作为人的结合，其股东和股权一般应具有多元性。

3.法人性

公司作为法人必须具备以下条件：（1）必须依法设立。（2）必须有独立的财产。（3）能够独立地承担民事责任。

二、公司法的对象与性质

（一）公司法的调整对象

- 1.公司的全部组织关系。
- 2.公司的部分财产关系。

（二）公司法的性质

- 1.公司法是组织法。
- 2.公司法是公法化了的私法。
- 3.公司法是国家管理公司的行为规范。

三、公司的分类与种类

（一）公司的分类

- 1.无限公司、有限公司、股份有限公司、两合公司和股份两合公司
- 2.人合公司（以个人信用为主）、资合公司（以资本为主）和人合兼资合公司（个人+资本）
- 3.封闭式公司（股东持有全部资本）、开放式公司（公开招股）
- 4.母公司和子公司：二者都是具有独立主体资格的法人，依法独立承担民事责任。

5.总公司和分公司：分公司在法律上和经济上都没有独立性，不具有法人资格。

6.本国公司、外国公司和跨国公司

（二）公司的种类

我国只承认有限责任公司和股份有限公司两种公司类型。

1.有限责任公司

（1）有限责任公司的概念与特征

有限责任公司，又称有限公司，是指由 50 个以下股东出资设立的，每个股东以其所认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任的营利法人。

有限责任公司具有以下特征：股东人数的限制性；股东责任的有限性；股东出资的非股份性；公司资本的封闭性；公司组织的简便性；资合与人合的统一性。

（2）一人公司

一人公司，系一人有限责任公司的简称，是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司。一人公司是有限责任公司的特殊组织形式。

（3）国有独资公司

国有独资公司，是指由国家单独出资、由国务院或者地方人民政府授权本级人民政府国有资产监督管理机构履行出资人职责的有限责任公司。

2.股份有限公司

（1）股份有限公司的概念与特征

股份有限公司，又称股份公司，是指注册资本由等额股份构成并通过发行股票筹集资本，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任的营利法人。

股份有限公司具有以下特征：股东责任的有限性；资本募集的公开性；股东出资的股份性；公司股票的流通性；公司财产的独立性。

（2）上市公司

上市公司，是指其股票在证券交易所上市交易的股份有限公司。

上市公司具有以下特点：第一，上市公司是股份有限公司的一种。第二，上市公司是股票在证券交易所进行交易的股份有限公司。第三，上市公司必须符合法定条件，且须履行审批程序。未经批准，不得上市

四、公司的设立

（一）公司设立的概念

公司设立,是指发起人为组建公司,使其取得法人资格所进行的一系列法律行为的总称。

公司设立与公司成立的区别:

(1) 发生阶段不同。设立行为发生于公司成立之前,成立行为则发生于公司被依法核准登记之时,是设立行为被法律认可的一种法律后果

(2) 行为性质不同。设立行为发生于发起人或发起人与认股人之间,是一种私法行为。成立行为则发生于发起人与登记机关之间,主要是登记机关的行政行为,具有公法性质

(3) 法律效力不同。设立阶段,公司不具备独立的法律主体资格,一般视为合伙

(4) 解决有关行为争议的依据不同。设立过程中的争议和纠纷,一般依照发起人之间订立的协议解决。成立过程中因设立事实能否得到登记机关或审批机关的登记认可或批准所产生的争议,当事人可以提起行政诉讼。

(二) 公司设立的方式

1. 发起设立

发起设立,亦称共同设立或单纯设立,是指公司的资本由发起人全部认购,不向发起人之外的任何人募集而设立公司的方式。

2. 募集设立

《公司法》第 77 条第 3 款,“是指由发起人认购公司应发行股份的一部分,其余股份向社会公开募集或者向特定对象募集而设立公司。”

我国的募集设立可以分为社会募集设立和定向募集设立两种形式。

(三) 公司设立的效力

公司设立最直接的法律后果:

一是公司经过设立程序,符合法定条件,被依法核准登记,取得法人资格;

二是公司经过设立程序,但不符合法定条件或违反法律强制性规定,公司不能成立或导致公司设立无效和撤销。

(四) 发起人的责任

按照我国《公司法》和相关司法解释的规定,发起人除应承担公司未成立的先合同责任外,还须承担下列责任:

(1) 公司成立,发起人须承担资本充实责任。发起人须保证公司在登记时,其财产的实际价值不少于章程所规定的资本额。如果公司登记时其财产不能满足章程所规定的数额,发起人有义务填补这部分差额。

（2）公司不成立，发起人须对设立行为所产生的债务和费用承担连带责任。当公司不能成立时，须由发起人对设立行为所生费用和债务负连带赔偿责任，对已收股款负返还的连带责任。在采取募集方式设立公司的情况下，发起人对认股人已缴纳的股款负有返还并加算银行同期存款利息的责任。

（五）公司章程

公司章程，是指公司必备的规定公司组织及活动的基本规则的书面文件，是以书面形式固定下来的股东共同一致的意思表示。

依据法律对公司章程记载的事项有无明确规定，以及所记载事项对章程效力的影响，章程的记载事项可分为绝对必要记载事项、相对必要记载事项和任意记载事项。

绝对必要记载事项，是指法律规定的章程中必须予以记载的、不可缺少的事项。通常包括公司的名称、住所地、经营范围、注册资本、利润分配、财产责任等

相对必要记载事项，是指由法律列举规定的、可以听凭章程制定人自主决定是否载入章程的事项。如果不予记载或某项记载不合法，则仅该事项无效，章程的其他事项仍然有效，不影响整个章程的效力。

任意记载事项，是指只要不违反法律的强行规定、公共秩序和善良风俗，章程制定人便可根据实际需要载入章程的事项。如不记载，不影响整个章程的效力；如记载不合法，也仅该事项无效，章程的其他事项仍具效力。

五、公司的人格

（一）公司人格的独立

公司作为最典型的法人，具有独立的人格。

公司具有独立的法人人格，即独立财产、独立名称、独立意思和独立责任。

公司独立于股东之外，股东有限责任，即股东仅以其出资额为限对公司承担责任，超过了出资额，股东则无责任。

（二）公司人格的否认

公司人格的否认，又被形象地概括为“揭开公司的面纱”，是指在具体的法律关系中，基于特定事由，否认公司的独立法人人格，使股东对公司债务承担无限责任。

我国《公司法》第 20 条第 3 款规定：“公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。”

第 63 条规定：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”

讲解归纳与举例

【单选题】某公司下属的一家分公司以自己名义对外签订的合同，其效力如何？

- A.无效
- B.有效，其责任由分公司独立承担
- C.有效，其责任由总公司承担
- D.有效，其责任由分公司独立承担，总公司负连带责任

【答案】C

【解析】分公司不是独立法人，责任由总公司承担。

第2节 公司的资本制度

一、公司资本的构成

公司资本专指在公司成立时由章程所确定的由股东出资构成的公司财产总额。

依据我国《公司法》第27条规定，有限责任公司和股份有限公司的资本由货币、实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产等构成。

（一）货币

货币或现金是最基本的资本构成。

（二）实物

实物，又称有形资产，主要包括建筑物、厂房和机器设备等。

股东对用以出资的实物必须拥有所有权，并应出具拥有所有权和处分权的有效证明。

（三）知识产权

知识产权包括专利权、商标权、著作权、专有技术等。

（四）土地使用权

土地使用权，是指非土地所有人对土地加以利用和取得收益的权利

（五）其他

除上述所列各项外，依法可以转让的并可以用货币估价的非货币财产，如股权、债权等，都可以作为股东的出资。

关于股东出资的禁止，《公司登记管理条例》第14条规定：“股东不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等作价出资”。

二、公司资本制度的类型

（一）法定资本制

又称确定资本制，是指公司在设立时，必须在章程中对公司的资本总额做出明确的规定，

并须由股东全部认足，否则公司不能成立。

（二）授权资本制

是指在公司设立时，资本总额虽应记载于章程，但并不要求发起人全部认足，只认定并缴付资本总额中的一部分，公司即可成立；未认定部分，授权董事会根据需要，可随时发行新股募集之。

（三）折中资本制

又称认可资本制，是介于法定资本制与授权资本制之间的一种公司资本制度。我国公司法实际采用的是法定资本制。

三、出资与转让

（一）出资

1. 股东出资方式

（1）出资平等主义

即规定有限责任公司股东的每份出资额是均等的，股东可以认购一份，也可以认购数份。

（2）出资不平等主义

指股东只能认购一份出资，但各股东所认缴的出资额可以不同。

在我国的公司实践中，有限责任公司股东的出资基本上是采用出资不平等主义，也即单一出资制。

（3）基本出资制

即每一股东只能认购一份出资，每一份出资数额可以不同，但必须是基本出资数额的整数倍。

对于股份有限公司股东的出资方式，世界各国均确认资本分为股份，股份集为资本。股份为资本构成的最小单位，具有不可分性；股份的表现形式为股票，具有可流通性。

2. 股东出资的缴纳

出资是股东最基本的义务，任何公司的股东都必须履行出资义务。有限责任公司的资本总额应由各股东全部认足。

我国公司法允许股东分期缴纳出资。

3. 违反出资义务的民事责任

（1）有限责任公司股东违反出资义务的责任：违约责任、差额补足责任

（2）股份有限公司发起人的责任

公司不能成立时，发起人对设立行为所产生的债务和费用负连带责任

（二）转让

1. 有限责任公司股东出资的转让

有限责任公司股东出资的转让须遵守下列规定：

- （1）有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权
- （2）股东向股东以外的人转让股权应当经其他股东过半数同意
- （3）经股东同意转让的股权，在同等条件下其他股东有优先购买权
- （4）转让股权本质上属于处理私权，应当奉行意思自治的原则
- （5）股权的转让还可能因法院依照强制执行程序而转让
- （6）在转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载
- （7）自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格。但是，公司章程另有规定的除外。
- （8）有限责任公司的股东未履行或者未全面履行出资义务即转让股权，受让人对此知道或者应当知道，公司请求该股东履行出资义务的，受让人应对此承担连带责任
- （9）股权转让后尚未向公司登记机关办理变更登记，原股东将仍登记于其名下的股权转让、质押或者以其他方式处分，受让股东以其对于股权享有实际权利为由，请求认定处分股权行为无效的，人民法院可以参照《民法典》第 311 条的规定处理

2. 股份有限公司股东出资的转让

股份有限公司的股东持有的股份可以依法转让，但不得违反以下规定：

- （1）股东转让其股份，应当在依法设立的证券交易场所进行或者按照国务院规定的其他方式进行
- （2）记名股票由股东以背书方式或者法律、行政法规规定的其他方式转让；转让后由公司将受让人的姓名或者名称及住所记载于股东名册
- （3）无记名股票的转让，由股东将该股票交付给受让人后即发生转让的效力
- （4）发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让
- （5）公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让
- （6）公司不得收购本公司股份。特殊情形除外

(7) 公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的

(8) 上市公司的股票，依照法律、行政法规和证券交易所的交易规则上市交易

四、增资与减资

(一) 增资

增资即增加资本，是指公司为筹集资金、扩大营业，依照法定的条件和程序增加公司的资本总额。有限责任公司的增资属特别决议，须经代表 $\frac{2}{3}$ 以上表决权的股东通过，方能做出决议。

股份有限公司的增资亦须经出席会议的股东所持表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上通过。

(二) 减资

减资即减少资本，是指公司因资本过剩或亏损严重，根据生产经营的实际情况，依照法定条件和程序减少公司的资本总额。

按照资本不变原则的要求，一般不允许公司减少资本。

有限责任公司减资决议的做出须经代表 $\frac{2}{3}$ 以上表决权的股东通过。公司决议减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单

股份有限公司的减资决议亦应由出席股东所持表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上通过。减少公司发行的任何类别股份的总数，还必须报有关部门审查同意

讲解归纳与举例

【多选题】在我国，商业名称包括

- A.企业名称
- B.个体工商户
- C.字号
- D.图形商标
- E.文字商标

【答案】ABCE

【解析】在我国，依照法律和法规的规定，商业名称包括企业名称、个体工商户和个人合伙的字号，商业名称只能以文字形态存在。

第3节 股份与股权

一、股份

(一) 股份的概念与特点

股份是股份有限公司资本构成的最小单位，即公司的全部资本分为金额均等的股份，全

部股份金额的总和即为公司资本的总额。

资本分为股份，股份集为资本。

股份有限公司的股份具有以下特点：

第一，股份是资本构成的最小单位，具有不可分性。

第二，股份是对资本的等额划分，具有金额的均等性。

第三，股份是股权的基础，具有权利上的平等性。第四，股份表现为有价证券，具有自由转让性。

（二）股份的种类

1.普通股和特别股

这是依股东享有权益和承担风险的大小所做的分类。

（1）普通股，即普通股份，是指对公司权利一律平等，无任何区别待遇的股份。

普通股是公司资本构成中最基本的股份，也是公司资本构成中风险最大的股份。

普通股具有三个特点：股息不固定；清算时位于公司债权人和优先股股东之后；享有表决权

（2）特别股，亦称类别股，是指在普通股之上附加某种权利或限制、扩张某些权利的股份类别。

2.额面股和无额面股

这是依股份是否以金额表示所做的分类。

（1）额面股，是在股票票面上标明了一定金额的股份。

（2）无额面股，又称比例股或部分股，即股票票面不表示一定金额，只表示其占公司资本总额一定比例的股份。

3.记名股和无记名股

这是依是否在股票上记载股东的姓名所做的分类。

（1）记名股，是将股东的姓名或名称记载于股票的股份。

（2）无记名股，是股票上不记载股东姓名或名称的股份。

4.表决权股和无表决权股

这是依股份有无表决权所做的分类。

（1）表决权股，即享有表决权的股份。

（2）无表决权股，是依法或依据章程被剥夺了表决权的股份。

二、股权

（一）股权的概念与种类

股权，亦即股东权。狭义的股权是指股东因向公司出资而享有的权利。广义的股权则是对股东权利和义务的总称。

股权是任何公司类型中的股东都普遍享有的权利。

- （1）按股权内容不同，将股权分为自益权与共益权
- （2）按股权性质不同，将股权分为固有权与非固有权
- （3）按股权行使方式不同，将股权分为单独股东权与少数股东权

（二）股权的行使

1. 股权的代理行使

股东既可以亲自行使股权，也可以委托代理人代为行使股权。

2. 股东知情权的行使

股东知情权，是指法律赋予股东的通过查阅、复制公司章程、股东会与董事会决议、公司会计报告、公司会计账簿等文件材料，了解公司运营状况和公司高级管理人员业务活动的权利。

3. 股东利润分配权的行使

利润分配权，是指股东按照出资或股份比例请求公司分配利润的权利。

（三）股权的确认

股权的确认实质上就是对股东资格的确认。

1. 不出资的股权确认

不出资，是指股东虽然在章程中承诺出资，但实际上在公司成立后至股权发生争议时并未出资。

2. 瑕疵出资的股权确认

瑕疵出资，是指股东用以出资的财产、财产权利或出资行为不符合法律规定或章程约定。瑕疵出资主要有三种表现形式：出资不足，出资不实，抽逃出资

3. 隐名出资的股权确认

隐名出资，是指实际出资人以他人名义登记为股东的行为。

（四）股权的转让

1. 有限责任公司股东的股权转让

（1）股东之间转让（自由主义）

股东之间可以相互转让其全部或者部分股权，无需通知其他股东，其他股东没有优先购

买权

（2）股东对第三人转让（限制主义）

应当以书面或其他能够确认收悉的合理方式通知其他股东，经其他股东过半数同意其他股东自接到书面通知之日起 30 日未答复的，视为同意转让。

其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

2.股份有限公司股东的股份转让

股东转让其股份，应当在依法设立的证券交易场所进行或者按照国务院规定的其他方式进行

发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

（五）股东代表诉讼

股东代表诉讼，又称股东派生诉讼或股东衍生诉讼，是指当公司的合法权益受到不法侵害而公司怠于起诉时，符合法定条件的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起的诉讼。

股东代表诉讼的原告应为股东，包括普通股股东与优先股股东。

我国《公司法》对股东代表诉讼设置了前置程序，股东在起诉前应书面请求监事会、监事、董事会、执行董事向人民法院起诉，只有在遭到后者拒绝，或者自后者收到请求之日起 30 日内未起诉，或有《公司法》第 151 条第 2 款规定的紧急情况，股东才能向法院提起代表诉讼。

讲解归纳与举例

【单选题】股东因向公司出资而享有的权利称为

- A.股权
- B.股份
- C.出资权
- D.收益权

【答案】A

【解析】狭义的股权是指股东因向公司出资而享有的权利。

第4节 公司的组织机构

一、公司组织机构概述

（一）公司组织机构的含义

公司的组织机构是为了适应公司的组织机能和治理结构而依法设置的实现其商事权利能力和商事行为能力的有机统一的组织系统，通常包括公司的意思形成机构、业务执行机构和内部监督机构。

（二）公司组织机构设置的基本原则

1.分权制衡原则

2.效率优先原则

3.民主与集中相结合原则

二、股东会

（一）股东会的概念

从广义上说，股东会泛指在各类公司中由全体股东组成的公司权力机构，它包括股份有限公司的股东大会和有限责任公司的股东会。

从狭义上说，股东会专指由全体股东组成的有限责任公司的权力机构，在股份有限公司中则专称股东大会。

股东会都具有以下特征：

第一，股东会须由全体股东组成

第二，股东会是公司的最高权力机构，也是公司的意思形成机构

第三，股东会是公司的法定但非常设机构，仅以普通年会和临时会议的形式行使职权，在股东会闭会后，股东只能通过有关参与权的行使，对公司的生产经营活动施加影响。

（二）股东会的职权

（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会或者监事的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本做出决议；（8）对发行公司债券做出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；（10）修改公司章程；（11）公司章程规定的其他职权。

（三）股东会的种类

股东会通常分为普通会议和特别会议两种。

1. 普通会议

普通会议，又称股东常会、股东年会或定期会议，是指公司按照法律或章程的规定按时召开的会议。普通会议是必须召集的股东会议，一般是一年一次。

2. 特别会议

特别会议，又称临时会议或特别股东会，是指在普通会议之外不定期召开的全体股东会议。

（四）股东会的召集

1. 召集人

无论是普通会议，还是特别会议，召集人原则上为董事会，由董事长主持

2. 召集程序

股东会的召集应以书面形式于会议召开的一定期限之前通知或通告股东

3. 股东表决权及其行使

表决权是股东基于其股东地位而享有的一种固有权利，除非依据法律规定，不得以公司章程或股东会决议予以剥夺或限制。

我国公司法规定股份有限公司股东大会的表决采取一股一票制；有限责任公司股东会由股东按出资比例行使表决权。我国《公司法》在坚持“一股一票制”的同时，为维护中小股东的权益，允许公司章程决定实行累积投票制。

（五）股东会决议的种类

根据具体的决定事项和多数标准，股东会的决议分为普通决议和特别决议。

普通决议：多数通过即可；特别决议：须经出席会议的股东所持表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上通过

（六）股东会的会议记录

我国《公司法》规定：股东会议应将所议事项的决定制成会议记录，主持人、出席会议的股东、董事应当在会议记录上签名。

（七）股东会决议的无效与撤销

《公司法》第 22 条第 1 款的规定，公司股东会或者股东大会的决议内容违反法律、行政法规的无效。公司股东、董事、监事等与股东会或者股东大会的决议内容有直接利害关系的人，均可提出请求确认无效之诉，法院应当依法受理。

第 22 条第 2 款的规定，股东会或者股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行

政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议做出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

三、董事会

（一）董事会的概念

董事会是由股东会选举产生的，由全体董事组成的行使经营决策和管理权的公司必设的集体业务执行机关。

董事会是公司的业务执行机关，其权限通常应以会议之形式行使，是公司经营决策的领导机关和公司的法定常设机关

（二）董事会的职权

董事会作为公司的业务执行和经营管理机构，拥有对内的经营管理权和对外的业务代表权。

（三）董事会的产生和组成

在公司成立后，董事一般应由股东会选任，董事会由符合条件的董事组成。

根据我国《公司法》规定，股份有限公司的董事会由 5-19 人组成；有限责任公司的董事会由 3-13 人组成，但股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。

（四）董事会会议

1. 董事会会议的种类

与股东会会议的分类相一致，董事会会议亦可分为普通会议和特别会议。

我国《公司法》第 110 条第 1 款规定：“董事会每年度至少召开两次会议。”

2. 董事会会议的召集

我国《公司法》规定董事会会议由董事长负责召集并主持，如果董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事推举一名董事召集和主持。

3. 董事会会议的决议

董事会决议的表决实行一人一票制。

股份有限公司的董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。

有限责任公司董事会的议事方式和表决程序可由公司章程规定。

4. 董事会决议的无效与撤销

根据《公司法》第 22 条第 1 款的规定，董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。

5. 董事会会议记录

董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。

（五）董事的义务和责任

1. 董事的义务

按照我国公司法的规定，董事、监事、高级管理人员对公司负有忠实义务和勤勉义务。

2. 董事的责任

（1）董事对公司的责任。董事（包括监事、高级管理人员）执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

（2）董事对股东的责任。董事（包括高级管理人员）违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

四、监事会

（一）监事会的概念

监事会是公司的业务活动进行监督和检查的公司常设机构。

有限责任公司设监事会，其成员不得少于 3 人。股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设 1-2 名监事，不设监事会。股份有限公司设监事会，其成员不得少于 3 人。

（二）监事会的职权

监事会作为公司的法定监督机构，其职权主要包括：

（1）检查公司的财务；

（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（4）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行法定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（5）向股东会会议提出提案；

（6）依法对董事、高级管理人员提起诉讼；

（7）公司章程规定的其他职权。

（三）监事会的组成

我国公司的监督机构原则上采取委员会制，规定监事会的人数不得少于 3 人。

但股东人数较少和规模较小的有限责任公司可不采取委员会制，可仅设 1-2 名监事。监

事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于 $\frac{1}{3}$ ，具体比例由公司章程规定。

（四）监事的任免

监事会中的股东代表，由股东会选举产生，职工代表则由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事的任职资格与董事、经理的任职资格相同。

（五）监事的任期

我国《公司法》规定，监事的任期与董事相同，每届任期为 3 年，可以连选连任。

（六）监事的义务与责任

监事与董事、高级管理人员一样，依法对公司负有忠实义务和勤勉义务。疏于履行职责而给公司造成损害的，应对公司承担赔偿责任。

五、经理

（一）经理的概念和职权

经理，又称经理人，是指由董事会做出决议聘任的主持日常经营工作的公司负责人。

经理从属于董事会，职权范围来自董事会的授权，只能在董事会或董事长授权的范围内对外代表公司。我国《公司法》规定，有限责任公司可以设经理，股份有限公司设经理，均由董事会聘任或者解聘。

（二）经理的选任与解聘

经理的选任和解聘均由董事会决定。董事会根据经理的表现，可决定续聘或解聘，并决定经理的报酬事项。

（三）经理的义务与责任

经理作为基于委任关系而产生的公司代理人，依法对公司负有忠实义务和勤勉义务。经理违反法律、行政法规或者公司章程规定的义务，使公司遭受损失的或损害股东利益的，应对公司或股东负赔偿责任。讲解归纳与举例

【多选题】我国的公司组织机构包括

- A.股东会 B.董事会
- C.监事会 D.经理
- E.法人

【答案】ABCD

【解析】我国公司法规定的公司组织机构主要是股东会、董事会、监事会和公司经理。

第 5 节 公司的合并与分立

一、公司的合并

（一）公司合并的概念与形式

公司合并,是指两个或两个以上的公司依照法定程序归并为其中的一个公司或创设另一个新的公司的法律行为。

公司合并的法定形式有吸收合并和新设合并两种。

吸收合并是指两个或两个以上的公司合并后,其中有一个公司(吸收方)存续,而其余公司(被吸收方)均归消灭的法律行为。 $A+B=A$

新设合并又称创设合并,是指两个或两个以上的公司合并后,参与合并的公司均归于消灭,在此基础上另行成立一个新的公司的法律行为。 $A+B=C$

（二）公司合并的程序

- 1.签订合并协议
- 2.通过合并决议
- 3.编制资产负债表和财产清单
- 4.通知和公告债权人
- 5.办理合并登记

（三）公司合并的法律效果

公司合并的法律效果体现在以下三个方面:

一是公司的消灭、变更和新设。

二是权利义务的概括移转。

三是股东资格的当然承继。

二、公司的分立

（一）公司分立的概念与形式

公司的分立,是指一个公司依法定程序分为两个或两个以上公司的法律行为。公司的分立分为新设分立和派生分立两种。

新设分立又称分解分立,是指将一个公司的资产进行分割,然后分别设立两个或两个以上的公司,原公司因此而消灭。 $A=B+C$

派生分立又称存续分立或分拆分立,是指在不消灭原公司的基础上,将原公司资产分出一部分或若干部分而再成立一个或数个公司的行为。 $A=A+B$

（四）公司分立的程序

- 1.股东会决议

2.通知和公告债权人

3.由分立后的各公司代表签署内部分立协议

4.编制资产负债表及财产清单

5.申请登记

（五）公司分立的法律效果

公司分立引起公司的变更、解散和新设。

对进行分立的公司本身而言，分立可能导致其解散或资本和股东的变更。

对于股东而言，分立引起其与原公司关系及其股权的数量和结构等的变化。对债权人而言，分立引起债务人主体的变化。

若分立过程中财产分割不公或以分立作为逃避债务的手段，股东、债权人可以采取必要的司法救济。

讲解归纳与举例

【简答题】简述公司合并与分立的形式

【参考答案】公司合并的法定形式有吸收合并和新设合并两种。公司的分立分为新设分立和派生分立两种

第6节 公司的解散与清算

一、公司的解散

（一）公司解散的概念

公司解散，可以定义为公司因法律或章程规定的解散事由出现而停止营业活动并逐渐终止其法人资格的行为，它是公司主体资格消灭的必经程序。

（二）公司解散的原因

公司解散可以分为自愿解散和被迫解散两类。

公司自愿解散的原因包括：（1）公司存续期间届满或章程规定的其他解散事由发生；（2）公司权力机关决定解散；（3）因公司合并、分立而解散。

导致公司被迫解散的情形包括：（1）法院判决解散；（2）主管机关命令解散。

（三）公司解散的登记和效力

公司解散时，除因破产和合并而解散外，应在法定期限内向公司所在地登记机关办理解散登记。经核准登记后，还应在公司所在地公告。

二、公司的清算

（一）公司清算的含义

公司清算，是指公司解散后，处分其财产，终结其法律关系，从而消灭公司法人资格的法律程序。

（二）公司清算的种类

1.根据清算是否在破产情形下进行，可以将清算分为破产清算和非破产清算

破产清算，是指公司不能清偿到期债务被依法宣告破产时，由法院组织清算组对公司资产进行清理，并将破产财产公平地分配给债权人，并最终消灭公司法人资格的程序。破产清算始终在法院的严格监督下进行。

非破产清算，是指公司资产足以清偿全部债务的情况下进行的清算，包括自愿解散的清算和强制解散的清算，此种清算的财产除用以清偿公司的全部债务外，还要将剩余财产分配给公司的股东。

2.根据清算是依公司自行确定的程序还是依照法定程序进行，可以将清算分为任意清算和法定清算。

任意清算，是指在公司自愿解散的情况下，依公司章程的规定或全体股东同意的清算方法，处分公司财产。法定清算，是指公司依照法律规定的程序进行的清算。

3.依照清算是否受到法律或行政机关的干预，法定清算又可以分为普通清算和特别清算。

普通清算，是指由公司自行依法组织的清算组按法定程序所进行的清算。

特别清算，是指当解散的公司实行普通清算有显著困难时，由法院或行政机关命令组织清算组并加以监督所进行的清算。

（三）清算中公司的机关

在普通清算时，公司的董事一般担任清算人。此外，清算期间公司股东会和监事会仍然存在，可以行使原有的职权，但以清算事务为限。公司在清算期间开展与清算无关的经营活动的，由公司登记机关予以警告，没收违法所得。

（四）清算人

1.清算人的选任（1）由法律规定（2）由股东选任（3）由法院指定

2.清算人的解任

解任的方式有两种：一是由股东会解任。股东选任的清算人，股东可以决议将其解任。但法院选任的清算人，股东会无权将其解任。

二是由法院依利害关系人申请将清算人解任。人民法院可以根据债权人、股东的申请，或者依职权更换清算组成员。

3.清算人的职权

清算人作为清算中公司的机关，在执行清算事务范围内，相当于董事的地位，享有与董事同等的权利和义务。

4.清算人的义务

清算人作为清算中公司的机关，对公司负有忠实和勤勉的义务，履行职务必须遵守法律、法规和公司章程的规定及股东会的决议。

（五）清算程序

公司清算一般需经过下列程序：

- （1）组织清算组。
- （2）公告和通知债权人，催报债权。
- （3）清理公司财产、编制资产负债表和财产清单，制定清算方案。
- （4）收取债权，清偿债务。清偿公司债务须按下列顺序进行：支付清算费用→支付职工工资和劳动保险费用→缴纳所欠税款→清偿公司其他债务。
- （5）分配剩余财产。在清偿公司债务后仍有剩余财产的，要按照股东的出资比例或持股比例分配给公司股东。
- （6）清算完结。公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会、股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

讲解归纳与举例

【名词解释题】破产清算

【参考答案】破产清算，是指公司不能清偿到期债务被依法宣告破产时，由法院组织清算组对公司资产进行清理，并将破产财产公平地分配给债权人，并最终消灭公司法人资格的程序。破产清算始终在法院的严格监督下进行。

第5章 非公司企业法

本章重难点分析

- 1.了解并掌握个人独资企业的概念、特征与治理结构
- 2.了解并掌握合伙企业的概念与分类、变更、解散与清算
- 3.了解其他非公司企业法

第1节 个人独资企业法

一、个人独资企业的概念与特征

（一）个人独资企业的概念

个人独资企业，也称独资企业、单一业主制企业，或独资商号、独资所有制、单人公司、

个体企业等，是指由一个自然人投资，财产为投资者个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。

（二）个人独资企业的特征

- 1.我国的个人独资企业的投资主体只能是一个自然人
- 2.个人独资企业不具有法人资格
- 3.投资人对企业的财产依法享有所有权和经营管理权
- 4.投资人以其个人财产对企业的债务承担无限责任

二、个人独资企业的设立制度

（一）个人独资企业的设立条件

个人独资企业的设立是指个人独资企业投资人依照法律规定的条件和程序，创设个人独资企业的过程。根据我国《个人独资企业法》第 8 条的规定，设立个人独资企业必须具备以下条件：

- 1.投资人为一个自然人
- 2.有合法的企业名称
- 3.有投资人申报的出资
- 4.有固定的生产经营场所和必要的生产经营条件
- 5.有必要的从业人员

（二）个人独资企业的设立程序

1.设立申请

设立个人独资企业，申请人是企业投资人，投资人也可以委托其代理人向个人独资企业所在地的登记机关申请设立登记。投资人申请设立个人独资企业，应当向登记机关提交法律规定的相关文件。

2.审查登记

登记机关应在收到投资人或其委托代理人的设立申请之日起 15 日内，根据《个人独资企业法》的规定进行审查，对符合登记条件的，予以登记，发给营业执照；对不符合登记条件的，不予登记，并应当给予书面答复，说明理由。个人独资企业营业执照的签发日期，为个人独资企业的成立日期。

（三）个人独资企业分支机构的设立

个人独资企业的分支机构是指企业在住所地以外设立的从事业务活动的办事机构。

个人独资企业分支机构经核准登记后，应将登记情况报该分支机构所属个人独资企业的

原登记机关备案。分支机构的民事责任，由设立该分支机构的个人独资企业承担。

三、个人独资企业的治理结构

（一）业主的权利和义务

个人独资企业的业主即个人独资企业的投资人，对企业的财产和经营管理享有绝对的权利，并承担相应的义务、责任。

权利：（1）业主对企业财产享有所有权。（2）业主的有关权利可以依法进行转让或继承。

（3）业主对个人独资企业的生产经营活动享有完全的决策权、管理权和监督权。（4）若委托或者聘用人员管理企业事务，业主对受托人或被聘用人员管理个人独资企业事务的行为有监督权，若发现受托人或者被聘用人员违反合同或有其他不法行为时，可撤销委托或解除聘用关系。（5）业主有扩大企业经营规模，设置分支机构的权利

义务：（1）业主应依法纳税。（2）业主以个人财产对个人独资企业债务承担无限责任。

（二）个人独资企业的权利、义务

根据《个人独资企业法》和有关法律、行政法规的规定，个人独资企业的权利主要体现在以下四个方面：（1）依法取得贷款。（2）依法取得土地使用权。（3）拒绝摊派权。（4）法律、行政法规规定的其他权利。

个人独资企业的义务主要有：（1）依法开展经营活动，不得从事法律禁止从事的业务。

（2）依法建立财务会计制度。（3）依法维护职工利益，做好环境保护工作。

（三）个人独资企业的事务管理

根据我国《个人独资企业法》，个人独资企业的管理模式主要有自行管理、委托管理和聘任管理三种。自行管理，即由个人独资企业投资人本人对企业的经营事务直接进行管理。

委托管理，须由投资人与受托人签订书面合同，明确委托的具体内容和授予的权利范围。聘任管理，由投资人聘任其他具有民事行为能力的人负责企业的事务管理。

四、个人独资企业的解散与清算

（一）个人独资企业的解散

个人独资企业的解散是指独资企业因出现某些法定事由导致其民事主体资格消失。根据《个人独资企业法》，个人独资企业有下列情形之一的，应当解散：

（1）投资人决定解散。

（2）投资人死亡或者被宣告死亡，无继承人或者继承人决定放弃继承。

（3）被依法吊销营业执照。

（4）法律、行政法规规定的其他解散情形。

解散后 5 年内，债权人未提出偿债请求的，投资人的清偿责任消灭

（二）个人独资企业的清算

个人独资企业的清算是指出现个人独资企业解散的事实后，处理解散企业未了结的法律关系的程序。清算程序：

- （1）确定清算人或者成立清算组。
- （2）通知或公告。投资人自行清算的，应当在清算前 15 日内书面通知债权人，无法通知的，应当予以公告。
- （3）登记债权。
- （4）投资人或者人民法院指定的清算人清理企业财产，编制财务清单，清理企业债权债务。
- （5）按照法律规定的程序清偿企业债务。
- （6）投资人取回剩余财产。
- （7）注销登记。

讲解归纳与举例

【单选题】甲出资设立一个花店（个人独资企业），花店成立后聘用了秦某做店长负责花店的事务管理，花店约定秦某仅在 50 万元的交易额范围内代表花店”订合同。后秦某未经甲同意与乙签订了 80 万元的订货合同，并以该花店的店面设定抵押。后花店无力清偿乙的货款，以下说法正确的是

- A.该抵押行为有效
- B.该订货合同无效
- C.甲可以因秦某行为解聘秦某
- D.乙对店面的变现财产主张优先受偿，甲无权拒绝

【答案】C

【解析】秦某违反了甲的权限约定，甲有权解聘秦某。

第 2 节 合伙企业法

一、合伙企业的概念与分类

（一）合伙企业的概念

根据我国《合伙企业法》第 2 条的规定，合伙企业是指自然人、法人和其他组织依照合伙企业法在中国境内设立的普通合伙企业和有限合伙企业。

普通合伙企业由普通合伙人组成，有限合伙企业则由普通合伙人和有限合伙人组成。

（二）合伙企业的分类

1.普通合伙企业和有限合伙企业

普通合伙企业，是指由普通合伙人组成，合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任的合伙企业。人合性最强。

有限合伙企业，是指由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人则以其出资额为限对合伙企业承担有限责任。

2.一般普通合伙和特殊普通合伙

一般普通合伙，是指由 2 个以上的普通合伙人订立合伙协议，各合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任的合伙企业。

特殊普通合伙，是指以专业知识和专门技能为客户提供有偿服务，部分合伙人对合伙企业债务承担无限责任或无限连带责任，部分合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任的专业服务机构。

二、合伙企业的设立制度

（一）合伙企业的设立条件

1.普通合伙企业的设立条件

根据我国《合伙企业法》的规定，普通合伙企业的设立条件包括：（1）有 2 个以上合伙人；（2）有书面合伙协议；（3）有合伙人认缴或者实际缴付的出资；（4）有合伙企业的名称和生产经营场所；（5）法律、行政法规规定的其他条件。

2.有限合伙企业的设立条件

- （1）合伙人的特殊规定。由 2 个以上 50 个以下合伙人设立，至少应当有 1 个普通合伙人
- （2）合伙企业名称的特殊规定。企业名称中应当标明“有限合伙”字样。

（二）合伙企业的设立程序

1.申请

设立合伙企业，应当由合伙人向企业登记机关提出设立合伙企业的申请。合伙人在申请设立合伙企业时，应当向企业登记机关提交登记申请书、合伙协议书、合伙人身份证明等文件。

2.审批

3.登记

登记机关应当自收到申请登记文件之日起 20 日内做出是否登记的决定

三、合伙企业的治理结构

（一）合伙人的权利和义务

1.合伙人的权利

(1) 对合伙企业财产所享有的权利。(2) 合伙企业经营效益好,需扩大投资规模时,合伙人有权优先投资;合伙人经全体合伙人同意对外转让其财产份额时,在同等条件下,其他合伙人有优先受让权。(3) 经营管理权。(4) 监督检查权。(5) 获得补偿的权利。

2.合伙人的义务

(1) 缴纳出资的义务;(2) 诚实合作,勤勉敬业的义务;(3) 竞业禁止义务。

(二) 合伙企业事务的执行

1.合伙企业事务执行人

按照合伙协议的约定或者经全体合伙人决定,可以委托一个或者数个合伙人对外代表合伙企业,执行合伙企业事务。作为合伙人的法人、其他组织执行合伙事务的,由其委派的代表执行。

2.合伙企业事务执行的形式

- (1) 全体合伙人共同执行合伙企业事务。
- (2) 委托一名或者数名合伙人执行合伙企业事务。
- (3) 合伙人分别执行合伙企业事务。
- (4) 聘任合伙人以外的人执行合伙企业事务。

3.合伙企业事务执行的规则

(1) 合伙人对合伙企业有关事项做出决议,按照合伙协议约定的表决办法办理。合伙协议未约定或者约定不明确的,实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。法律对合伙企业的表决办法另有规定的,从其规定。

(2) 必须经全体合伙人同意的合伙企业事务。

(三) 合伙企业事务执行的后果

(1) 由一个或者数个合伙人执行合伙企业事务的,执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况,其执行合伙企业事务所产生的收益归合伙企业,所产生的费用和亏损由合伙企业承担。

(2) 合伙人分别执行合伙事务的,执行事务合伙人可以对其他合伙人执行的事务提出异议。

(3) 受委托执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的,其他合伙人可以决定撤销该委托。

(4) 被聘任的合伙企业的经营管理人员应当在合伙企业授权范围内履行职务。

四、合伙企业的财产与责任承担

（一）合伙企业的财产构成

我国《合伙企业法》第 20 条规定：“合伙人的出资、以合伙企业名义取得的收益和依法取得的其他财产，均为合伙企业的财产。”

1.合伙人的出资

2.合伙企业的收益

（二）合伙人财产份额的转让

1.份额转让

普通合伙人：内部转让-通知；外部转让-须经其他合伙人一致同意，在同等条件下，其他合伙人有优先购买权，合伙协议另有约定的除外

有限合伙人：内部转让-自由；外部转让：提前 30 天通知，其他合伙人无优先购买权 2. 份额出质

普通合伙人：须经其他合伙人一致同意；未经其他合伙人一致同意，其行为无效，由此给善意第三人造成损失的，由行为人依法承担赔偿责任。

有限合伙人：将其财产份额出质，另有约定的除外。

（三）合伙企业的责任承担

1.合伙企业的利润分配和亏损分担

合伙企业的利润分配和亏损分担，按照合伙协议的约定办理；合伙协议未约定或者约定不明确的，由合伙人协商决定；协商不成的，由合伙人按照实缴出资比例分配、分担；无法确定出资比例的，由合伙人平均分配、分担。

2.合伙企业债务承担中的具体责任

（1）合伙企业的财产责任：应当以其营业的所有财产，对外承担清偿责任。

（2）普通合伙人的无限连带责任：清偿额超过其亏损分担比例的，有权向其他合伙人追偿。

（3）特殊的普通合伙人的责任

一个合伙人或者数个合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成合伙企业债务的，应当承担无限责任或者无限连带责任，其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任。

（4）有限合伙人的责任

有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。五、合伙企业的变更、解散与清算

（一）合伙企业的变更

合伙企业的变更是指合伙企业由于登记事项发生变化而进行的变更，主要包括合伙人、

合伙协议及合伙企业名称、经营场所等登记事项的变更。

合伙人的入伙和退伙是最为重要的变更类型。

入伙是指在合伙企业存续期间，合伙人以外的第三人加入合伙企业并取得合伙人资格的行为。

退伙，是指原合伙人依法退出合伙企业，从而丧失合伙企业合伙人资格的事实。声明退伙和法定退伙

（二）合伙企业的解散

合伙企业的解散，是指根据合伙协议的约定或法律的规定，结束合伙协议关系，终止合伙企业的行为。（1）合伙协议约定的经营期限届满，合伙人决定不再经营；（2）合伙协议约定的解散事由出现；（3）全体合伙人决定解散；（4）合伙人已不具备法定人数满 30 天；（5）合伙协议约定的合伙目的已经实现或无法实现；（6）被依法吊销营业执照、责令关闭或者撤销；（7）出现法律、行政法规规定的其他原因。

（三）合伙企业的清算

合伙企业的清算，是指在合伙企业解散后，为了终止合伙企业的法律关系，依法确定清算人，了结合伙事务，清理债权债务，分配剩余财产，终止合伙关系的程序。

1.确定清算人

2.通知和公告：清算人自被确定之日起 10 日内将合伙企业解散事项通知债权人，并于 60 日内在报纸上公告。

3.执行清算事务

4.清偿合伙企业债务：清偿顺序-（1）清算费用；（2）合伙企业所欠职工工资和社会保险费用；（3）法定补偿金以及所欠税款；（4）其他债务。

5.编制清算报告

6.注销登记

讲解归纳与举例

【单选题】合钢工作室（有限合伙企业）由 30 位合伙人出资设立，其中甲是唯一的普通合伙人。全体合伙人协商一致同意合伙人乙在以其在工作室的薪酬作为出资。合钢工作室合伙协议虽经全体合伙人签章但并未登记。合伙人丙在没有通知其他合伙人的情况下，私自将其所持合伙份额转让不知情的鲁拉；合伙人丁擅自将所持合伙份额出质给第三人元德。以下说法正确的是？

- A.乙的出资合法有效
- B.合钢工作室的合伙协议已经生效
- C.因未提前 30 天通知其他合伙人，丙将合伙份额转让的行为无效
- D.丁将合伙份额出质的行为没有得到全体合伙人一致同意无效

【答案】B

【解析】合伙协议经全体合伙人签名、盖章后生效，登记只是对抗效力。

第 3 节 其他非公司企业法

一、国有企业法

国有企业法是规范国有企业的设立、法律地位、组织形式及治理结构及其与政府关系等方面的法律规范的总称。

目前我国的国有企业法除宪法性规范外，主要包括《全民所有制工业企业法》《全民所有制工业企业转换经营机制条例》《国有企业监事会暂行条例》《全民所有制工业企业厂长工作条例》《全民所有制工业企业职工代表大会条例》《全民所有制工业企业承包经营责任制暂行条例》《全民所有制小型工业企业租赁经营暂行条例》《企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》以及其他涉及国有企业运营和资产管理的法规和规章。

（一）国有企业的概念及特征

国有企业是指企业财产权属于国家所有或者由国家依法设立的，具有独立经营权的企业法人。具有以下法律特征：

- 1.国有企业属于国家所有或者由国家依法投资设立。
- 2.国有企业具有独立的法人地位。
- 3.国有企业在经营管理中实行所有权和经营权分离。

（二）国有企业的种类及相关概念

1.国有商业企业和国有公益企业

国有商业企业是指按照市场化要求实行商业化运作，以增强国有经济活力、放大国有资本功能、实现国有资产保值增值为主要目标，依法自主自主开展生产经营活动的国有企业。

国有公益企业是指以保障民生、服务社会、提供公共产品和服务为主要目标，引入市场机制，依法自主自主开展生产经营活动的国有企业。

2.国家出资企业、国家控股企业和国家参股企业

国家出资企业，是指国家出资的国有独资企业、国有独资公司以及国有资本控股公司、国有资本参股公司。

国家控股企业是指在企业的全部资本中，国家资本股本占较高比例，并且由国家实际控制的企业。包括绝对控股和相对控股。绝对控股企业是指国家资本比例大于 50%（含 50%）的企业；相对控股企业是指国家资本虽然比例不足 50%，但相对高于企业中的其他经济成分所占比例（相对控股），或者虽不大于其他经济成分，但根据协议规定，由国家拥有实际控制权的企业（协议控制）。

国家参股企业是指虽有国家出资，但达不到国家控股要求的企业。

（三）国有企业的法人治理结构

1. 国有企业的决策与管理制度

主要实行厂长（经理）负责制与董事会制度。

2. 国有企业的监督制度

国有企业的监督制度主要包括内部监督和外部监督。

3. 国有企业的民主管理制度

国有企业必须实行民主管理制度，职工代表大会是企业实行民主管理的基本形式，是职工行使民主管理权力的机构。

二、外商投资企业法

（一）外商投资与外商投资企业

外商投资，是指外国的自然人、企业或者其他组织（以下简称“外国投资者”）直接或者间接在中国境内进行的投资活动

（二）负面清单管理制度

负面清单，是指国家规定在特定领域对外商投资实施的准入特别管理措施。负面清单规定禁止投资的领域，外国投资者不得投资。

（三）外商投资企业的组织形式与投资权益

外商投资企业的组织形式、组织机构及其活动准则，适用《公司法》《合伙企业法》等法律的规定。

三、合作社法

（一）农民专业合作社的概念及特征

农民专业合作社，是指在农村家庭承包经营基础上，农产品的生产经营者或者农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。农民专业合作社有以下特征：

1. 农民专业合作社的成员以农民为主体，并以服务成员为宗旨，谋求全体成员的共同利益。

- 2.合作社成员入社自愿、退社自由，地位平等，并实行民主管理。
- 3.合作社盈余主要按照成员与农民专业合作社的交易量（额）比例返还。
- 4.具有法人资格。
- 5.可以依法自愿设立或者加入农民专业合作社联合社。

（二）农民专业合作社的设立

1.设立条件

设立农民专业合作社，应当具备下列条件：（1）有 5 名以上法律规定的成员；（2）有符合法律规定的章程；（3）有符合法律规定的组织机构；（4）有符合法律、行政法规规定的名称和章程确定的住所；（5）有符合章程规定的成员出资。

2.出资形式

农民专业合作社的成员可以以货币出资，也可以以实物、知识产权、土地经营权、林权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产，以及章程规定的其他方式作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。

3.设立程序

设立农民专业合作社，须有申请、审查登记程序。

4.转投资

可以依法向公司等企业投资，以其出资额为限对所投资企业承担责任。

（三）农民专业合作社的治理结构

1.成员大会：权力机构

2.理事会和监事会

（四）农民专业合作社的合并、分立、解散和清算

农民专业合作社应自合并决议做出之日起 10 日内通知债权人。

农民专业合作社因下列原因解散：（1）章程规定的解散事由出现；（2）成员大会决议解散；（3）因合并或者分立需要解散；（4）依法被吊销营业执照或者被撤销。

合作社在解散时，应当依法成立清算组。

（五）农民专业合作社联合社

3 个以上农民专业合作社在自愿的基础上，可以出资设立农民专业合作社联合社。农民专业合作社联合社应当有自己的名称、组织机构和住所

第 6 章 商业银行法与支付法

本章重难点分析

- 1.了解并掌握商业银行法的设立、变更、业务和风险管理制度
- 2.了解并区分商业支付的不同种类
- 3.了解票据的种类与应用

第1节 商业银行法

一、商业银行法概述

（一）商业银行的概念与特征

商业银行是我国最为重要的金融机构。

商业银行，是指依照《商业银行法》和《公司法》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。

商业银行具有以下特点：

第一，商业银行是以利润最大化为经营目的的商事企业。

第二，商业银行是从事商业性信用货币业务的金融机构。

第三，商业银行是以从事存贷款等金融业务为基础性业务并以存贷款之间的利差作为主要利润来源的金融机构，属于储蓄银行而非投资银行。

（二）商业银行的主要职能

1.信用中介职能

信用中介职能是指银行通过其负债业务，把社会上的各种闲散货币资金集中到银行里来，再通过资产业务把它投向经济各部门。它是商业银行的最基本职能。

2.支付中介职能

支付中介职能是指商业银行利用其技术、网络、资源为客户代理收付、汇兑、转账等资金转移的功能。

3.信用创造职能

信用创造职能指的是存款货币的创造，即存款货币的派生能力，是商业银行在信用中介职能和支付中介职能的基础上产生的一种派生职能。

4.金融服务职能

金融服务职能是商业银行充当客户财务顾问，提供各种商情咨询、征信服务的职能。

5.经济调节职能

调节经济是指商业银行通过其信用中介活动，调剂社会各部门的资金短缺，同时在人民银行货币政策和其他国家宏观政策的指引下，实现对经济结构、消费比例投资、产业结构等方面的调整。

（三）商业银行法的概念和性质

商业银行法，是调整商业银行设立、变更、终止及开展业务活动中发生的各种社会关系的法律规范的总称。

商业银行法的调整对象，主要有以下三类经济关系：

第一，商事组织关系，即商业银行在设立、变更、终止和运营过程中所发生的组织关系；

第二，商事经营关系，即商业银行在经营过程中与其他市场主体之间发生的以货币信用为基础的商事交易和服务关系；

第三，监督管理关系，即商业银行在组织运营过程中发生的政府和商业银行之间的监督管理关系。

商业银行法在一定程度上体现了公权力的干预，具有一定的经济法色彩和综合法的属性，但其主要调整的是商业银行与其他市场主体之间的商事关系，遵循的是平等、自愿、等价有偿和诚实信用等私法基本原则，因此其本质上仍然属于私法，是商法体系的有机组成部分，具有商事组织法和商事行为法的双重特征。

二、商业银行的设立、变更、接管和终止

（一）商业银行的设立

商业银行的设立是指商业银行发起人依照法律规定的条件和程序，通过筹建商业银行并使商业银行取得法律关系主体资格的法律行为。

1. 设立条件

根据《商业银行法》相关条款规定，设立商业银行应具备以下条件：

（1）有符合《商业银行法》和《公司法》规定的章程。

（2）有符合《商业银行法》规定的最低限额以上的注册资本。

全国性商业银行：10 亿元；

城市商业银行：1 亿元；

农村商业银行：5000 万元。

（3）有具备任职专业知识和业务工作经验的董事、高级管理人员。

（4）有健全的组织机构和管理制度。

（5）有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施。

2. 设立程序

我国对商业银行的设立实行核准制，由中国银行保险监督管理委员会审批并颁发经营许可证，具体程序包括申请、审批、登记、公告四个环节。

（二）商业银行的变更

商业银行的变更是指商业银行的组织或重大事项的改变，包括主体变更和事项变更。主体变更主要指商业银行的合并和分立；

事项变更主要涉及银行名称、注册资本、住所、业务范围、股权结构及章程修改等的变更。

（三）商业银行的接管

商业银行的接管，是指国务院银行业监督管理机构通过一定的接管组织，按照法定的条件和程序，全面控制和管理商业银行业务活动的行为。

（四）商业银行的终止

商业银行的终止，是指因商业银行出现解散、被撤销和被宣告破产等法律规定的情形，消灭其主体资格的法律行为，其实质是商业银行从金融市场的退出。

商业银行的终止事由包括解散、被撤销以及被宣告破产三种情形，且均须履行必要的清算程序。商业银行不得自行决定终止，须事先取得银行业监督管理机构的批准。

三、商业银行业务与经营原则

（一）商业银行的业务概述

商业银行的传统业务可以概括为负债业务、资产业务和中间业务。

负债业务是商业银行资产业务和中间业务的基础，由资本金、借款和吸收存款等构成。

资产业务是商业银行取得收益的主要途径，包括发放贷款、进行投资、买卖外汇、票据贴现等。

中间业务则是指不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入的业务，如担保、承兑、信用证等担保类业务，贷款承诺等承诺类业务，以及支付结算、代理服务金融等服务类业务。

《商业银行法》该法第 43 条规定，商业银行不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，但国家另有规定的除外。

（二）商业银行的经营原则

《商业银行法》第 4 条规定：“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则。”

（三）商业银行的存款业务制度

1. 存款业务制度概述

存款业务，是指商业银行等依法具有存款业务资格的金融机构接受客户存入资金，存款人可以随时或按约定时间支取本金和利息的一种信用业务。

根据存款主体的不同，可将存款分为单位存款和个人储蓄存款；

根据存款的期限和提取方式的不同，可将存款分为活期存款和定期存款；根据存款币种的不同，可将存款分为人民币存款和外汇存款；

根据存款支取方式的不同，可将存款分为支票存款、存单（折）存款、通知存款、协定存款等。

2. 储蓄存款业务制度

储蓄存款是指个人将其所有或者合法持有的人民币或外币，自愿存入中国境内储蓄机构的存款，是居民个人与银行之间发生的一种债权债务关系。

商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。

3. 单位存款业务制度

单位存款，又称机构存款，是指个人储蓄存款之外的所有存款，是企业、事业、机关和社会团体等单位在金融机构办理的人民币存款，包括财政性存款和商业性存款。财政性存款由中国人民银行专营。

（四）商业银行的贷款业务制度

1. 贷款业务概述

贷款是商业银行依法将货币资金按一定的利率贷给客户并约定期限偿还的一种信用活动，反映的是商业银行与借款人之间的债权债务关系。

按照贷款期限的不同，可以分为贷款期限在 1 年以下的短期贷款、在 1 年以上 5 年以下的中期贷款和 5 年以上的长期贷款

按照贷款人是否承担风险，可分为自营贷款和委托贷款

按贷款有无担保，可分为信用贷款、担保贷款和贴现贷款

2. 商业银行经营贷款业务的基本原则

第一，合法原则

第二，自主经营原则

第三，安全性、流动性、效益性相统一的原则

第四，公平竞争原则

第五，有担保原则

3. 商业银行贷款业务及其限制禁止从事下列行为：

第一，违反资产负债比例监管规定发放贷款。

第二，向关系人发放信用贷款或以优于其他借款人同类贷款的条件向关系人发放贷款。此处的关系人包括：商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属；上述人员投资或担任高级管理职务的公司、企业或者其他经济组织。

第三，向不具备法定贷款资格和条件或生产、经营、投资国家明文禁止的产品、建设项目或生产经营、投资项目未取得批准文件或环境保护部门许可及有其他严重违法行为的借款人发放贷款。

第四，未经中国人民银行批准，对自然人发放外币币种的贷款。

第五，给委托人垫付资金，但国家另有规定的除外。

第六，提供无担保的信用贷款，但经商业银行严格审查，确认借款人资信良好，确有偿还能力的除外。

（五）商业银行结算业务与其他业务法律制度

1. 商业银行结算业务

商业银行结算业务即转账结算业务，是指通过银行账户的资金转移实现债权债务清结的行为，是以信用收付代替现金收付的业务。

结算业务与存款业务、贷款业务并列，构成商业银行的三大核心业务。

目前的结算形式主要有银行汇票、商业汇票、银行本票、支票、汇兑、委托收款和异地托收承付以及信用卡等方式。

2. 同业拆借与票据贴现业务

同业拆借是指为解决短期资金流动性需要，商业银行、非银行金融机构同业之间相互融通短期资金的活动，其实质是金融机构之间依法发生的借贷关系。

我国商业银行间同业拆借由中国人民银行统一负责管理、组织、监督和稽核。

商业银行用于拆出的资金只限于缴足准备金、留足备付金、归还中国人民银行到期贷款之后的闲置资金，拆入的资金只能用于弥补票据清算、先支后收等临时性资金周转的需要。

国家严禁非金融机构和个人参与同业拆借活动。

票据贴现，是指票据持有人在票据未到期之前向银行贴付一定利息而发生的票据转让行为，体现的是贴现银行对贴现申请人的授信行为，即由贷款人以购买借款人未到期的票据的方式放贷。

票据贴现可以分为贴现、转贴现和再贴现三种。

3. 商业银行担保、代理、保管及投融资

商业银行担保业务，是指商业银行应申请人的请求，以保函或备用信用证形式向债权人

或受益人承诺，当债务人未按有关合同偿付债务或履行义务，由银行承担责任，即银行作为保证人担保债务的履行，同时收取相应担保费用的一种金融业务。

保管业务属于银行的传统业务，保管的范围通常包括贵重物品、重要文件或有价证券等。银行的保管服务包括委托代保管服务和出租保管箱服务。

商业银行的投融资业务包括投资业务和融资业务。我国商业银行可购买的有价证券仅局限于政府债券及金融债券，而向其他企业的投资则仅主要局限于银行之间。

商业银行融资业务是指商业银行为解决资金需求而实施的筹措资金的行为。商业银行的融资包括股权融资和债权融资两种类型

四、商业银行的风险管理和内部控制制度

《商业银行法》第 59 条规定：“商业银行应当按照有关规定，制定本行的业务规则，建立、健全本行的风险管理和内部控制制度。”

讲解归纳与举例

【名词解释题】同业拆借

【参考答案】同业拆借是指为解决短期资金流动性需要，商业银行、非银行金融机构同业之间相互融通短期资金的活动，其实质是金融机构之间依法发生的借贷关系。

第 2 节 商事支付法

一、商事支付法概述

（一）商事支付法的界定

我国尚未有专门的商事支付立法，有关规范主要散见于《民法典》《商业银行法》《票据法》《电子签名法》等立法中，或表现为《非金融机构支付服务管理办法》《支付结算办法》《银行卡业务管理办法》等行政法规和部门规章

（二）支付体系与支付方式

支付体系，是指为实现和完成支付活动所制定的一系列法规制度、所建成的基础设施等形成的有机整体，包括传达支付指令的支付工具、支持支付工具运用的支付系统、确保支付活动的法规制度和基础设施安排等，是一国金融市场的基础设施核心，主要由支付服务组织、支付工具、支付系统、支付账户、支付结算管理、支付法规制度等组成。

支付方式是各种交易发生后付款的具体形式。

按照支付媒介载体的不同，可分为现金支付和非现金支付根据是否借助互联网，又有线上支付和线下支付之分。

二、现金支付

现金支付是商事交易最基本的支付手段。

国家鼓励使用非现金支付方式，并对现金支付的使用做出严格控制，对机关、团体、企事业单位、其他经济组织及个体工商户大额现金支付实施备案制度。

三、银行电子支付

中国人民银行按照我国支付清算需要，分别建立了大额支付结算系统、小额支付结算系统和网上支付跨行清算系统以及境内外币支付系统等支付系统，并与各商业银行内部的电子支付系统相连接，实现资金的电子化支付。

四、银行卡支付

（一）银行卡支付概述

银行卡是商业银行或其他金融机构向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的支付工具的统称，主要包括信用卡和借记卡。

（二）银行卡的种类

1.按清偿方式不同分类

按清偿方式不同，银行卡分为信用卡和借记卡。

信用卡，是指商业银行等金融机构依法向资信状况良好的单位和个人签发的，凭以向特约单位购物、消费及存取现金，具有消费信用特征的特制载体卡片，是一种特殊的信用凭证和支付工具。

借记卡是先存款后消费，一般不允许透支。

2.按发卡对象不同分类

按发卡对象不同，银行卡分为单位卡和个人卡。

3.按银行卡使用流通范围分类

按银行卡使用流通范围，银行卡分为国际卡、国内卡以及地区卡。

4.按账户币种不同分类

按照账户币种不同，银行卡可分为人民币卡、外币卡和双币卡。

（三）银行卡的性质与功能

无论借记卡还是信用卡都具有支付功能。

（四）银行卡法律关系

1.发卡机构的权利与义务

发卡机构通常是银行或信用卡公司等金融机构。

2.收单机构的权利与义务

收单机构包括从事银行卡收单业务的银行业金融机构，以及获得银行卡收单业务许可、为特约商户提供银行卡受理并完成资金结算服务的支付机构。

3. 特约商户的权利与义务

特约商户是指提供商品或服务，并与收单机构签订银行卡受理协议、按约定受理银行卡并委托收单机构为其完成交易资金结算的经营机构和个人。

4. 持卡人的权利与义务

持卡人是指银行卡的合法持有人，即与银行卡对应的银行账户的所有人。

（五）银行卡纠纷及其处理

传统的银行卡纠纷的基础事实和诉讼请求相对固定，法律关系比较单一，主要是银行卡合同纠纷，可依据合同法的有关原理或规定进行处理。

新型的银行卡纠纷具有违约责任和侵权责任竞合、纠纷主体多样、法律关系复杂等特点，依据不同情况采取不同的处理方式。

五、商业预付卡与第三方支付

（一）商业预付卡与第三方支付概述

商业预付卡，也可称商事预付卡，是指具有一定资质的商业企业或发卡机构，以磁条卡、芯片卡等特定载体和形式发行，由购卡方预先支付一定款项，持卡人可在特定时间和范围内分次购买商品和服务的权利凭证。

在我国，按发卡人不同，划分为两类：一类是专营发卡机构发行，可跨地区、跨行业、跨法人使用的多用途预付卡；另一类是商事企业发行，只在本企业或同一品牌连锁商业企业购买商品、服务的单用途预付卡。

第三方支付也称非金融支付，是指具备一定实力和信誉保障的独立机构提供与商业银行支付结算系统接口的交易支持平台的网络支付模式。如微信支付、支付宝支付等

（二）商业预付卡支付

商事企业根据自己的经营需要而发行的单用途商事预付卡，因发卡人和商家是同一机构，法律关系相对简单。

对于专营发卡机构以营利为目的发行的、在发行机构之外购买商品或服务的多用途预付卡，因发卡人和商家并非同一人，就会涉及发卡人、持卡人和特约商家（特约商户）三方当事人。其具体法律关系的性质则需要依据当事人的不同而分别加以认定。

（三）第三方支付

1. 第三方支付中的法律关系

在电子商务中，交易双方都要与第三方支付机构发生法律关系。付款方与收款方均与第三方支付机构之间建立了委托付款与委托收款的委托代理关系。

2.对第三方支付机构及其活动的监管

（1）行业准入监管

申请人拟在全国范围内从事支付业务的，其注册资本最低限额为 1 亿元人民币；拟在省（自治区、直辖市）范围内从事支付业务的，其注册资本最低限额为 3000 万元人民币。注册资本最低限额为实缴货币资本。

（2）业务活动监管

支付机构之间的货币资金转移应当委托银行业金融机构办理，不得通过支付机构相互存放货币资金或委托其他支付机构等形式办理。除特别许可外，支付机构不得办理银行业金融机构之间的货币资金转移。

（3）支付机构的民事责任

支付机构与网络用户之间形成了网络服务合同关系，应当确保网络用户个人信息和资金的安全，因自身过错导致用户隐私泄露和账户资产遭受损失的，应当依据《民法典》的有关规定承担赔偿责任。

六、其他方式支付

信用证和票据也是商事交易中较为传统的支付工具。

信用证是指开证银行应申请人的要求并按其指示向第三方开立的载有一定金额的，在一定的期限内凭符合规定的单据付款的书面保证文件，即银行开立的有条件的承诺付款的书面凭证，其主要适用于国际贸易结算。

票据除了具有支付功能外，还具有流通和信用等其他功能。

讲解归纳与举例

【多选题】甲所在单位发放某大型商场购物卡，关于该购物卡的表述正确的是

- A.该购物卡能够商场使用，属于单用途预付卡
- B.该购物卡可在商场使用，说明其可在商场的多个签约商户处使用，属于多用途预付卡
- C.该购物卡属于商业预付卡
- D.该购物卡属于第三方支付
- E.该购物卡的法律关系较为简单

【答案】ACE

【解析】单用途预付卡的发卡人与商家是同一机构，持该卡只在本企业购买商品。

第3节 票据法

一、票据法概述

（一）票据的概念和特征

广义的票据，是指用以证明或以设定权利为目的而制成的各种书面凭证，如股票、债券、本票、提单、车船票、借据等。

狭义的票据，是指出票人依法签发的约定自己或委托他人于到期日无条件按票面金额向收款人或持票人付款的有价证券，包括汇票、本票、支票，是以支付一定金钱为目的的有价证券。

其特征表现在：

1.票据是设权证券；2.票据是金钱债权证券；3.票据是要式证券，即由法律规定；4.票据是一种无因证券，无须说明其取得票据的原因；5.票据是文义证券，权利义务以票据上的文字记载为准。

（二）票据的功能

- 1.汇兑功能是票据最基本、最原始的功能
- 2.票据具有代替现金为支付的功能
- 3.票据还是商业信用工具，具有信用功能
- 4.融资功能

（三）票据法与票据法上的法律关系

广义的票据法，又称实质票据法，指一切有关票据的法律规范；

狭义的票据法则仅指专门规范票据关系的法律规范，又称形式票据法。

票据关系是指由票据法所确认和规范的基于当事人的票据行为而发生的票据权利义务关系。

二、票据基本法律制度

（一）票据行为

1.票据行为的概念和种类

广义上的票据行为，是指以产生、变更或消灭票据权利义务关系为目的的法律行为，包括出票、背书、承兑、保证、保付，以及付款、参加付款、划线、涂销等行为。

狭义上的票据行为，则仅指以发生或转移票据上权利、负担票据上债务为目的的要式法律行为，其以负担票据上的债务为目的。

一般所称的票据行为即狭义的票据行为，只包括出票、背书、承兑、保证、参加承兑、

保付六种。出票，是当事人签发并交付票据的行为，属于基础票据行为，由票据制作和交付两个环节构成。

背书，是指持票人以转让票据权利或将票据权利授予他人为目的，在票据背面或在粘单上记载有关事项并签章的行为。

承兑，是汇票独有的附属票据行为。它是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。保证，是指票据债务人以外的人以担保票据债务的履行为目的而进行的票据行为。它是适用于汇票、本票的附属票据行为。

2. 票据行为的特征

票据行为具有要式性、文义性、无因性、独立性等特点。

（二）票据权利

票据权利是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利，包括付款请求权和追索权。票据权利的取得方式包括原始取得和继受取得两种。

票据权利的行使，主要通过票据的提示承兑、提示付款、行使追索权等程序来实现。票据抗辩可分为物的抗辩和人的抗辩。

基于票据本身存在的事由而发生的抗辩，称为物的抗辩。这一抗辩可以对任何持票人提出，又称绝对抗辩。

人的抗辩，指票据债务人仅可以抵抗特定票据债权人的抗辩。

《票据法》第 17 条规定了持票人的票据权利因时效届满而消灭情形：（1）持票人对出票人和承兑人的权利，自票据到期日起 2 年。见票即付的汇票、本票，自出票日起 2 年。（2）持票人对支票出票人的权利，自出票日起 6 个月。（3）持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起 6 个月。（4）持票人对前手的再追索权，自清偿日或者被提起诉讼之日起 3 个月。

（三）票据的伪造和变造

票据的伪造和变造属于票据瑕疵，直接危及票据权利的安全和票据的使用及流通秩序。票据的伪造，是指无权限人假冒出票人或虚构他人名义进行签章和票据其他记载事项的行为，包括票据本身的伪造和票据上签名的伪造。

票据的变造，是指采用技术手段改变票据上已经记载事项的内容，或增加、减少票据记载事项的内容，从而达到变更票据权利义务关系的目的。

票据上其他记载事项被变造的，在变造之前签章的人，对原记载事项负责；在变造之后签章的人，对变造之后的记载事项负责；不能辨别是在票据被变造之前或者之后签章的，视

同在变造之前签章。

三、汇票

（一）汇票的概念和种类

汇票是出票人签发的，委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

它有出票人、付款人和收款人三方基本当事人，其中出票人和付款人为票据义务人，收款人为票据权利人。

1.根据汇票当事人身份的不同，汇票可以分为银行汇票和商业汇票

2.根据汇票付款期限的不同，可分为即期汇票和远期汇票

3.根据记载到期日方式的不同，远期汇票又可以分为定日付款的汇票、出票后定期付款的汇票、见票后定期付款的汇票

（二）汇票的出票

1.汇票的格式

相对必要记载事项，是指在出票时应当予以记载，但如果未做记载，票据法另有补充规定，汇票并不因此而无效。例如付款日期、付款地、出票地等事项。

任意记载事项，是指法律允许当事人自行选择，不记载不影响票据效力，记载则产生票据效力的事项。例如出票人在票据上记载的禁止背书、委托收款背书、质押背书、现金字样、不得转让等事项。

禁止记载事项，是指法律禁止在票据上记载的事项，又分为记载本身事项无效和因记载使汇票归于无效的事项。前者常见的有“有条件委托”“不确定的金额”等记载内容。后者是一般违反票据法规定的事项。

2.出票的条件

《票据法》第 21 条规定：“汇票的出票人必须与付款人具有真实的委托付款关系，并且具有支付汇票金额的可靠资金来源。不得签发无对价的汇票用以骗取银行或者其他票据当事人的资金。”

3.出票的效力

（1）出票行为对出票人产生担保承兑与担保付款的效力。

（2）出票行为使持票人取得了付款请求权和追索权等汇票上的权利。

（3）出票行为对付款人并不必然产生约束力。

（三）汇票的背书

1.汇票背书的种类

根据背书的目的不同，汇票背书可分为转让背书和非转让背书两种类型。转让背书的目的在于转让票据的权利，通常的背书大都属于转让背书。

禁止转让的背书是一种限制性背书，即背书人在票据上写明“不得转让”字样的背书；

2.汇票背书的格式和内容

第一，背书须由背书人签章并记载背书日期；

第二，背书不得附有条件；

第三，背书人在汇票上记载“不得转让”字样，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担保证责任。

3.背书的连续

以背书转让的汇票，背书应当连续。持票人以背书的连续，证明其汇票权利，即背书连续产生证明效力。

4.背书的效力

对转让背书而言，首先产生权利转移和责任担保的效力，即汇票上的权利因背书而由背书人转移给被背书人；其次，背书人以背书转让汇票后，即承担保证其后手所持汇票承兑和付款的责任。与此同时，背书还具有权利证明的效力，即持票人所持票据的背书如果具有连续性，法律即推定持票人为合法持票人，即可以凭此票据行使票据权利。

（四）汇票的承兑

承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为，为汇票所独有。付款人决定承兑汇票后，就成为票据主债务人，应当依汇票记载的文义承担到期付款的责任。

付款人收到持票人提示承兑的汇票时，应当向持票人签发收到汇票的回单。回单上应当记明汇票提示承兑日期并签章。汇票上未记载承兑日期的，以前述规定期限的最后一日为承兑日期。

（五）汇票的保证

保证是由票据债务人以外的他人充当保证人，担保票据债务履行的票据行为。

保证人为出票人、承兑人保证的，应当将保证事项记载在汇票或者粘单上。保证事项包括表明“保证”的字样、保证人名称和住所、被保证人的名称、保证日期、保证人签章。

（六）汇票的付款

付款程序包括提示付款、汇票支付和收回汇票三个阶段。

（七）汇票的追索权

追索权，是指持票人在汇票到期不获付款或期前不获承兑或其他法定原因发生时，向其前手请求偿还票据金额及其损失的一种票据权利。它是用来弥补付款请求权而设定的第二顺序请求权。

追索权发生应具备以下实质条件之一：第一，汇票到期被拒绝付款；第二，汇票在到期日前被拒绝承兑；第三，在汇票到期日前，承兑人或付款人死亡、逃匿的；第四，在汇票到期日前，承兑人或付款人被依法宣告破产或因违法被责令终止业务活动。

四、本票

（一）本票的概念和特点

本票是出票人签发的、承诺自己在见票时无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据。我国《票据法》仅承认银行本票。

本票的特点是：

- 1.本票属于自付票据，它是由出票人本人对持票人付款，而非委托他人付款
- 2.本票的当事人即出票人和收款人
- 3.本票是自付证券，其出票人始终是主债务人，因此无须承兑。

（二）本票的出票

我国规定本票的出票人仅限于经中国人民银行当地分支机构批准办理银行本票业务的银行机构。

根据《票据法》第 75 条的规定，下列记载事项属于绝对必要记载事项：（1）表明“本票”的字样；（2）无条件支付的承诺；（3）确定的金额；（4）收款人名称；（5）出票日期；（6）出票人签章。本票上未记载上述规定事项之一的，本票无效。

本票出票人一经出票，即成为票据债务人，应负有无条件到期支付票据金额的义务。

（三）本票的付款与见票

本票为见票即付的票据。本票的出票人在持票人于规定的付款期限内提示本票时，必须承担付款的责任。

第一次向出票人提示本票是行使第一次请求权，它是向本票的其他债务人行使追索的必经程序，没有按期提示的本票，持票人不能向其前手追索。

本票的见票，是指本票的出票人因持票人的提示，为确定见票后定期支付本票金额的到期日，在本票上记载“见票”字样并签章的行为。持票人未按照规定期限提示见票的，丧失对出票人以外的前手的追索权。

法律规定，本票自出票日起，付款期限最长不得超过 2 个月。

五、支票

（一）支票的概念、种类和特点

支票，是指出票人签发的、委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

支票的基本当事人包括出票人、付款人和收款人。支票分为现金支票、转账支票和普通支票三种。

支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能用于支取现金。支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于转账。

支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票。在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于转账，不得支取现金。

支票的特点：

第一，支票的付款人仅限于银行或其他金融机构，此与汇票不同。

第二，支票为见票即付的即期票据。见票即付是支票的唯一形式，不存在汇票、本票那样的即期和远期之分。

第三，支票是委付证券，不同于本票。

第四，支票的无因性受到一定的限制。

（二）支票的出票

支票的出票同样是创设票据权利的基础票据行为，出票人签发支票后，即对支票的收款人承担担保责任；付款人则取得按照支票所载文义代出票人付款的权利及票据法上规定的特定条件下向付款人付款的义务

1.支票的出票须以出票人与付款银行之间的账户合同关系为基础，禁止透支和开立空头支票。

2.支票在记载事项与格式上不同于汇票，且不以收款人为绝对必要记载事项。

（三）支票的付款

支票属于见票即付的近期票据，无须提示承兑，但须提示付款。

作为支付证券，支票提示期限相对较短。除异地使用的支票外，支票的持票人应当自出票日起 10 日内提示付款。超过提示付款期限的，付款人可以不予付款；付款人不予付款的，出票人仍应当对持票人承担票据责任。

六、票据电子化与票据法未来的发展

目前，我国《票据法》规定的汇票、本票、支票三类票据中，银行汇票、银行本票和支

票均已不同程度地实现了电子化，只有商业汇票仍采用传统的手工处理方式。

我国现行《票据法》的有关票据规则均以传统纸质票据作为规范对象，缺乏对电子票据进行规范的必要设计。

讲解归纳与举例

【答案】D

【解析】“金额 100 万元，城市银行进行了承兑”→合法持票人主张票据权利的，城市银行承担第一顺位的付款义务。

“丙公司办公楼失火，票据被烧毁，仅有留档的复印件”→票据具有要式性，原件灭失应通过法定的程序进行救济，复印件≠原件，复印件没有票据的效力。

【单选题】诚益公司用一张银行承兑汇票来支付与刘伟的合同款项，甲银行已经承兑。但票据上没有将刘伟写为被背书人。刘伟用此票据买红酒，红酒公司担心拿不到钱，刘伟就找了自己的好朋友张三作为此票据的保证人，但没写明被保证人红酒公司在被背书人栏中填了自己的名字并盖章红酒公司向甲银行提示付款时被拒绝。下列说法正确的是？

- A.刘伟对红酒公司无任何法律责任
- B.红酒公司应先向诚益公司主张追索权
- C.虽没写明被保证人，张三仍需承担保证责任
- D.红酒公司可以向甲银行主张追索权

【答案】C

【解析】实施票据保证时，如果没写明被保证人不影响保证的成立，法律推定票据的第一责任人为被保证人：①已经承兑的汇票，推定承兑人为被保证人；②未经承兑的汇票，推定出票人为被保证人。本案中，张三实施保证行为时，虽然没写明被保证人，保证行为依旧成立，张三应承担保证责任。

【多选题】甲公司为清偿对乙公司的欠款，开出一张收款人是乙公司财务部长李某的汇票。李某不慎将汇票丢失，王某拾得后在汇票上伪造了李某的签章，并将汇票背书转让给外地的丙公司，用来支付购买丙公司电缆的货款，王某收到电缆后转卖得款，之后不知所踪。关于本案，下列哪些说法是正确的？

- A.甲公司应当承担票据责任
- B.李某不承担票据责任

- C.王某应当承担票据责任
- D.丙公司应当享有票据权利
- E.王某应为其伪造签章的违法行为承担民事责任

【答案】ABDE

【解析】王某虽然在汇票上进行了签章，但汇票上显示的签章是李某而非王某，故王某没有真实签章，不承担票据责任。但王某要为其伪造签章的违法行为承担民事、刑事等法律责任，C 错误，E 正确。票据具有独立性，票据上有伪造、编造签章的，不影响票据上其他真实签章的效力，AD 正确。票据上李某的签章系王某伪造，李某不承担票据责任，B 正确。

【名词解释题】本票

【参考答案】本票是出票人签发的、承诺自己在见票时无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据。

【名词解释题】汇票

【参考答案】汇票是出票人签发的，委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

【名词解释题】支票

【参考答案】支票是指出票人签发的、委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

第 7 章 保险法

本章重难点分析

- 1.了解保险法的概念、基本原则
- 2.了解并掌握保险合同的种类、成立、成效及履行
- 3.了解保险业法

第 1 节 保险法概述

一、保险的概念与基本属性

（一）保险的概念

我国《保险法》第 2 条规定：“本法所称保险，是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿责任

金责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限等条件时承担给付保险金责任的商业保险行为。”

（二）保险的基本属性

保险是以危险为逻辑起点，以大数法则为主要数理基础，以危险转移为目的的一种危险处理方式。

二、保险法的概念和地位

（一）保险法的概念

我国保险法是调整保险合同关系、保险组织（保险业）关系和保险业监督管理关系的法律规范的总称。

（二）我国的保险立法

从学科划分的意义来看，保险法属于商法，是民商法的特别法。

中华人民共和国第一部《保险法》诞生于 1995 年，分别于 2002 年、2009 年、2014 年、2015 年、2018 年进行了修改。

（三）保险法的特殊属性

第一，保险合同的标的和对价不同于一般合同。保险产品要求保险的危险与保险产品的价格之间贯彻所谓的对价平衡原则，即风险和保费相适应。

第二，如果把保险当作一件商品来看，除了生存保险之外，当事人双方都不希望商品的购买方去实际消费该产品。这在商品市场中可能是独一无二的。

第三，在金融诸业中，或许只有保险业直接关乎民生和社会保障。

第四，对投保方来讲，保险是一种金钱换承诺的行为。

第五，保险与其他金融产品一样，需要建立一套专门针对保险等金融消费者权益保护的法律法规体系。

三、保险与相关术语的区别

（一）保险与社会保险

广义上的保险包括商业保险和社会保险。我国《保险法》的调整对象仅限于商业保险，社会保险由《社会保险法》专门调整。

商业保险与社会保险的差别：

（1）运作基础不同。商业保险的运作基础在于当事人的意思自治和合同自由；社会保险具有社会保障的性质，系通过立法的方式强制推行，其内容也由立法做出规定。

（2）运作机构的性质不同。商业保险的主体均为营利性的企业法人，社会保险则由专门的

国家机构办理。

（3）保险的宗旨不同。商业保险具有营利性；而社会保险的主要目的在于消除贫困和缩小贫富差距，不具有营利性质。

（4）具体类别不同。商业保险尤其是财产保险（含责任保险），赔付的标准根据保费的多少等因素而有差别；社会保险只限于人身保险，主要以健康、养老、失业、医疗等为保障对象，实现全社会或者全行业统筹，按照法定的保障标准给付。

（5）适用对象不同。商业保险的被保险人可以是符合承保条件的任何人；社会保险的保障对象则有严格规定，符合条件的全体社会成员均应纳入社会保障体系。

（二）保险与储蓄

（1）实施的方法不同。保险是互助合作行为，只能依靠多数人的互助共济；储蓄是自助行为，可以单独、个别地实施。

（2）给付与反给付的前提条件不同。保险只需要存在综合的、整体的均等给付关系即可；而储蓄在给付与反给付之间存在个别的均等关系，取款的数量取决于存款的数量和期限。

（3）遵循的原则不同。保险虽也贯彻“投保自愿，退保自由”原则，但如果退保，通常要扣除已经经过的保险期间的保险费或者管理费、手续费，并且退保金往往会少于所缴的保险费；而储蓄的原则是“存款自愿，取款自由”。

（三）保险与赌博

（1）法律性质不同。保险是各国法律所倡导的良善制度，赌博则被视为违法行为。

（2）道德认可不同。保险是广受赞许的人类互助精神的发扬，利己利人；赌博则是道德所不倡导甚至谴责的人类贪婪本性的极端流露，试图不劳而获，损人损己。

（3）目的和作用不同。保险是收集保险费建立保险基金，通过互助共济的方式，对被保险人或者受益人予以救济，以达到社会安定的目的的行为；赌博是对财产的意外增加或者减少。保险是使投保人或被保险人“从不安定走向安定”的行为，赌博则是一种“从安定走向不安定”的行为。

（4）是否以保险利益为基础不同。保险以保险利益的存在为前提，投保人与保险标的存在一定的利益关系；赌博的对象则可以是在与自己没有任何利害关系的财产或者事件。

（5）与危险或获利的关系不同。保险的危险都是客观存在的，投保人没有获利的可能；赌博的危险则都是参与者自找的，且赌博存在获利的可能性。

（四）保险与保证

（1）法律性质不同。保险合同是独立的合同关系；保证则是效力从属于主合同的从合同。

保险既是一种法律关系，又是一种经济制度；保证则纯属法律关系之一种。

（2）法律效力不同。保险合同中，保险人履行的义务是自己应尽的义务，除非作为第一方保险的财产损失保险中保险危险的发生是基于第三者的责任，一般不发生追偿权问题；保证合同中保证人则是代主债务人履行合同义务，而后享有代位追偿权，于一般保证（而非连带责任保证）的场合，保证人还享有先诉抗辩权。

四、保险法律关系

保险法律关系是保险关系的主体之间针对保险客体所形成的权利义务关系。

保险法律关系的主体包括保险合同当事人、保险合同关系人、保险合同辅助人。保险合同当事人是指投保人和保险人；保险合同关系人是指被保险人和受益人；保险合同辅助人则是指保险代理人、保险经纪人、保险公估人。

保险法律关系的客体，又称为保险标的或者保险法所欲保障的保险利益，是保险行为指向的对象，包括财产关系中的有体物、无形利益，以及人身关系中的生命、身体和健康。

1.投保人

投保人是指与保险人订立保险合同，并按照合同约定负有交付保险费义务的人。投保人负有交付保险费的义务。违反交费义务的法律后果表现为：

第一，约定以交付保险费或者首期保费为合同的生效条件时，投保人违反该义务，则保险合同不生效。

第二，对于已经生效的人寿保险合同，投保人违反交付保险费义务，保险人不得请求强制履行，只能依照《保险法》第 36 条的规定行使合同中止权。

第三，健康保险和意外伤害保险合同中，多约定以保险费的交付作为合同的生效要件，投保人交付保险费之前，合同仅仅成立但不生效。

第四，财产保险合同中，保险费在合同生效之后可以作为保险人对投保人享有的债权，保险人既可以请求强制交付，也可以在发生保险事故进行赔付时扣除投保人欠交的保险费，还可以依照合同约定解除合同，合同解除前未发生保险事故的，保险人有权要求投保人支付自保险责任开始时至合同解除前期间的保险费。

2.保险人

保险人，也称承保人，是指与投保人订立保险合同，并按照合同约定承担赔偿责任或者给付保险金责任的保险公司。

保险人负有如下义务：

（1）承担危险的义务。

(2) 通知与保密义务。

3. 被保险人

被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。投保人可以为被保险人。被保险人在保险关系中主要享有两方面权利：(1) 同意权。(2) 保险金赔付请求权。

4. 受益人

受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。投保人、被保险人可以为受益人。

受益人具有如下特征：

- (1) 受益人是享有赔偿金请求权的人。
- (2) 受益人由被保险人或者投保人指定。
- (3) 指定的受益人可以变更或撤销。

讲解归纳与举例

【多选题】保险法律关系的主体包括下列哪些

- A. 投保人
- B. 被投保人
- C. 受益人
- D. 保险人
- E. 保险经纪人

【答案】ABCDE

【解析】保险法律关系的主体包括保险合同当事人（投保人、被投保人）、保险合同关系人（被保险人、受益人）、保险合同辅助人（保险代理人、保险经纪人、保险公估人）。

第2节 保险法的基本原则

一、最大诚信原则

(一) 最大诚信原则概述

最大诚信原则，是指保险合同的双方当事人在合同的订立和履行过程中，必须以最大的诚意履行自己的义务，互不欺骗和隐瞒，恪守合同的约定，以免影响合同的成立以及效力的存续。

最大诚信原则在保险法上主要体现为三项规则：投保人的告知义务、保险人的说明义务、保险人的弃权与禁止反言规则

（二）投保人的告知义务

《保险法》第 16 条规定：“订立保险合同保险人就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问的，投保人应当如实告知。投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除合同。”

告知义务具有如下特征：（1）系法定义务。（2）系先契约义务。（3）系间接义务或不真正义务。不真正义务，是指违反告知义务之时，保险人不能强制履行此项义务，通常也不能请求损害赔偿，仅能对投保人或被保险人课以一定不利益的法律后果（不赔付）以收间接强制之效。

投保人违反告知义务的，可能产生如下法律后果：

其一，保险人有权解除保险合同。

其二，保险人对于合同解除前发生的保险事故不承担保险责任。

《保险法》第 16 条规定，保险人的合同解除权，自其知道有解除事由之日起，超过 30 日不行使而消灭。自合同成立之日起超过 2 年的，保险人不得解除合同；发生保险事故的，保险人应当承担赔偿或者给付保险金的责任。

（三）保险人的说明义务

保险人的说明义务，是指保险人在保险合同订立阶段，依法应当履行的将保险合同条款、所含专业术语及有关文件内容，向投保人陈述或解释的法定义务。

《保险法》第 17 条规定：“订立保险合同，采用保险人提供的格式条款的，保险人向投保人提供的投保单应当附格式条款，保险人应当向投保人说明合同的内容。对保险合同中免除保险人责任的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明；未做提示或者明确说明的，该条款不产生效力。”

二、保险利益原则

（一）保险利益原则概述

保险利益，又称可保利益，是指投保人或者被保险人对保险标的具有的法律上承认的利益，是在保险事故发生时可能遭受减损的利益。

我国《保险法》第 31 条、第 48 条规定，人身保险合同在订立时，投保人对被保险人不具有保险利益的，合同无效；财产保险合同在保险事故发生时，被保险人对保险标的不具有保险利益的，不得向保险人请求赔偿保险金。

（二）保险利益存在的范围和时点

我国《保险法》第 31 条规定：“投保人对下列人员具有保险利益：（一）本人；（二）配偶、子女、父母；（三）前项以外与投保人有抚养、赡养或者扶养关系的家庭其他成员、近亲属；（四）与投保人有劳动关系的劳动者。除前款规定外，被保险人同意投保人为其订立合同的，视为投保人对被保险人具有保险利益。”

关于保险利益的存在时点，在人身保险中，保险利益必须于订约时存在，但在财产保险中，保险利益不必于订约时存在，只需在事故发生时存在即可。

三、损失补偿原则

（一）损失补偿原则概述

损失补偿原则是指在保险期限内发生保险事故致使被保险人遭受损失时，保险人在责任范围内对被保险人遭受的损失进行补偿。

损失补偿原则在保险法上主要表现为如下规则：

超额保险的无效规则、重复保险的比例分摊规则、保险代位权规则、委付规则等。

（二）损失补偿原则的适用范围及规则体现

损失补偿原则在保险法中主要体现为以下具体规则：

（1）超额保险的无效规则，即保险金额超过保险价值的，超过部分无效。

（2）重复保险的比例分摊规则，即重复保险的各保险人赔偿保险金的总和不得超过保险价值。除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任。

（3）保险代位求偿规则，即因第三者对保险标的的损害而发生保险事故的，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利。

（4）保险委付规则，即保险事故发生后，保险人已支付全部保险金额，并且保险金额等于保险价值的，受损保险标的之上的全部权利归于保险人；保险金额低于保险价值的，保险人按照保险金额与保险价值的比例取得受损保险标的的部分权利。

（三）保险损失补偿的范围

（1）保险标的的实际损失。

（2）施救费用。

（3）其他合理费用。

（四）保险损失补偿的计算方法

1. 第一危险赔偿方式

第一部分是相当于保险金额的损失，即保险人负责赔偿的第一部分损失；超过保险金额

的部分为第二部分损失，保险人对此部分不负责赔偿。

2. 限额赔偿方式

限额赔偿方式又分为超出一定限额赔偿和不足限额赔偿。

前者是指保险人与被保险人双方事先约定一个免责限额，在此限额以内的损失，由被保险人自己承担；

超过此限额，由保险人予以赔偿。

“免赔额”具体分为两种：其一，相对免赔额，指保险标的受损程度或金额超过规定的免责限额时，才赔偿被保险人的全部损失；不超过该限额时，不负责赔偿，由被保险人自己承担。其二，绝对免赔额，指保险标的损失超过免责限额时，只赔付超过部分的损失，即赔款额等于损失金额和免责限额之差。

3. 比例赔偿方式

比例赔偿方式，又称“比例责任赔偿方式”，是指发生保险事故造成损失后，按照保险金额与出险时保险财产的实际价值的比例来计算赔款。

（1）在计算赔款时，如果保险金额与保险标的实际价值一致，则构成足额保险或者全额保险，按照保险标的实际损失赔偿。（2）保险金额超过保险标的实际价值的部分，构成超额保险，超出部分无效，保险人不予赔偿。（3）保险金额低于保险财产的实际价值时，构成不足额保险，其差额视作被保险人自保和自留。赔偿金额=损失金额×保险金额/保险标的的实际价值（保险金额/保险标的的实际价值≤1）。

4. 定值赔偿方式

在海洋运输货物保险、船舶保险和无法鉴定其价值的高档工艺品、古玩、珠宝等特约保险中，保险人与被保险人约定保险价值作为保险金额，出险时不论保险标的当时的实际价值或市价涨落如何，全损按保险金额全部赔偿，部分损失按损失程度赔偿。

（五）保险代位权

保险代位权，是指保险人就被保险人遭受的损失全额支付保险金之后，可以向就该损失对被保险人负有赔偿责任的第三人请求赔偿的权利。

保险人应以自己的名义行使保险代位求偿权。

（六）保险委付制度

《保险法》第59条规定：“保险事故发生后，保险人已支付了全部保险金额，并且保险金额等于保险价值的，受损保险标的的全部权利归于保险人；保险金额低于保险价值的，保险人按照保险金额与保险价值的比例取得受损保险标的的部分权利。”委付通常适用于海上

保险。

讲解归纳与举例

【单选题】下列关于保险代位权的表述正确的是

- A.保险人在被保险人尚未支付全部保险金之前享有代位权
- B.保险人应以自己的名义行使代位权
- C.保险人是向被保险人行使代位权
- D.保险人可以委托他人行使代位权

【答案】B

【解析】根据规定，保险人应以自己的名义行使保险代位求偿权。

第3节 保险合同

一、保险合同的特征

（一）保险合同的特征

保险合同是指投保人与保险人之间约定保险权利义务关系的协议。

- 1.保险人的合同责任以金钱赔付为常态。
- 2.保险合同的解除权与一般合同不同。《保险法》第15条规定：“除本法另有规定或者保险合同另有约定外，保险合同成立后，投保人可以解除合同，保险人不得解除合同。”
- 3.保险合同的效力，部分取决于当事人与保险标的之间的保险利益关系。
- 4.如果将保险费视为保险合同或者保险产品中的“价格”，则这种合同价格受到特殊的监管。

（二）保险合同的特征

1.保险合同是射幸合同

单个保险合同是一种典型的射幸合同。投保人根据保险合同交付保险费的义务是确定的，而保险人赔偿或者给付保险金的义务在保险合同订立时尚不确定，最终是否赔付通常取决于保险事故发生与否。

基于保险合同的射幸性，保险法上特别设定了防范道德危险的法律规范：

（1）财产保险的保险金额不得超过保险价值。超过保险价值的，超过部分无效；重复保险的各保险人赔偿保险金的总和不得超过保险价值

基于保险合同的射幸性，保险法上特别设定了防范道德危险的法律规范：

（2）人身保险的投保人在保险合同订立时，对被保险人应当具有保险利益；财产保险的被保险人在保险事故发生时，对保险标的应当具有保险利益。

（3）投保人不得为无民事行为能力人投保以死亡为给付保险金条件的人身保险，保险人也

不得承保。

（4）以死亡为给付保险金条件的合同，未经被保险人同意并认可保险金额的，合同无效。按照以死亡为给付保险金条件的合同所签发的保险单，未经被保险人书面同意，不得转让或者质押。

（5）以被保险人死亡为给付保险金条件的合同，自合同成立或者合同效力恢复之日起2年内，被保险人自杀的，保险人不承担给付保险金的责任，但被保险人自杀时为无民事行为能力人的除外。

（6）被保险人或者受益人谎报、编造保险事故，保险人有权解除合同，并不退还保险费。

2. 保险合同是非要式合同

3. 保险合同是诺成合同

诺成合同，又称为非要物合同，是指依照当事人意思表示即可成立，不以交付标的物或者履行其他给付为成立要件的合同。

4. 保险合同是属人性合同

二、保险合同的分类

（一）人身保险和财产保险

以保险标的为划分标准，保险可分为人身保险和财产保险。

1. 人身保险

人身保险合同是以人的寿命、健康和身体为保险标的的保险，具体可分为人寿保险、健康保险、意外伤害保险、年金保险等。

人寿保险是指保险人和投保人约定，如果被保险人死亡、于约定的年限内死亡或者约定的期限届满仍然生存时，由保险人按照约定向被保险人或者受益人给付保险金的保险。

健康保险是指保险人和投保人约定，于被保险人发生疾病或者因此而残疾或死亡时，保险人依照约定向被保险人或者受益人给付保险金的保险。

意外伤害保险是指保险人和投保人约定，在被保险人遭受意外伤害并由此致残或死亡时，由保险人依照约定向被保险人或者受益人给付保险金的保险。

年金保险是指年金保险人于被保险人生存期间或特定期间内，依照合同约定一次或分期给付一定金额的保险。

2. 财产保险

财产保险是以财产及其有关利益为保险标的的保险，又称产物保险。按照保险标的的不

同，财产保险可分为财产损失保险、责任保险、信用保险与保证保险。

（二）损失填补保险和定额给付保险

以保险金赔付方式的不同，或者说以保险利益的存在基础是否是经济上的利益为划分标准，保险可分为损失填补保险和定额给付保险。

财产保险必然为损失填补保险，而人身保险则多为定额给付保险。

（三）自愿保险和强制保险

以实施方式为划分标准，保险可分为自愿保险和强制保险。

我国目前除机动车交通事故责任第三者责任采取强制保险外，煤矿企业对煤矿井下作业职工的意外伤害、建筑施工企业对从事危险作业的职工的意外伤害、旅行社就自身对游客的旅行社责任等领域也建立了强制保险制度。

（四）原保险和再保险

以保险危险转移的层次为划分标准，保险可分为原保险和再保险。

原保险，又称第一次保险，是指投保人和保险人通过订立保险合同建立的原始保险关系。

再保险，又称为第二次保险，是指保险人将其承担的保险业务，部分或全部移转给其他保险人的保险。

三、保险合同的成立与生效

《保险法》第13条第1款规定：“投保人提出保险要求，经保险人同意承保，保险合同成立。保险人应当及时向投保人签发保险单或者其他保险凭证。”

我国保险法还将“被保险人同意”作为以死亡为给付保险金条件的人身保险合同的生效要件。

四、保险合同的条款解释

（一）疑义利益解释原则

疑义利益解释原则又称为“不利解释原则”，渊源于罗马法法谚“有疑义应为表意者不利之解释”，是指格式合同的语句有歧义、模糊或者两种以上的解释时，应采取对拟定合同条款一方不利的解释。

（二）合理期待原则

合理期待原则是指保险合同当事人就合同内容的解释发生争议时，如果合同内容本身不含歧义，应以投保人或被保险人对合同缔约目的的合理期待为出发点对保险合同进行解释。

五、保险合同的履行

（一）人身保险合同的履行

人身保险合同的履行具有如下特征：

- （1）保险费之请求原则上不得强制；
- （2）以生命表或伤残表作为直接的技术基础；
- （3）具有储蓄性质；
- （4）保险金原则上定额给付；
- （5）原则上不适用保险代位求偿权。

五、保险合同的履行

（一）人身保险合同的履行

1.人身保险合同特殊条款的履行方法具体包括：

- （1）宽限期条款，是指对于人身保险的保险费交付期予以宽限的条款。
- （2）年龄误报条款，又称年龄误保条款，是指被保险人的真实年龄于订约时被误报并记载于保单内，保险人允许投保人进行更正，或在保险事故发生后，允许保险人采取相应办法予以处理的一种合同约定。
- （3）自杀条款，是指被保险人在保单生效或者复效后的2年内自杀的，保险人不负给付保险金责任的条款。

2.人身保险合同中的受益权

受益权，是指受益人享有的依照约定请求给付保险金的权利。

受益权与继承权的主要差别在于：基于受益权而受领之保险金，不承担被保险人之债务；但基于继承权而获得的被保险人财产，须以继承的财产为限负担被保险人的债务。

根据《保险法司法解释（三）》规定，投保人指定和变更受益人应当征得被保险人同意，未经被保险人同意的，指定和变更行为无效。

（二）财产保险合同的履行

1.我国交强险制度概述

交强险是“机动车交通事故责任第三者责任强制保险”的简称，又称“机动车强制责任保险”，是指由保险公司对被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人的人身伤亡、财产损失，在责任限额内予以赔偿的强制性责任保险。

交强险的投保人是指与保险公司订立交强险合同，并按照合同负有支付保险费义务的机动车的所有人、管理人；被保险人则是指投保人及其允许的合法驾驶人。交强险保障的对象是被保险机动车本车人员和被保险人以外的第三人，并以被保险人对第三方依法应负的民事赔偿责任为保险标的。

2.强制投保与承保

我国交强险实行强制投保、强制承保、强制续保制度。在中国境内道路上行驶的机动车都有义务投保交强险。

机动车所有人、管理人未按照规定投保交强险的，由公安机关交通管理部门扣留机动车，并通知机动车所有人、管理人依照规定投保，处依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的2倍罚款。

3.基础费率与浮动费率

我国交强险实行统一的保险条款和基础保险费率。

根据规定，被保险机动车没有发生道路交通安全违法行为和道路交通事故的，保险公司应当在下一年度降低其保险费率。

4.责任范围、免责事项与责任限额

根据规定，被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人人身伤亡、财产损失的，由保险公司依法在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。若道路交通事故的损失是由受害人故意造成的，则保险公司不予赔偿。

《交强险条款》规定，交强险不负责赔偿和垫付下列损失和费用：

- （1）因受害人故意造成的交通事故的损失；
- （2）被保险人所有的财产及被保险机动车上的财产遭受的损失；
- （3）被保险机动车发生交通事故，致使受害人停业、停驶、停电、停水、停气、停产、通信或者网络中断、数据丢失、电压变化等造成的损失以及受害人财产因市场价格变动造成的贬值、修理后因价值降低造成的损失等其他各种间接损失；
- （4）因交通事故产生的仲裁或者诉讼费用以及其他相关费用。我国交强险在全国范围内实行统一的责任限额，具体分为：

- 1）死亡伤残赔偿限额；
- 2）医疗费用赔偿限额；
- 3）财产损失赔偿限额；
- 4）被保险人在道路交通事故中无责任的赔偿限额。其中无责任的赔偿限额也分为无责任死亡伤残赔偿限额、无责任医疗费用赔偿限额以及无责任财产损失赔偿限额。

讲解归纳与举例

【多选题】关于保险合同的理解，下列哪些表述是正确的？

A.保险人可以随时解除合同

- B.被保险人编造保险事故，保险人有权解除合同
- C.保险合同是要式合同
- D.依法成立的保险合同，自成立时生效
- E.人身保险属于保险合同范畴

【答案】BDE

【解析】《保险法》第 15 条规定：“除本法另有规定或者保险合同另有约定外，保险合同成立后，投保人可以解除合同，保险人不得解除合同。” A 错误：保险合同不需要具备法定形式，只由双方约定即可。C 错误

第 4 节 保险业法

一、保险业法概述

保险业法：可指以经营保险为业的组织体法律规范，还可以指代保险业组织规范之外的保险行业的经营规则以及保险业监管规范等。

根据我国《保险法》规定，我国保险业贯彻“专营原则”与“分业经营”原则。

保险业务由依照保险法设立的保险公司以及法律、行政法规规定的其他保险组织经营，其他单位和个人不得经营保险业务。

混业经营，也叫兼营保险，是指由银行、证券公司等金融机构作为保险人提供的保险。兼营保险主要是银行、保险、证券三大金融业混业经营的产物。

二、保险业组织

《保险法》及中国银保监会对保险公司的设立、运营和管理做出了相关规定：

1. 保险公司设立一律采用核准制

设立保险公司应当经国务院保险监督管理机构批准。

2. 严格的设立条件：

（1）主要股东具有持续盈利能力，信誉良好，最近 3 年内无重大违法违规记录，净资产不低于人民币 2 亿元。

（2）有符合《保险法》和《公司法》规定的章程。

（3）有不少于人民币 2 亿元的注册资本，且注册资本必须为实缴货币资本；国务院保险监督管理机构根据保险公司的业务范围、经营规模，可以调整其注册资本的最低限额，但不得低于人民币 2 亿元的限额。

（4）有具备任职专业知识和业务工作经验的董事、监事和高级管理人员；董事、监事和高级管理人员，应当品行良好，熟悉与保险相关的法律、行政法规，具有履行职责所需的经营

管理能力，并在任职前取得保险监督管理机构核准的任职资格。高级管理人员的范围由国务院保险监督管理机构规定。

（5）有健全的组织机构和管理制度。

（6）有符合要求的营业场所和与经营业务有关的其他设施。

（7）法律、行政法规和国务院保险监督管理机构规定的其他条件。

三、保险辅助人

保险辅助人包括保险中介人（保险代理人、保险经纪人）、保险公估人。

（一）保险代理人

保险代理人，是指根据保险人的委托，向保险人收取佣金，并在保险人授权的范围内代为办理保险业务的单位或者个人。

保险代理人分为机构代理人和个人代理人，机构代理人又可分为专业代理人 and 兼业代理人。

保险专业代理机构，是指根据保险公司的委托，向保险公司收取佣金，在保险公司授权的范围内专门代为办理保险业务的机构，包括保险专业代理公司及其分支机构。

保险专业代理机构经营的保险代理业务主要包括：

（1）代理销售保险产品；

（2）代理收取保险费；

（3）代理相关保险业务的损失勘查和理赔；

（4）国务院保险监督管理机构批准的其他业务。保险专业代理公司在注册地以外的省、自治区或者直辖市开展保险代理活动，应当设立分支机构。保险专业代理公司分支机构的经营区域不得超出其所在地的省、自治区或者直辖市。

（二）保险经纪人

保险经纪人，是指基于投保人的利益，为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务，并依法收取佣金的机构。

与保险代理人不同，保险经纪人是基于投保人的利益，以自己的名义独立开展保险中介业务。保险经纪人因过错给投保人、被保险人造成损失的，依法承担赔偿责任。

（三）保险公估人

保险公估人（在我国台湾地区称为保险公证人），是指接受委托，专门从事保险标的或者保险事故评估、勘验、鉴定、估损理算等业务，并按约定收取报酬的单位或个人。

根据规定，保险公估机构可以经营下列业务：

- (1) 保险标的承保前和承保后的检验、估价及风险评估;
- (2) 保险标的出险后的查勘、检验、估损理算及出险保险标的残值处理;
- (3) 风险管理咨询;
- (4) 国务院保险监督管理机构批准的其他业务。

关于保险公估人的主体资格，目前国务院保险监督管理机构仅仅限定于单位或者机构。
根据规定，保险公估机构应当采取下列组织形式：

- (1) 有限责任公司;
- (2) 股份有限公司;
- (3) 合伙企业。保险公估从业人员不得以个人名义招揽、从事保险公估业务或者同时在两个以上保险公估机构中执业。

根据规定，保险公估机构及其从业人员享有下列权利：

- (1) 根据执行业务的需要，要求委托人及其他相关当事人提供有关保险公估的文件、资料和其他必要协助;
- (2) 客观、公正地从事保险公估活动，在当事人不提供协助或者要求出具虚假保险公估报告时，中止执行业务或者终止履行合同;
- (3) 法律、行政法规和国务院保险监督管理机构规定的其他权利。保险公估人的主要义务表现为执业的公正性和独立性。

四、保险业的监督管理

保险业的监管包括：保险费率的监管，偿付能力的监控，保险公司的整顿，保险公司的接管、撤销与清算等。

1. 保险费率的监管

根据《保险法》规定，关系社会公众利益的保险险种、依法实行强制保险的险种和新开发的人寿保险险种等的保险条款和保险费率，应当报国务院保险监督管理机构批准。

2. 偿付能力的监控

保险法规定，国务院保险监督管理机构应当建立健全保险公司偿付能力监管体系，对保险公司的偿付能力实施监控。

对偿付能力不足的保险公司，国务院保险监督管理机构应当将其列为重点监管对象，并可以根据具体情况采取下列措施：

- (1) 责令增加资本金、办理再保险;
- (2) 限制业务范围;

- (3) 限制向股东分红;
- (4) 限制固定资产购置或者经营费用规模;
- (5) 限制资金运用的形式、比例;
- (6) 限制增设分支机构;
- (7) 责令拍卖不良资产、转让保险业务;
- (8) 限制董事、监事、高级管理人员的薪酬水平;
- (9) 限制商业性广告;
- (10) 责令停止接受新业务。

3.保险公司的整顿

保险公司未依照《保险法》规定提取或者结转各项责任准备金,或者未依照该法规定办理再保险,或者严重违反该法关于资金运用的规定的,监管机构做出限期改正的决定后,保险公司逾期未改正的,监管机构可以决定选派保险专业人员和指定该保险公司的有关人员组成整顿组,对公司进行整顿。

整顿决定应当载明被整顿公司的名称、整顿理由、整顿组成员和整顿期限,并予以公告。

4.保险公司的接管、撤销与清算

保险法规定,保险公司有下列情形之一的,国务院保险监督管理机构可以对其实行接管:

- (1) 公司的偿付能力严重不足的;
- (2) 违反《保险法》规定,损害社会公共利益,可能严重危及或者已经严重危及公司的偿付能力的。被接管的保险公司的债权债务关系不因接管而变化。

被整顿、被接管的保险公司达到《企业破产法》规定的破产界限时,国务院保险监督管理机构可以依法向人民法院申请对该保险公司进行重整或者破产清算。

5.其他监管措施

保险公司在整顿、接管、撤销清算期间,或者出现重大风险时,国务院保险监督管理机构可以对该公司直接负责的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员采取以下措施:

- (1) 通知出境管理机关依法阻止其出境;
- (2) 申请司法机关禁止其转移、转让或者以其他方式处分财产,或者在财产上设定其他权利。

讲解归纳与举例

【单选题】关于保险业务的理解,下列哪个表述是正确的?

A.保险业务可以由个人经营

- B.某未依法设立的保险公司可以经营保险业务
- C.银行柜台可以自行开展保险业务
- D.个人不得经营保险业务

【答案】D

【解析】保险业务由依照保险法设立的保险公司以及法律、行政法规规定的其他保险组织经营，其他单位和个人不得经营保险业务。一些银行营业柜台销售的保险并非兼营保险，而是银行为保险公司代销的保险

【单选题】下列哪个类别不属于保险辅助人？

- A.保险经纪人
- B.保险代理人
- C.保险公估人
- D.保险公司客服

【答案】D

【解析】保险辅助人包括保险代理人、保险经纪人、保险公估人

第8章 证券法

本章重难点分析

- 1.理解证券的概念和特征，把握证券的内涵与外延，并在此基础上领会证券法的基本原则和这些基本原则对证券法律的实务的指导。
- 2.掌握证券发行的基本制度类型，区分两种发行制度的各自利弊，同时学习证券发行中的条件、程序和相关法律规则。
- 3.了解证券市场有典型的违法行为的类型，掌握证券市场监管的方式和手段、及监管机构的职能。

第1节 证券法的基本问题

一、证券概述

（一）证券的概念及法律特征

广义上的证券可分为有价证券与无价证券。

有价证券又可分为价值证券和实物证券，而价值证券还可分为货币证券和资本证券。本章所讨论的“证券”，是资本证券。

证券，是指资金需求者为了筹措中长期资金而向投资者发行，由投资者购买且能对一定

的收益拥有请求权的投资凭证。

证券具有以下四个法律特征：

- （1）证券是一种投资权利证书。
- （2）证券是一种可转让的权利证书。
- （3）证券是一种面值均等的权利证书。证券在其票面上一般会标明特定的金额，同一种证券所标明的金额都是相等的。
- （4）证券是一种含有风险的权利证书。

（二）证券的分类

依据不同的标准，可对证券做出不同的分类：

- （1）依证券上是否记载面值，证券可分为有面值证券和无面值证券；
 - （2）依持券人的姓名是否记载在证券上，证券可分为记名证券和不记名证券；
 - （3）依发行人发行证券时是否向证券购买者提供担保，证券可分为担保证券和无担保证券；
 - （4）依持券人享有权利的性质，证券分为股票、债券、新股认购权利证书、投资基金证券及其他衍生金融工具等，以股权为内容的证券主要是股票，以债权为内容的证券主要是债券。
- 我国 2019 年修订的《证券法》第 2 条规定的证券包括股票、公司债券、存托凭证、政府债券、证券投资基金份额和国务院依法认定的其他证券。

（三）证券市场及其结构

1. 证券市场

证券市场是包括证券投资活动全过程在内的证券供求交易的网络和体系，它是金融市场的重要组成部分。证券市场的构成有三个要素：

- （1）市场主体，主要是指资金需求者和资金供给者，还包括提供各种金融服务的参与者。
- （2）市场客体，即金融工具，是指交易双方在交易活动中按照一定的格式明确各自权利义务的书面凭证，如股票、债券。
- （3）市场组织方式，主要有交易所方式和柜台交易方式。

2. 证券市场的内部结构

一是发行市场，二是交易市场。

证券发行市场，又称“初级市场”或“一级市场”。发行市场是一个由发行者、投资者和证券公司（或投资银行）三者构成的市场，它为发行者筹集资金提供便利的条件。

证券发行市场有两个必要前提：

其一，凡证券的发行，必须有管理机构的许可；

其二，证券公司包销或承购证券，必须领有执照。证券交易市场，又称“次级市场”或“二级市场”。

交易市场是一个由证券出让者、交易场所、证券购买者三者构成的市场，它为投资者转让所持证券、收回本金提供便利的条件。

证券市场的交易量，只代表现有证券所有权的转移，不代表社会资本存量的增加。

按照证券交易的场所不同，可以将证券交易市场划分为场内市场和场外市场。所谓场内市场，即在证券交易所内进行的证券交易（如主板市场、创业板、科创板等）；场外市场则泛指在证券交易所外进行的各种证券交易（如新三板、区域性产权交易、全国银行间债券市场）

二、证券法概述

（一）证券法的概念与调整对象

证券法包括一切有关资本证券的法律规范。具体地说，证券法是关于证券募集、发行、交易、服务以及对证券市场进行监督管理的法律规范的总和。

证券的募集是资金需求者（发行人）设法从资金供给者（投资者）那里筹集资金的活动，它包括资金需求者进行资金筹措的可行性论证、制定招募章程或说明书、报请主管机构审核、备置证券及其认购书、公告招募认购等步骤。

证券的发行是证券供给者直接或委托证券发行中介人代理将证券出售，由证券需求者购买证券的活动。证券的发行与证券的募集是紧密联系的。

证券的交易是持有证券的人在证券市场上出让证券，由其他投资者买受证券的活动。证券的服务是为便于证券发行与交易，而向有关方面提供的诸如资产评估、证券评级、投资咨询、证券登记、清算服务以及会计与法律服务等辅助活动。

证券的监督管理是国家根据市场的现状和发展趋势，运用行政的力量对证券市场进行规划、调控和监督的活动。

证券法的任务就是规范上述证券募集、发行、交易、服务、监督管理等活动，引导社会资金合理配置，保障证券市场各方参与者的权益，促进证券市场的繁荣和经济的发展。

证券法的调整对象是证券市场的参与者和监督管理者在证券的募集、发行、交易、服务、监督管理过程中所发生的各种经济社会关系，这些关系可统称为“证券关系”。证券法律关系的构成有三个要素：

- （1）证券及证券行为，这是证券法律关系的客体；
- （2）证券市场的参与者和监督管理者，这是证券法律关系的主体；

（3）证券市场的参与者和监督管理者所享有的权利（权力）和承担的义务，这是证券法律关系的内容。

（二）证券法的原则

1.公开原则

公开原则亦称信息公开制度。它是指证券发行者在证券发行前或发行后根据法定的要求和程序向证券监督管理机构和证券投资者提供规定的能够影响证券价格的有关信息资料。

依据公开原则，发行证券的主体所公开的信息应当做到：

- （1）真实。证券发行人所披露的信息必须与所反映的事实相符，不得存在任何虚假陈述。
- （2）准确。证券发行人在进行信息披露时，必须采用精确的表述方式以确切表明其含义，内容表述清晰。
- （3）全面。所有与证券价格有关的信息资料应尽可能详细地公开，不得故意隐瞒、遗漏。
- （4）及时。证券发行人的有关信息应以最快的速度传达接受者，不得故意拖延迟缓。
- （5）公平。证券发行人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得私下提前向特定对象单独披露。
- （6）易得。信息资料应以广大投资者最易获得的形式加以公开，发行者应设法通过各种宣传媒体进行传播。
- （7）易解。信息内容的表述应通俗简明，易被大众理解，不得使用深奥、容易引起误解的字

2.公平原则

公平原则是指证券商事关系主体在证券募集、发行、交易、服务活动中应公平合理，照顾各方的权利和利益。

公平原则要求证券商事关系主体做到：

- （1）平等。当事人无论其身份、经济实力等存在何种差异，在商事活动中的地位平等。证券商事关系主体应相互尊重，平等协商。
- （2）自愿。当事人可依法行使自己的商事权利，按照自己的意愿参与商事活动。证券商事关系主体在商事活动中要真实表达自己的意志，切忌一方当事人将自己的意志强加于另一方当事人。
- （3）等价有偿。证券商事关系主体在从事商事活动中要按照价值规律的要求进行等价交换，除法律另有规定或合同另有约定者外，取得他人财产利益或得到他人的劳动服务必须向对方支付相应的价款或酬金。当事人一方不得无偿占有、剥夺他方的财产，损害他人利益。

(4) 诚实守信。证券商事关系主体在从事商事活动时，应讲诚实，守信用，以善意的方式履行其义务，不得规避法律和合同。

3. 公正原则

公正原则是指证券监督管理机构及其他组织和人员应充分运用法律，采取有效措施，对证券市场的违法犯罪活动进行制止和查处，以确保投资者得到公正的对待。

公正原则要求证券监督管理机构及其他组织和人员做到：

(1) 反欺诈。证券监督管理机构不仅要求信息充分公开，而且要求这些公开的信息是真实的，严禁发行者或出售者制造或散布虚假的或使人误解的信息，并严禁某些不正当的证券销售手段。

(2) 反操纵。法律禁止一切使用直接或间接方法操纵市场、扰乱市场的行为，如连续抬价买人或压价卖出同一种证券，联手买卖证券等。

(3) 反内幕交易。证券发行人的董事、高级职员、对公司有控制权的股东等内幕信息知情人，利用尚未公开的信息进行证券交易以图获利或避免损失，或将尚未公开的信息透露给他人，使他人据此进行证券交易，就构成内幕交易。证券法对内幕交易应当施以严格的限制。我国《证券法》“总则”第 3-7 条规定了证券市场活动须遵守的五项基本原则。这五项原则是：

(1) “三公原则”；

(2) 自愿、有偿、诚实信用原则；

(3) “三禁原则”，即禁止欺诈、内幕交易和操纵证券市场的行为的原则；

(4) 证券业和银行业、信托业、保险业实行分业经营、分业管理的原则；

(5) 集中统一监督管理原则。理解证券法，首先必须从理解这些原则着手。

(三) 证券法的体系与结构

证券法体系是指国家通过制定法律、法规、部门规章或认可自治规范、守则等方式对证券行业进行制度化管理、调节和监督的法律规范整体。

证券法结构是证券法的内容与表现形式的有机统一体。我国的证券法结构，从内容来看，应包括：

(1) 总则。(2) 证券的发行。(3) 证券的交易。(4) 证券经营机构。(5) 证券服务机构。

(6) 证券交易所。(7) 证券监督管理机构。(8) 证券业协会。(9) 证券仲裁与诉讼。(10) 境外证券投资。

三、我国证券法的发展历程

自改革开放以来，我国资本市场经历了一个从低级到高级、从简单到复杂的发展过程；与此相应，证券法律制度也呈现出明显的螺旋式上升与波浪式前进的特征。这种上升和前进与政策引领、与我国的经济体制改革密切相关。

我国证券市场在不断向前发展的过程中存在着相互影响、相互制约和相互作用的各种要素，发展正是对经济、法律等各类资源进行有效整合的结果。

讲解归纳与举例

【多选题】我国证券法规定的证券包括

- A.股票
- B.公司债券
- C.存托凭证
- D.政府债券
- E.政府投资基金份额

【答案】ABCDE

【解析】我国 2019 年修订的《证券法》第 2 条规定的证券包括股票、公司债券、存托凭证、政府债券、证券投资基金份额和国务院依法认定的其他证券。

第 2 节 证券市场主体法律制度

一、证券交易所

（一）证券交易所的概念及法律特征

证券交易所是依据国家有关法律设立的，为证券集中交易提供场所和设施，组织和监督证券交易，实行自律管理的法人。

证券交易所具有以下特征：

- （1）一般都是依法设立的法人组织；
- （2）是证券集中交易的场所；
- （3）是证券交易的组织者和监督者；
- （4）是自律管理的法人。

（二）证券交易所的组织形式

就国际上现有交易所来看，主要有两种形式：一种是会员制，一种是公司制。会员制的证券交易所不以营利为目的，其会员是各证券商。

公司制的证券交易所是由股东出资设立并以营利为目的的企业法人。

（三）证券交易所的职责范围

- 1.提供证券交易的场所、设施和服务
- 2.制定和修改证券交易所的业务规则
- 3.证券发行及上市的审核，决定证券终止上市和重新上市
- 4.提供非公开发行证券转让服务
- 5.组织、监督证券交易
- 6.对会员进行监管
- 7.对证券上市交易公司及相关信息披露义务人进行监管
- 8.对证券服务机构为证券上市、交易等提供服务的行为进行监管
- 9.管理和公布市场信息
- 10.开展投资者教育和保护
- 11.证券监督管理机构赋予的其他职能

二、证券公司

（一）证券公司的概念

证券公司是指依照公司法规定，经证券监督管理机构批准设立的从事证券经营业务的有限责任公司或者股份有限公司。

根据我国《证券法》的规定，个人与合伙组织不能经营证券业务。

（二）证券公司的设立条件

- （1）有符合法律、行政法规规定的公司章程；
- （2）主要股东及公司的实际控制人具有良好的财务状况和诚信记录，最近 3 年无重大违法违规记录；
- （3）有符合《证券法》规定的公司注册资本；
- （4）董事、监事、高级管理人员、从业人员符合《证券法》规定的条件；
- （5）有完善的风险管理与内部控制制度；
- （6）有合格的经营场所、业务设施和信息技术系统；
- （7）法律、行政法规和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

（三）证券公司的业务范围

证券公司从事的证券业务主要有：

- （1）证券经纪；
- （2）证券投资咨询；
- （3）与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；

- (4) 证券承销与保荐;
- (5) 证券融资融券;
- (6) 证券做市交易;
- (7) 证券自营;
- (8) 证券资产管理;
- (9) 其他证券业务。

(四) 证券公司的业务规则

- (1) 业务许可规则。
- (2) 证券业务分开办理规则。
- (3) 证券账户实名制规则。
- (4) 客户账户管理规则。

在日常业务活动中，证券公司还应注意：

- (1) 不得接受客户的全权委托，即证券公司不得代客户决定证券买卖、选择证券种类、决定买卖数量或者买卖价格。
- (2) 不得以任何方式对客户买卖证券的收益或损失赔偿做出承诺。投资风险应由投资者自己承担。证券公司做出承诺不仅增大了自身的经营风险，而且破坏了公平竞争的秩序。
- (3) 不得私下接受委托。证券公司及其从业人员不得未经过其依法设立的营业场所，私下接受客户委托买卖证券。

三、证券登记结算机构

(一) 证券登记结算机构的概念及职能

证券登记结算机构是指为证券交易提供集中的登记、存管与结算服务的不以营利为目的的法人。

证券登记结算采取全国集中统一的运营方式。根据《证券法》的规定，我国的登记结算机构是中国证券登记结算有限责任公司。

证券登记结算机构一般具有登记、存管和结算三项职能。

(二) 证券登记结算机构的业务规则

证券登记结算机构在其主要业务活动中应当遵循如下规则：

- (1) 账户的开立及管理规则。
- (2) 账户的存管和过户规则。
- (3) 结算规则。

（三）证券登记结算机构的风险防范

证券结算是证券市场的高风险活动，这种风险来自信用风险、技术故障、操作失误以及不可抗力等因素。

证券结算风险基金是指证券登记结算机构依法设立的用于补偿证券登记结算机构损失的一种基金。风险基金的资金来源有两个：

一是从证券登记结算机构的业务收入和收益中提取；

二是由证券公司按证券交易业务量的一定比例缴纳。

四、证券服务机构

（一）证券服务机构概述

证券服务机构是指专门从事证券投资咨询业务、证券资信评级业务、为证券发行与交易提供会计、审计及法律服务的机构，主要包括投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等。

（二）证券投资咨询机构

证券投资咨询机构，又称证券投资顾问机构，是指依法成立的，为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议，以营利为目的的证券服务组织。

（三）证券资信评估机构

证券资信评估机构是依法设立的对证券质量进行评价从而确定证券投资价值，以营利为目的的证券服务机构。

按国际上通行的做法，资信评估机构对证券信用等级进行评定一般采取三等九级制，最高为 AAA 级，最低为 C 级。

（四）其他证券交易服务机构

在证券市场中，除上述证券投资咨询机构、证券资信评估机构提供咨询等服务外，还有会计师事务所、律师事务所提供审计、咨询评估和法律等服务。

五、证券业协会

（一）证券业协会的性质和职责

证券业协会，又称证券业同业公会，是依法设立的旨在对证券业进行自律性管理的具有法人资格的社会团体组织。

作为社会团体法人，证券业协会是由证券公司和其他证券经营、服务机构自愿组织成立的。有自己的独立财产或基金，有成员共同制定的团体章程，其活动不以营利为目的。

证券业协会分为全国性证券业协会和地方性证券业协会两种。

（二）证券业协会的会员及内部管理

证券业协会的会员主要是证券公司

我国《证券法》规定，证券公司应当加入证券业协会。

我国证券业协会采取的是自愿入会与强制入会相结合的办法。证券业协会的权力机构是由全体会员组成的会员大会。

讲解归纳与举例

【多选题】下列哪些属于证券交易所的特征

- A.法人组织
- B.证券集中交易的场所
- C.是证券交易的组织者
- D.属于自律管理
- E.监督证券交易

【答案】ABCDE

【解析】证券交易所具有以下特征：（1）一般都是依法设立的法人组织；（2）是证券集中交易的场所；（3）是证券交易的组织者和监督者；（4）是自律管理的法人

第3节 证券发行与承销法律制度

一、证券发行

（一）证券发行的概念及法律意义

证券发行是指证券的发行者为筹集资金依法向投资者以同一条件招募和出售股票、公司债券以及其他证券的活动。

证券发行包括证券募集和证券交付两个环节。证券发行具有如下法律特征：

- （1）证券发行主体应当具备法定资格。
- （2）证券发行的客体是特殊的金融商品，主要包括股票、公司债券、存托凭证等。
- （3）证券发行必须依照法定的程序进行，确保发行的公开、公平和公正。
- （4）证券发行以筹集资金为主要目的，通过筹集资金改善资本结构、财务结构或满足特定项目的生产经营需要。

（二）证券发行的分类

依证券品种不同，证券发行可分为股票发行、债券发行、存托凭证发行、国务院依法认定的其他证券发行。

依发行对象的不同，证券发行可分为公募和私募。公募即公开发行，是发行者向不特定

的社会公众广泛出售证券的行为；私募即非公开发行，是指面向少数特定的投资者发行证券的行为。

依发行目的不同，证券发行可分为设立发行和增资发行。这种分类适用于股票发行。

依发行是否借助证券发行中介机构的不同，证券发行可分为直接发行和间接发行。直接发行是证券发行人不通过证券承销机构，由自己承担发行风险，办理发行事宜。

依发行价格与证券票面金额或贴现金额的关系不同，证券发行可分为平价发行、溢价发行、折价发行。

我国法律仅允许股票平价发行和溢价发行，不允许折价发行。依发行地点不同，证券发行可分为境内发行和境外发行。

（三）证券发行的条件

公司首次公开发行新股应当满足以下条件：

- （1）具备健全且运行良好的组织机构；
- （2）具有持续经营能力；
- （3）最近 3 年财务会计报告被出具无保留意见审计报告；
- （4）发行人及其控股股东、实际控制人最近 3 年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；
- （5）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

公开发行公司债券，应当符合下列条件：

- （1）具备健全且运行良好的组织机构；
- （2）最近 3 年平均可分配利润足以支付公司债券 1 年的利息；
- （3）国务院规定的其他条件。

根据我国法律的规定，公司债券发行主体的范围较股票发行主体的范围广泛，凡满足上述条件的公司原则上均可发行公司债券。

（四）证券发行保荐制度

保荐制度又称保荐人（sponsor）制度，源于英国。

证券发行保荐是指证券发行人申请其证券公开发行，必须聘请依法取得保荐资格的保荐人为其出具保荐意见，证明其发行文件中所载材料真实、完整、准确，符合公开发行的条件，从而由保荐人协助发行人建立严格的信息披露制度，承担风险防范责任。我国的保荐制度适用于两种情况：

- （1）公开发行股票、可转换为股票的公司债券，依法采取承销方式的。

(2) 公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券。

(五) 证券发行的审核

证券发行审核制度主要包括两种，即核准制和注册制。

核准制又称实质管理主义，是指证券发行人除了进行信息披露，还必须在主体资格、财务状况、盈利能力等方面满足法定的实质条件，并经证券主管机关实质审查核准方可发行证券的制度。

注册制又称申报制，是指发行人按照法律规定向证券主管机关提交与发行有关的文件，通过主管机关的形式审查后即可发行证券的制度。

2019年修订的《证券法》的规定，公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门注册，未经依法注册，任何单位和个人不得公开发行证券。

(六) 证券发行信息公开

1. 证券发行信息公开的意义

证券发行信息公开，是指证券发行人按照法律、行政法规、部门规章及相关规范性文件的规定，在证券公开发行前，公告公开发行募集文件，并将该文件置备于指定场所供公众查阅的制度。

意义在于：

(1) 有利于投资者做出正确的投资选择。通过对发行公司的资信、资产负债情况及经营状况的公开，投资者可以全面了解拟发行证券，从而决定是否投资以及投资多少。

(2) 保证所有投资者有均等地获得信息的权利。将一切对投资者进行投资判断有重大影响的信息予以公开，有助于解决信息不对称问题，防止操纵市场、内幕交易等不公平现象的发生。

(3) 有利于规范发行公司的行为。信息的公开，可使发行公司受到公众的监督，从而保证发行公司在规范的轨道上运行。

2. 预披露制度

预披露，是指发行人申请首次公开发行证券的，在依法向审核部门报送注册或申请文件并经审核部门受理后，预先向社会公众披露相关注册或申请文件，而不是等审核部门对发行文件审核完毕，做出准许发行的决定后再进行披露的制度。

3. 证券发行需公开的信息

证券发行需公开的信息主要是指募集文件的内容。

募集文件主要包括招股说明书、配股说明书、公司债券募集办法等。

（七）募集资金投向和使用

发行审核机关在选择发行企业时，要严格审查募集资金的投向。

二、证券承销

（一）证券承销概述

证券承销是指发行人委托证券公司（又称承销商）向证券市场上不特定的投资人公开销售股票、债券及其他投资证券的活动。

（二）证券承销方式

证券承销通常有四种方式，即代销、助销、包销和承销团承销。

1. 证券代销

证券代销，是指承销商代理发售证券，并于发售期结束后，将未销售部分证券退还发行人的承销方式。

2. 证券助销

证券助销，是指承销商按承销合同规定，在约定的承销期满后对剩余的证券出资买进（此即余额包销，我国的证券法将余额包销归入包销方式），或者按剩余部分的数额向发行人贷款，以保证发行人的筹资、用资计划顺利实现。

3. 证券包销

证券包销，是指在证券发行时，承销商以自己的资金购买计划发行的全部或部分证券，然后再向公众出售，承销期满后未出售部分仍由承销商自己持有的一种承销方式。

4. 承销团承销

承销团承销，又称“联合承销”，是指两个以上的证券承销商共同接受发行人的委托向社会公开发售某一证券的承销方式。

（三）证券承销合同

证券承销合同是指证券发行人与证券承销商或是主承销商与分销商就证券承销的有关内容所达成的明确双方权利义务的书面协议。

证券承销合同的法律特征主要有：

- （1）合同主体是特定的。
- （2）合同性质是多种的。
- （3）合同以依法注册发行证券为生效要件。
- （4）合同的内容不得违反国家强制性规定。

讲解归纳与举例

【单选题】证券发行人不包括

- A.公司
- B.政府
- C.金融机构
- D.个人

【答案】D

【解析】证券发行人包括公司、政府、金融机构以及其他企业法人。

第4节 证券上市与交易法律制度

一、证券上市

（一）证券上市的概念

证券上市有广义和狭义之分。

广义的证券上市是指已发行的证券依照法定的条件和程序在证券交易所或其他法定交易场所进行交易的行为。

而狭义的证券上市是指公开发行的证券依法在证券交易所挂牌进行集中竞价交易的行为，不包括非公开发行的证券的挂牌交易，也不包括场外交易市场的证券交易。

证券上市与证券发行有明显的区别：

（1）证券发行的对象是初始投资者，这些投资者要通过申购程序产生；证券上市的对象是市场的所有投资者，欲购买证券的人通过交易所均可购得。

（2）证券发行的价格一般是事先确定的，而证券上市的价格则通过交易所竞价产生，由供求情况决定。

（3）证券发行的卖方是特定的，买方是不特定的，而证券上市后的买卖双方均是不特定的。证券发行也可以与证券上市合并进行。

（二）证券上市的标准

一般而言，股票的上市条件主要包括如下四方面：

- （1）股票已经公开发行，这是上市交易的前提。
- （2）公司股本总额达到最低要求。
- （3）公司股权结构具有公众性。
- （4）诚信经营，财务规则符合要求。

公司债券的上市条件，通常而言需要满足如下三方面要求：

- (1) 债券经有权部门审核并依法完成发行。
- (2) 债券持有人符合交易所投资者适当性管理规定。
- (3) 证券交易所规定的其他上市条件，如公司债券的期限、公司债券的实际发行额等。

(三) 证券上市的程序

1. 股票上市程序

- (1) 上市申请。
- (2) 上市审核。
- (3) 签署上市协议。
- (4) 公告上市。
- (5) 挂牌交易。

2. 公司债券上市程序

(1) 申请核准。在我国，公司申请其发行的公司债券上市交易，应当向证券交易所提出申请，由证券交易所依法审核同意，并由双方签订上市协议。

(2) 公告上市。公司债券上市交易申请经证券交易所审核同意后，签订上市协议的公司应当在规定的期限内公告公司债券上市文件及有关文件，并将其申请文件置备于指定场所供公众查阅。

3. 政府债券上市程序

基于债券主体的特殊性，政府债券信用度高，由财政来担保，其发行方式、时间、对象和还款期限都由政府财政部门具体规定，因此可豁免证券交易所的发行及上市审查。

证券交易所根据国务院授权的部门的决定安排政府债券上市交易。

(四) 证券退市制度

证券退市是指当上市公司出现法定情形时，由证券交易所依法永久性地停止其证券上市交易的制度。

1. 股票退市

股票退市是指上市公司因出现法定情形而被证券交易所决定取消股票挂牌交易资格，或上市公司主动向证券交易所申请终止上市的情况。前者通常被称为强制退市，后者被称为主动退市。

2. 公司债券退市

公司债券退市是指取消公司债券在证券交易所挂牌交易的资格。

二、证券交易

（一）证券交易概述

1. 证券交易的概念与特征

证券交易是指对已经依法发行并经投资者认购的证券进行买卖的行为。证券交易是证券转让的一种。证券转让除了证券交易以外，还有赠与、继承等。

证券交易的主要特征是：

- （1）它是一种具有财产价值的特定权利的买卖。
- （2）它是一种标准化合同的买卖
- （3）它是一种已经依法发行并经投资者认购的证券的买卖。

2. 证券交易的分类

证券交易依不同的标准可做不同的分类。从交易场所的角度来看，可分为集中交易市场和分散交易市场；

从买卖双方交易主体结合方式来看，可分为议价交易和竞价交易；从达成交易的方式来看，可分为直接交易和间接交易（委托交易）；

从交割期限和投资方式来看，可分为现货交易、期货交易、期权交易、信用交易和回购。

（二）证券交易的一般规则

- 1. 非依法发行的证券不得买卖
- 2. 转让期限有限制性规定的证券在限定期内不得买卖
- 3. 证券从业人员买卖证券的禁止或限制
- 4. 证券交易必须在法定的交易场所进行
- 5. 证券交易可采取多种方式
- 6. 证券交易的标的有多个种类
- 7. 证券交易应当遵守保密义务
- 8. 证券交易的收费必须合理
- 9. 短线交易的禁止及上市公司的归入权

（三）证券交易的程序

1. 名册登记与开设账户

名册登记是委托人（投资者）在集中市场进行证券买卖的前提。开设账户是投资者进行证券买卖的基本条件。

2. 委托

所谓委托，是指委托人向证券公司发出的表示委托人以某种价格购进或卖出一定数量的

某种证券的意思表示（通常称为委托指令）。

3.成交

成交是指证券公司相互间通过交易所内竞价，就买卖证券的价格和数量达成一致的行为，一般是通过计算机进行和完成。

4.结算与过户

证券登记结算机构根据成交结果，按照结算规则，进行证券和资金的清算交收。结算包括清算与交收两个行为。

证券过户是指证券由证券转让人移转至证券受让人的登记过程。上市的记名证券的过户由证券登记结算公司通过计算机统一办理。

三、持续信息公开

持续信息公开，是指证券在进入证券交易场所交易之后，证券发行人依法向公众披露对投资者的投资决策有重大影响或对所发行证券的交易价格有重要影响的相关信息。持续信息公开是公开原则在交易市场中的反映。

持续信息公开具有以下三个特点：

（1）公开的功能不单是让投资者了解公司，更主要的是为投资者提供证券交易价值判断的依据。

（2）信息公开不是一次性完成的，而是要持续不断地进行。上市公司只要继续存在，只要有影响价格形成的因素或情况产生，就须履行公开义务。

（3）信息公开的形式和内容在法律上有不同的要求。持续信息公开主要涉及上市公告书、年度报告、中期报告及临时报告等，而初始信息公开主要是招股说明书、配股说明书、募债说明书等。

持续信息公开的内容包括：

（1）上市公告书。

（2）中期报告。

（3）年度报告。

（4）临时报告。

四、上市公司收购

（一）上市公司收购的概念及法律特征

上市公司收购是指投资者（收购人）旨在获得特定上市公司（目标公司）控制权或将该公司合并所进行的批量股份购买行为。特点：

- (1) 被收购公司是股票公开上市的股份有限公司，因而其股份掌握在众多的投资者手中。
- (2) 收购人可以是企业法人，也可以是自然人。在实践中，企业法人作为收购人为多数。
- (3) 收购人收购股份的行为不单纯是投资，更重要的是要在控制股份的基础上控制目标公司的经营管理权，或干脆将目标公司与收购人合并。
- (4) 由于上市公司收购主要是为了取得目标公司控制权，而在“资本多数决”原则下，收购人只有掌握了多数有表决权的股份才能实现对公司的控制。

(二) 上市公司收购的分类

1. 上市公司收购的基本类型

上市公司股份收购包括通过证券交易所的集中竞价交易收购（简称“竞价收购”）、要约收购、协议收购。

竞价收购是指收购人通过证券交易所集中竞价交易方式依法连续收购上市公司已发行的有表决权的股份并取得相对控股权的行为。

要约收购是指收购人为取得或强化对目标公司的控制权，通过向目标公司全体股东公开发出购买该上市公司股份的要约方式，收购该上市公司股份的行为。

竞价收购是指收购人通过证券交易所集中竞价交易方式依法连续收购上市公司已发行的有表决权的股份并取得相对控股权的行为。

协议收购是指收购者与上市公司特定股东通过私下协商的形式，与该股东达成股权转让协议，取得该部分股份，进而获得对目标公司控制权的收购。

2. 上市公司收购的其他分类

- (1) 依收购是否成为收购人的法定义务为标准，上市公司收购可分为自愿收购和强制收购。
- (2) 依预定收购的股份数量，上市公司的收购还可分为部分收购和全面收购。
- (3) 依收购人是否直接取得上市公司控制地位的股权，上市公司的收购还可分为直接收购和间接收购。

(三) 上市公司收购的一般规则

1. 权益披露规则

任何人通过证券交易所的股票交易持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的有表决权的股份达到 5% 时，无论其是否具有收购的意图，均需暂停购买且依法定要求报告或公告其持股情况。此规则也称“百分之五规则”。

2. “台阶规则”

“台阶规则”要求投资者通过证券交易所的证券交易持有或者通过协议、其他安排与他

人共同持有一个上市公司已发行的有表决权的股份达到 5%以后，每增加或者减少一定的持股比例时，均须暂停买卖该公司的股票，且须依法进行报告和公告。

我国《证券法》规定每增加或减少的“一定比例”亦为 5%。

3.强制要约规则

强制要约规则要求投资者通过证券交易所的证券交易持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的有表决权的股份达到 30%时，继续进行收购的，应当依法向该上市公司所有股东发出收购上市公司全部或者部分股份的要约。

4.终止上市规则

终止上市规则要求，收购要约的期限届满，被收购公司的股权分布不符合上市条件的，该上市公司的股票就应当由证券交易所依法终止上市。

5.强制接受规则

强制接受规则要求，收购要约的期限届满，被收购公司股权分布不符合上市条件的，该上市公司的股票就应当由证券交易所依法终止上市，其余仍持有被收购公司股票的股东，有权向收购人以收购要约的同等条件出售其股票，收购人应当无条件地受让。

6.同等条件收购规则

采取要约收购方式的，收购人在收购要约期限内，不得卖出被收购公司的股票，也不得采取要约规定以外的形式和超出要约的条件买入目标公司的股票。竞价收购与协议收购不受此规则约束。

7.转让股份限制规则

在上市公司收购中，收购人对所持有的目标公司股票，在收购行为完成后的 18 个月内不得转让。

（四）上市公司收购的程序

1.竞价收购的程序

竞价收购的程序通常包括：

- （1）通过证券交易所购买目标公司已发行的有表决权的股份达 5%。
- （2）按“权益披露规则”报告与公告。
- （3）继续购买目标公司股份，按“台阶规则”报告与公告。
- （4）达到相对控股的程度，向中国证监会和证券交易所报告持股情况及收购后的改组计划。
- （5）依《公司法》的规定请求召开临时股东大会。
- （6）实施改组计划。这些计划可能涉及组织机构的重组、人员的重组、资产的重组以及业

务的重组等。

2.要约收购的程序

要约收购的程序通常包括：

- (1) 编制要约收购报告书，同时对要约收购报告书摘要做出提示性公告。
- (2) 报告。
- (3) 公告收购要约。
- (4) 收购。
- (5) 实施改组或合并计划。
- (6) 报告与公告。

3.协议收购的程序

协议收购的程序通常包括：

- (1) 谈判。
- (2) 经协议双方有关机构批准。
- (3) 正式签订收购协议。
- (4) 报告与公告。
- (5) 发出要约。
- (6) 履行收购协议。
- (7) 实施改组或合并计划。
- (8) 报告及公告。

讲解归纳与举例

【多选题】 证券交易的方式包括

- A.集中竞价交易
- B.大宗交易
- C.做市商交易
- D.协议交易
- E.折价交易

【答案】 ABCD

【解析】 证券交易的方式可采用集中竞价交易、大宗交易、做市商交易、协议交易等。

第5节 证券投资者保护法律制度

一、投资者的类型划分

我国《证券法》规定的主要参考因素是投资者的财产状况、金融资产状况、投资知识和经验、专业能力等，并以此将投资者分为普通投资者和专业投资者。对于不同类别的投资者给予不同的制度保护。

二、投资者适当性制度

投资者适当性制度是金融市场的一项基础性制度，也是金融市场法制建设不可或缺的重要方面。

其本质是要求金融机构承担将金融产品仅推荐给能够理解产品本身及投资机会，并能承受投资损失的投资者，实现保护投资者的目的。

投资者适当性制度是指，证券经营机构在销售和推荐证券产品的过程中，须充分了解客户的投资知识、投资经验、投资目标、财务状况、风险承受度等信息，并充分了解所推荐或销售的证券产品或服务，从而将适合的证券产品和服务推荐或销售给适合的客户。

三、投资者权利行使机制

投资者是持有上市公司股份的股东，或是向公司融资持有公司债券的持券人。

基于股东的身份，投资者享有《公司法》规定的股东的各项合法权益，尤其是投票权和利益分配请求权。

我国《证券法》明确规定，上市公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依法设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。

四、投资者权益救济措施

（一）投资者保护机构

我国已经形成了“一体两翼”的投资者保护组织体系。其中“一体”是指中国证监会下设的中国证监会投资者保护局，“两翼”分别指中国证券投资者保护基金有限责任公司和中证中小投资者服务中心有限责任公司。

（二）先行赔付制度

先行赔付，是指在发生虚假陈述等案件时，在对发行人、上市公司等市场主体据以承担赔偿责任的行政处罚、司法裁判做出之前，由可能承担民事赔偿责任的连带责任人之一先行垫资向投资者承担赔偿责任，然后再由先行赔付者向未参与先行赔付的发行人、上市公司以及其他责任人进行追偿的一种措施。

（三）证券支持诉讼制度

所谓证券支持诉讼，就是针对涉及中小投资者众多、矛盾比较突出、社会影响较大的典型证券侵权纠纷，由投服中心以投资者保护机构的身份，根据中小投资者提出的申请，委派投服中心的公益律师或法律专业人员作为中小投资者诉讼代理人，代理中小投资者向法院起诉并参与诉讼的活动。

（四）证券代表人诉讼制度

我国《证券法》明确规定了证券领域的代表人诉讼制度，主要包括：

（1）投资者提起虚假陈述等证券民事赔偿诉讼时，诉讼标的是同一种类，且当事人一方人数众多的，可以依法推选代表人进行诉讼。

（2）对于这类诉讼，人民法院可以发出公告，说明该诉讼请求的案件情况，通知投资者在一定期间向人民法院登记。人民法院做出的判决、裁定，对参加登记的投资者发生法律效力。

（3）投资者保护机构受 50 名以上投资者委托，可以作为代表人参加诉讼，并为经证券登记结算机构确认的权利人向人民法院登记，但投资者明确表示不愿意参加该诉讼的除外。

讲解归纳与举例

【多选题】我国“一体两翼”的投资者保护组织体系指的是

- A.中国证监会下设的中国证监会投资者保护局
- B.中国证券投资者保护基金有限责任公司
- C.中证中小投资者服务中心有限责任公司
- D.中国证监会
- E.证券公司

【答案】ABC

【解析】“一体”是指中国证监会下设的中国证监会投资者保护局，“两翼”分别指中国证券投资者保护基金有限责任公司和中证中小投资者服务中心有限责任公司。

第 6 节 证券监督管理机构

一、证券监督管理机构的性质

我国《证券法》规定，国务院证券监督管理机构依法对证券市场实行监督管理，维护证券市场秩序，保障其合法运行。

（1）专业性。证券监督管理机构为专门针对证券市场设置的监督管理机构。

（2）行政性。证券监督管理机构是行政管理机构，其所从事的证券监督管理行为是代表国家所进行的行政干预行为，其以国家权力来查处违法行为，从而保障投资者权益，维护证券市场秩序。

(3) 执法性。证券监督管理机构是证券法的执法机构。

二、证券监督管理体制

证券监督管理体制是指一国范围内以证券法为基础而构成的证券监督管理体系、层次结构、功能模式以及运行机制的统一体。

世界各国对证券市场的监管体制主要分为自律型管理体制和集中型管理体制。我国证券法确立的证券监督管理体制属于集中型管理体制。

三、证券监督管理机构的职责范围我国《证券法》的规定：

(1) 依法制定有关证券市场监督管理的规章、规则，并依法进行审批、核准、注册，办理备案；

(2) 依法对证券的发行、上市、交易、登记、存管、结算等行为，进行监督管理；

(3) 依法对证券发行人、证券公司、证券服务机构、证券交易场所、证券登记结算机构的证券业务活动，进行监督管理；

(4) 依法制定从事证券业务人员的行为准则，并监督实施；

(5) 依法监督检查证券发行、上市、交易的信息披露；

(6) 依法对证券业协会的自律管理活动进行指导和监督；

(7) 依法监测并防范、处置证券市场风险；

(8) 依法开展投资者教育；

(9) 依法对证券违法行为进行查处；

(10) 法律、行政法规规定的其他职责。

四、证券监管中的行政和解

行政和解是指中国证监会在对行政相对人涉嫌违反证券期货法律、行政法规和相关监管规定的行为进行调查执法过程中，根据行政相对人的申请，与其就改正涉嫌违法行为、消除涉嫌违法行为不良后果、交纳行政和解金、补偿投资者损失等事项进行协商，达成行政和解协议，并据此终止调查执法程序的制度。

我国现行《证券法》第 171 条的规定从立法层面确认了证券领域的行政和解制度。

五、证券监督管理机构工作人员的行为准则

(1) 符合检查、调查程序要求的义务。

(2) 保守商业秘密的义务。证券监督管理机构工作人员依法履行自己的职责时，必须对知悉的有关单位和个人的商业秘密予以保密。

(3) 忠于职守的义务。证券监督管理机构工作人员必须忠于职守，依法办事，公正廉洁，

不得利用自己的职权牟取不正当的利益。

（4）办事公开的义务。证券监督管理机构及其工作人员的行为是行政执法行为，应当受到公众监督，以防职权被滥用。

（5）兼职禁止的义务。

六、证券监管的国际合作

（一）国际证券监管组织的现状

国际证监会组织（IOSCO）是一个常设的国际性证券监管组织，成立于 1983 年，于 2004 年迁至西班牙马德里市。

2007 年，中国证监会签署了证监会国际组织《关于咨询、合作与信息交换的多边备忘录》。该备忘录为证券监管机构办理跨境违法案件制定了标准。

（二）国际监管的标准

（1）证券监管的目标是保护投资者，确保市场的公正、有效和透明，减少系统风险。

（2）证券监管的原则（其中包括 38 项具体原则）。

（三）证券监管的跨境合作

目前，中国证监会已与 71 个国家和地区的证券监管机构签署了双边监管合作谅解备忘录，建立了跨境监管与执法合作机制。

讲解归纳与举例

【单选题】国际性证券监管组织是

- A.国际证监会组织
- B.国际监管组织
- C.国际证券交易组织
- D.国际证券委员会

【答案】A

【解析】国际证监会组织（IOSCO）是一个常设的国际性证券监管组织。

第 7 节 证券违法行为法律责任

一、虚假陈述行为及其法律责任

所谓虚假陈述，是指信息披露义务人违反信息披露义务，在证券发行和交易过程中，对证券活动的事实、性质、前景等事项做出不实、误导、遗漏的陈述，致使投资者不明真相而产生投资损失的违法行为。

1. 虚假陈述的具体形态

- (1) 虚假记载
- (2) 误导性陈述
- (3) 重大遗漏
- (4) 未按规定披露

2. 虚假陈述的责任主体

- (1) 信息披露义务人。
- (2) 发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员。
- (3) 证券保荐人、承销商及其直接责任人员。
- (4) 证券专业服务机构。在申请证券发行、上市过程中，发行人需要聘请律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等专业机构协助制作有关申请文件，并出具有关报告和证明文件。

3. 虚假陈述的归责原则

对虚假陈述行为人的责任认定，《证券法》采用了无过错责任、过错推定责任和过错责任三种原则。

- (1) 无过错责任。适用这类归责原则的责任主体是信息披露义务人。
- (2) 过错推定责任。其适用主体是发行人、上市公司中的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员；证券保荐人、承销商及其直接责任人员；证券专业中介服务机构。
- (3) 过错责任。适用这类归责原则的责任主体是发行人、上市公司的控股股东、实际控制人。

4. 虚假陈述的法律责任承担

- (1) 民事责任。虚假陈述的民事责任制度旨在补偿因信息披露人违反法律规定，进行虚假陈述，从而给投资者造成的损失。
- (2) 行政责任。这里的行政责任的处罚类别主要包括责令改正、罚款、警告、暂停或者取消其发行、上市资格等。
- (3) 刑事责任。当虚假陈述行为人有严重违法情节或给投资人造成严重损害时，其行为已具有严重的社会危害性，应当承担刑事责任。

二、内幕交易行为及其法律责任

内幕交易是指内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息进行证券交易活动的行为。

- (一) 知悉内幕信息的人

知悉内幕信息的人主要分为两类,即证券交易内幕信息的知情人与非法获取内幕信息的人。前者是指知悉证券交易内幕信息的人员。后者主要是通过非法手段或非法途径获得内幕信息的人。

（二）内幕信息

内幕信息,是指证券交易活动中,涉及证券发行人的经营、财务或者对该发行人证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。

“未公开性”与“重大性”是内幕信息的两个主要特征。

（三）内幕交易行为的法律责任

在民事责任方面,因内幕交易行为给投资者造成损失的,行为人应依法承担赔偿责任。在行政责任方面,证券监管机构有权责令违法行为人依法处理非法持有的证券,没收违法所得,并处以违法所得1倍以上10倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足50万元的,处以50万元以上500万元以下的罚款。单位从事内幕交易的,还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处以20万元以上200万元以下的罚款。证券监督管理机构工作人员进行内幕交易的,从重处罚。

我国《刑法》第180条就规定了关于证券期货的内幕交易罪。

三、操纵证券市场行为及其法律责任

操纵证券市场是指行为人以不正当手段,影响证券交易价格或者证券交易量,制造虚假繁荣、虚假价格,诱导或者迫使其他投资者在不了解真相的情况下做出错误的投资决定,使操纵者获利或减少损失的行为。

（1）民事责任。

（2）行政责任。主要是责令依法处理非法持有的证券,没收违法所得,并处以违法所得1倍以上10倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足100万元的,处以100万元以上1000万元以下的罚款。单位操纵证券市场的,还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处以50万元以上500万元以下的罚款。

（3）刑事责任。《刑法》第182条规定了操纵证券、期货市场罪

四、欺诈客户行为及其法律责任

欺诈客户是指证券公司及其从业人员在证券交易活动中诱骗投资者买卖证券以及其他违背投资者真实意愿、损害其利益的行为。

我国证券法律法规禁止的欺诈行为包括:

（1）违背客户的委托为其买卖证券;

- (2) 不在规定时间内向客户提供交易的书面确认文件;
- (3) 未经客户的委托,擅自为客户买卖证券,或者假借客户的名义买卖证券;
- (4) 为牟取佣金收入,诱使客户进行不必要的证券买卖;
- (5) 其他违背客户真实意思表示,损害客户利益的行为。

证券公司违背客户的委托买卖证券、办理交易事项,或者违背客户真实意思表示,办理交易以外的其他事项,给客户造成损失的,应当依法承担赔偿责任;同时,证券监管部门应给以警告,没收违法所得,并处以 1 倍以上 10 倍以下的罚款,没有违法所得或者违法所得不足 10 万元的,处以 10 万元以上 100 万元以下的罚款;情节严重的,暂停或者撤销相关业务许可。

讲解归纳与举例

【单选题】下列哪类人可能无法知悉内幕信息,成为知情人

- A.证券公司的清洁工
- B.公司董事
- C.上市公司收购人
- D.发行人公司监事会主席

【答案】A

【解析】证券交易内幕信息的知情人,是指知悉证券交易内幕信息的人员,清洁工的职责与证券交易无关,无法成为知情人。

第 9 章 期货交易法

本章重难点分析

- 1.把握期货交易的概念和法律特征,并在与其他类型公司的比较中发现期货公司的特殊性。
- 2.学习期货交易所和期货交易规则的具体内容。了解期货市场监管的方式和手段,把握现代监管的相关理念。

第 1 节 期货交易法概述

一、期货交易的含义

(一)期货交易的理论含义

期货交易有狭义、中义和广义三种解释。

在狭义上,期货交易仅指以期货合约作为交易标的的买入或卖出活动,可称为期货合约交易。

在中义上,期货交易包括期货交易和期权交易,指以期货合约和期权合约作为标的的买

入或卖出活动。

在广义上，期货交易还包括其他金融衍生品交易，甚至包括远期合约交易。

（二）我国期货交易的含义

根据《期货交易管理条例》第2条的规定，期货交易是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约作为交易标的的交易活动。我国现行法律所称期货交易，包含以下含义：

- （1）期货交易是指场内交易。
- （2）期货交易是指期货合约和期权合约的交易。
- （3）期货交易包括与期货交易有关的其他活动。

二、期货交易的法律特征

（一）期货交易的主体

期货交易主体分为三类，即期货交易者、期货交易所和期货经营者。

1. 期货交易者

期货交易者，即买入或卖出期货和期权合约的当事人，可称为买方或卖方，或统称为买卖双方或交易双方。

2. 期货交易所

期货交易所，也即期货市场组织者，是指依法经批准设立，制定期货和期权标准化合约，组织该标准化合约上市交易，提供期货合约成交和交收服务的期货交易所。

3. 期货经营者

按照期货交易的一般规则，能够进入期货交易所从事期货交易的，仅限于期货交易所认可的期货经营者。期货交易者从事期货交易时，必须委托期货经营者，才能从事证券交易所组织的期货交易。

（二）期货交易的客体

期货交易的客体是指期货合约或期权合约。

1. 期货合约

期货合约，是期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

2. 期权合约

期权合约，又称选择权合约，是指期货交易场所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物（包括期货合约）的标准化合约。

（三）期货交易的内容

期货交易的内容，即期货交易之买方或卖方的权利。

1.期货合约交易的内容

期货合约载明了在未来某个时间，以约定价格买入或卖出标的物的内容，期货交易者买入期货合约时，相当于做出了在未来某个时间、以约定价格买入标的物的承诺；期货交易者在卖出期货合约时，相当于做出了在未来某个时间、以约定价格卖出标的物的承诺。

2.期权合约交易的内容

按照期权合约的通常规则，期权合约的买方在支付权利金后，即取得在未来特定期限内依照特定价格和数量等条件，买入或卖出约定的标的物的权利；期权合约的卖方根据买方的要求，应当承担依约履行的义务，或者按照双方约定结算差价。

在期权合约交易中，买方的主要义务是支付权利金。权利金，又称权利费、期权费或期权金，是通过市场公开竞价形成的。

三、期货交易法

（一）境外期货交易法

期货交易法，是调整期货交易关系及相关活动的法律的总称。

1.期货交易单独立法模式

单独立法模式，即指单独制定的期货法或期货交易法，用以直接调整期货交易关系。

2.期货与证券交易合并立法模式

合并立法模式，指合并规范证券和期货的交易规则的立法模式。

3.金融商品统一立法模式

统一立法模式，指将有关金融商品交易的规则纳入统一的法律文件中。日本和韩国均曾采用单独立法模式，现在则将期货交易规则分别纳入《金融商品交易法》或《资本市场统一法》中。

（二）我国期货交易立法的演变

1999年6月，国务院颁布了《期货交易管理暂行条例》。2007年3月，国务院颁布《期货交易管理条例》，取代了《期货交易管理暂行条例》。2012年9月，国务院修订《期货交易管理条例》。2017年，国务院第二次修订《期货交易管理条例》并沿用至今。

（三）我国期货交易法律体系

1.行政法规

2.司法解释

3.部门规章

4.自律规范

5.期货交易规则

讲解归纳与举例

【多选题】下列哪些属于我国期货交易法律体系

A.行政法规

B.司法解释

C.部门规章

D.自律规范

E.期货交易规则

【答案】ABCDE

【解析】我国期货交易法律体系包括：行政法规、司法解释、部门规章、自律规范、期货交易规则。

第2节 期货交易参与者

一、期货交易者

期货交易者是指为了自己的利益，委托具有期货经纪业务资格的期货交易所会员，从事期货交易并自行承担期货交易损失和收益的企业、机构和个人。我国现行法规称其为“期货投资者”，期货经营机构通常将向其申请开户的期货交易者称为“客户”。

（一）期货交易者的资格

1.期货交易者的消极资格

根据《期货交易管理条例》第25条规定的消极资格，下列单位和个人不得从事期货交易，期货公司不得接受其委托为其进行期货交易：

（1）国家机关和事业单位；

（2）国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货业协会的工作人员；

（3）证券、期货市场禁止进入者；

（4）未能提供开户证明材料的单位和个人；

（5）国务院期货监督管理机构规定不得从事期货交易的其他单位和个人。

2.境外交易者的特殊资格

直接入场交易的境外交易者应当具备下列条件：（1）所在国（地区）具有完善的法律和

监管制度；（2）财务稳健，资信良好，具备充足的流动资本；（3）具有健全的治理结构和完善的内部控制制度，经营行为规范；（4）期货交易所规定的其他条件。

（二）期货交易者的种类

1. 自然人交易者和单位交易者

在我国期货交易实践中，自然人交易者通常受到更多的特殊保护。

2. 境内交易者和境外交易者

根据规定，境外交易者只能从事境内特定品种的期货交易，且境内特定品种的期货交易实行交易者适当性制度。

3. 套期保值者、套利者和投机者

这是根据期货交易者的交易目的做出的分类。

二、期货经营机构

期货经营机构是指接受期货交易者委托，为期货交易者办理期货交易的人。我国《期货交易管理条例》仅规定“期货公司”是期货经营机构，通常认为，期货经营机构不得采用独资企业或合伙企业的组织形式。

（一）期货公司的特殊性

1. 期货公司的性质

期货公司属于与银行、保险、证券和信托等并存的金融机构，期货公司必须领取国务院期货监督管理机构颁发的期货业务许可证；从事金融期货业务的证券公司，还要专门申领金融期货经纪业务许可证。除此以外，期货公司从业人员也必须取得规定的资格。

2. 期货公司的设立

期货公司的设立，必须遵守《公司法》和《期货交易管理条例》规定的条件和程序。在设立条件上，期货公司的最低注册资本限额不少于 3000 万元。

3. 期货公司的治理

根据《期货交易管理条例》规定，期货公司必须有健全的风险管理和内部控制制度。在机构设置上，期货公司除要设置股东会、董事会和经理外，还必须设置首席风险官、风险控制以及合规审查部门或岗位。

4. 期货公司的营业禁止

（1）不得从事与期货业务无关的活动，法律、行政法规或者国务院期货监督管理机构另有规定的除外；

（2）不得从事或者变相从事期货自营业务；

(3) 不得为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资，不得对外担保；

(4) 不得接受不具有期货交易者资格的人的委托，为其进行期货交易。

(二) 期货公司的特殊义务

期货公司从事的业务包括期货经纪业务、投资咨询业务和资产管理业务，不包括自营业务。

1. 资金和交易安全保障义务

2. 客户利益优先原则

3. 风险揭示义务

4. 客户信息保密义务

三、期货交易所

根据《期货交易管理条例》，期货交易所主要指期货交易所，也包括其他经批准进行期货交易的场所。

(一) 期货交易所的特点

1. 不以营利为目的

2. 依法设立和变动

3. 履行法定职责

4. 实行自律管理

(二) 期货交易所的类型

1. 金融期货交易所和商品期货交易所

按照期货交易所的营业范围，可将期货交易所分为金融期货交易所和商品期货交易所。

2. 会员制期货交易所与公司制期货交易所

根据《期货交易所管理办法》，期货交易所所有会员制和公司制两种。我国现有的三家商品期货交易所采用会员制形式，中国金融期货交易所采用公司制形式。

3. 专业期货交易所和兼业期货交易所

这是按照期货交易所的业务或上市品种进行的分类。专业期货交易所是指只提供期货交易服务的交易所。兼业期货交易所，是指主要提供商品或证券现货上市交易，同时提供部分期货品种上市交易的交易所。

四、期货结算机构

(一) 期货结算机构的概念和类型

期货结算，是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易结果进行的资金清算和划转。

我国现有的独立结算机构是中国证券登记结算有限责任公司，目前仅受托为上海、深圳证券交易所以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司提供结算服务。

（二）期货结算中的会员分级结算

《期货交易管理条例》第8条第2款规定，期货交易所可以实行会员分级结算制度。实行会员分级结算制度的期货交易所会员由结算会员和非结算会员组成。

在实务中，我国各期货交易所均采用分级结算规则。

会员分级结算，即指期货交易所仅与具有结算会员资格的会员办理结算，具有结算会员资格的会员再与非结算会员办理结算。反之，如果期货交易所不区分结算会员与非结算会员，而是允许全部会员与期货交易所办理结算，即为全员结算。

（三）期货结算机构的中央对手方地位

中央对手方，也称共同对手方，指期货结算机构在双边净额交收中介入了期货交易，成为结算会员之相对方。即在交收环节，期货结算机构成为卖方的买方、买方的卖方，并且有权动用结算会员交付的保证金或准备金承担交收责任，从而确保交收的顺利完成。

中央对手方是各国期货市场普遍采用的制度，通常依托于合同更新理论。即在期货交易合约成立后，期货结算机构介入买卖双方的关系中，买卖双方达成的原合同消灭，并被期货结算机构与买方、卖方形成的两个新合同所替代。

讲解归纳与举例

【多选题】下列哪些属于期货交易参与者

- A.自然人
- B.单位
- C.期货公司
- D.期货交易所
- E.期货结算机构

【答案】ABCDE

【解析】期货交易参与者包括：期货交易者、期货经营机构、期货交易所、期货结算机构等。

第3节 期货交易规则

一、保证金制度

（一）保证金的含义和形式

保证金是仅适用于狭义期货交易的概念，不适用于期权交易。

在期货交易中，期货交易者需要按照其交易的期货合约价值的一定比例，向期货经营机

构缴纳保证金，期货经营机构作为期货交易所的结算会员，也要按照其交易的期货合约价值的一定比例，向期货交易所缴纳期货交易保证金。

保证金只能用于结算和保证履约。在我国，保证金通常仅指资金。

根据《期货交易所管理办法》第 70 条规定，期货交易所可以接受部分有价证券充抵保证金，主要是：

- （1）经期货交易所认定的标准仓单；
- （2）可流通的国债；
- （3）中国证监会认定的其他有价证券。

以上述有价证券充抵保证金的，充抵的期限不得超过该有价证券的有效期限。

（二）保证金的分类

1.会员保证金和客户保证金

会员保证金，是指作为期货交易所会员的期货经营机构向期货交易所缴纳的保证金。

2.初始保证金和维持保证金

初始保证金，是指交易者在下单买卖期货合约时必须存入的最低履约保证金。维持保证金是期货交易所对会员、会员对客户保证金余额的最低要求。

3.结算保证金和交易保证金

结算保证金也称结算准备金，是期货交易所会员为了交易结算，在期货交易所专用结算账户中预先存放的资金，是未被期货合约占用的保证金。

（三）期货保证金的法律性质

1.保证金属于缴纳者的财产

2.保证金属于预交的资金

3.保证金是限定交易者之交易量的指标

4.期货合约的价值属于担保交收的资金

二、当日无负债结算制度

当日无负债结算，又称每日无负债结算、逐日盯市，是指当日交易结束后，期货交易所按照当日结算价对结算会员结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用。

当日结算价，是在正常交易的最后时刻确定的，用于计算期货经营机构和期货交易者账户的盈亏、追加保证金及交割的发票价格。

通常采用四种方法确定当日结算价格：

- （1）收盘时段集合竞价；

- (2) 收盘前一段时间成交量加权价；
- (3) 收盘价；
- (4) 收盘时刻最高与最低卖出价的平均价，按照最下波动价位取整数计算。

由于期货交易所会员存在结算会员和非结算会员之分，在执行当日无负债结算制度时，存在三层结算：

- (1) 期货交易所与结算会员之间的结算；
- (2) 结算会员与非结算会员之间的结算；
- (3) 结算会员或非结算会员与期货交易者之间的结算

三、持仓限额和大户持仓报告制度

(一) 持仓限额制度

持仓限额，指期货交易所对期货交易者的持仓量规定的最高数额。

持仓限额制度是期货交易所为防范操纵市场价格的行为，防止期货市场过度集中于少数投资者而定的制度

(二) 大户持仓报告制度

大户持仓报告，是指会员或客户在某一合约上的持仓量，达到期货交易所规定的持仓报告标准时，会员或客户应当向期货交易所报告的制度。

大户持仓报告是与持仓限额规则相关的交易风险控制制度。

四、涨跌停板制度和熔断机制

涨跌停板制度是限制期货合约成交价格波动的制度。所谓的涨跌停板，又称每日价格最大波动幅度限制，是指期货合约在一个交易日中的成交价格，不能高于或低于以该合约上一交易日结算价为基准的某一涨跌幅度，超过该范围的报价将视为无效，不能成交。

熔断机制，是指当期货合约成交价格涨跌幅度达到某一比例时，按照期货交易所规定暂停交易一定时间的制度。

我国期货交易所均采用涨跌停板制度，未采用熔断机制。

第4节 期货市场的监管

一、自律监管与行政监管

(一) 自律监管

自律监管，是指期货交易所及期货业协会等自律组织实施的监管，有时也包括期货经营机构在内部实施的各项控制措施。

我国现有的自律组织包括期货交易所和期货业协会。

自律监管的渗透性较强。期货经营机构的行为即使不违反法律和行政法规，只要违反了自律组织的规则，自律组织也能够启动纪律处分程序，实现对期货经营机构及其经营的柔性监管。

（二）行政监管

行政监管，通常是指国家授权的机关实施的行政监管。

在我国，证监会同时承担了证券市场和期货市场的监管职能。行政监管的监管依据，是法律和行政法规的授权。

行政监管机关有权在法律和行政法规规定的范围内，实施行政处罚。

二、行政监管的理念

（一）执行期货交易适当性规则

期货交易所应当制定良好的适当性操作指引，督促期货经营机构落实适当性管理操作指引，应当向市场提供适合于一般交易者交易的期货产品，使其能够公平享有利用期货市场风险管理功能的机会。

（二）跟进期货交易技术的发展

期货交易主要采用公开竞价方式，期货能否成交与报单技术密切相关。截至目前，期货交易技术经历了从手工报单向计算机报单的转变，并且正在面临从计算机报单向程序化交易的重大转变。

（三）建立适当的责任追究机制

传统的责任追究机制强调对违法者的惩戒，以减少未来发生违法行为的概率。这种惩戒型追究机制不完全契合于期货市场的特点，难以适应保护期货交易者的客观需求。

第 10 章 商事信托与投资基金法

本章重难点分析

- 1.掌握商事信托的概念和类型，理解商事信托设立的具体法律制度。
- 2.理解商事信托财产的范围和财产的独立性。掌握信托法律关系中各方当事人的权利、义务与责任。
- 3.掌握投资基金的概念和类型，把握证券投资基金的相关法律关系主体。

第 1 节 商事信托概述

一、我国法上的商事信托概念—营业信托

我国《信托法》第 3 条规定：“委托人、受托人、受益人（以下统称信托当事人）在中华人民共和国境内进行民事、营业、公益信托活动，适用本法。”

本书认为,我国的商事信托是个人或法人委托以经营信托业务为其营业的信托机构进行财产经营而设立的信托,即营业信托。

二、我国商事信托的类型

(一) 集合资金信托

集合资金信托是由受托人将两个以上委托人交付的资金进行集中管理、运用或处分的资金信托业务活动,是一种特定类型的营业信托业务。

(二) 企业年金信托

企业年金信托是指以信托方式管理企业年金的制度。

(三) 信贷资产证券化信托

信贷资产证券化信托也称特殊目的信托,是指依照法律规定,以资产证券化为目的而成立的信托关系。

(四) 保险资金信托

保险资金信托是利用信托的机制间接利用保险资金进行投资的信托模式。

三、我国商事信托的监管

信托公司作为营业信托最主要的经营主体,在我国属于金融机构而受到银行业监督管理机构即中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)的特别监管。

实践中,关于信托公司监督管理方面的法律规定,均体现为中国银保监会制定的相关部门规章。

四、民法典与商事信托

我国 2020 年颁布的《民法典》没有对信托做出基本规定,仅在第 1133 条中规定了遗嘱信托。但是,《民法典》对信托法律关系有着重要影响,因为《信托法》是《民法典》的特别法,《信托法》未做出特别规定的问题,可以适用《民法典》。例如,信托行为是民事法律行为,《民法典》关于民事法律行为的一般规定适用于信托行为。

第 2 节 商事信托的设立和生效

一、设立商事信托的意思表示

(一) 意思表示的形式

我国《信托法》第 8 条明确规定:“设立信托,应当采取书面形式。”

我国《证券投资基金法》所规定的基金合同也是设立营业信托的一种书面形式合同。

(二) 意思表示的内容

《信托公司管理办法》第 32 条规定,以信托合同形式设立信托时,信托合同应当载明

的事项除《信托法》中规定的上述必备内容外，还包括：

- （1）信托当事人的权利义务；
- （2）信托财产管理中风险的揭示和承担；
- （3）信托财产的管理方式和受托人的经营权限；
- （4）信托利益的计算，向受益人交付信托利益的形式、方法；
- （5）信托公司报酬的计算及支付；
- （6）信托财产税费的承担和其他费用的核算；
- （7）信托期限和信托的终止；
- （8）信托终止时信托财产的归属；
- （9）信托事务的报告；
- （10）信托当事人的违约责任及纠纷解决方式；
- （11）新受托人的选任方式。

（三）意思表示的真实

意思表示真实是法律行为的有效条件之一。

意思表示不真实包括欺诈、胁迫、乘人之危和重大误解等几种情形，不同情形对于信托行为具有不同的影响。

需要注意的是，在欺诈的认定上，消极地隐瞒事实真相的行为在一般民事信托中不构成欺诈，但在商事信托的一些业务中，受托人有主动告知的义务。

二、商事信托的当事人资格

（一）委托人资格

对于商事信托的委托人，我国《信托公司管理办法》未对其资格做出特殊的规定。对于特定类型的营业信托，不同的规范性文件对委托人的资格有一定的要求。

1.集合资金信托计划：合格投资者必须是能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人；

2.信贷资产证券化信托

3.企业年金信托

4.保险资金信托

（二）受托人的特殊资格

营业信托的受托人必须是信托机构。

营业信托的受托人从设立到运营到形式，都有明确的法律法规上的规定。

首先，从设立上看，信托公司的设立必须经中国银行业监督管理机构批准，并领取金融

许可证；

其次，从形式上看，信托公司必须采取有限责任公司或股份有限公司的形式，其他类型的法人、其他组织以及个人不能成为营业信托的受托人；

最后，从监管上看，营业信托的受托人及其业务活动受中国银行业监督管理机构监管 1. 企业年金信托受托人资格

- (1) 经国家金融监管部门批准，在中国境内注册；
- (2) 注册资本不少于 1 亿元人民币，且在任何时候都维持不少于 1.5 亿元人民币的净资产；
- (3) 具有完善的法人治理结构；
- (4) 取得企业年金基金从业资格的专职人员达到规定人数；
- (5) 具有符合要求的营业场所、安全防范设施和与企业年金基金受托管理业务有关的其他设施；
- (6) 具有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度；
- (7) 近 3 年没有重大违法违规行为。

2. 信贷资产证券化受托人的资格

在信贷资产证券化中，受托人为特定目的受托机构。

而信托公司要担任特定目的受托机构，也必须满足一定的条件，主要包括：

- (1) 根据国家有关规定完成重新登记 3 年以上；
- (2) 注册资本不低于 5 亿元人民币，并且最近 3 年年末的净资产不低于 5 亿元人民币；
- (3) 自营业务资产状况和流动性良好，符合有关监管要求；
- (4) 原有存款性负债业务全部清理完毕，没有发生新的存款性负债或者以信托等业务名义办理的变相负债业务；
- (5) 具有良好的社会信誉和经营业绩，到期信托项目全部按合同约定顺利完成，没有挪用信托财产的不良记录，并且最近 3 年内没有重大违法违规行为；
- (6) 具有良好的公司治理结构、信托业务操作流程、风险管理体系和内部控制；
- (7) 具有履行特定目的信托受托机构职责所需要的专业人员、业务处理系统、会计核算系统、管理信息系统以及风险管理和内部控制制度；
- (8) 已按照规定披露公司年度报告；
- (9) 中国银行业监督管理机构规定的其他审慎性条件。信贷资产证券化受托人的资格采取审批制，信托公司要担任信贷资产证券化受托人，其资格的取得必须获得中国银行业监督管理机构的事先批准。

3. 保险资产投资信托的受托人资格

该办法规定，受托人设立投资计划，应当具备相应的投资管理能力。

三、商事信托设立的目的

我国《信托法》第6条规定：“设立信托，必须有合法的信托目的。”

目前被广泛承认的非法的信托目的包括但不限于：欺诈债权人、专为诉讼或者讨债、规避强制性法律规定。

第3节 商事信托财产

一、商事信托财产的范围

（一）经营权信托问题

从实际需要与经营权的性质与内容来看，经营权特别是以收费权为核心的基础设施经营权与土地承包经营权作为一种财产权，具有一定的独立性，具有财产价值，同时具有可让与性及与所有权一定时间内的分离特征，因此可以作为信托财产，但经营权作为信托财产受该经营权本身的性质的限制，如监管类企业的经营权，不仅受企业所有权的限制，而且受监管政策的限制，未经许可，不得转让或抵押，也不能作为信托财产在其上设立信托。

（二）股权或其他资产收益权信托问题

股权或资产信托涉及所有权的名义的转移以及对股权或资产的管理与控制权及其他相关权利的转移，而实践中，很多股权或资产持有人并不愿意失去对股权或资产的控制与管理权，同时又希望通过股权或资产进行融资，于是出现了一种新型的信托，即将股权或其他资产的收益权独立出来，作为信托财产设立信托。

（三）表决权信托问题

单独的表决权不能成为信托财产。但是，它可以存在于股权信托中，以股权信托的方式实现股东集中行使表决权的目，同时，通过受益权的安排，保留真实股东收益上的权利。

（四）将来权利和期待权信托问题

这两类财产权能否成为信托财产，关键是看它们的现时存在性。

将来权利是将来能够实现的权利，只要经过合法的批准或合同上的约定，可以转化为实际的财产期待权不具有财产确定性的特征，不能成为信托财产。

二、信托财产的独立性

（一）信托财产相对于委托人的独立性

1. 信托财产与未设立信托财产相区别

委托人一旦将信托财产交付给受托人，信托生效，委托人对信托财产的所有权就转移给

受托人，对信托财产，委托人就不再享有所有权，仅享有对信托的监督权及与之相关的权利。

2.除特定情形外，信托财产不属于委托人的遗产或清算财产

3.强制执行禁止。我国《信托法》第 17 条明确规定，除该条规定的情形外，不得对信托财产强制执行，这些情形包括：（1）设立信托前债权人已对该信托财产享有优先受偿的权利，并依法行使该权利的；（2）受托人处理信托事务所产生债务，债权人要求清偿该债务的；（3）信托财产本身应负担的税款；（4）法律规定的其他情形。

（二）信托财产相对于受托人的独立性

第一，禁止将信托财产与受托人财产混同。

第二，信托财产不属于受托人的遗产或清算财产。

第三，信托财产产生的债权不得与受托人固有财产产生的债务相抵销，也不得与受托人管理运用、处分其他委托人的信托财产所产生的债务相抵销。

第四，强制执行禁止。

（三）信托财产相对于受益人的独立性

（1）如果受益人有继承人的，信托应继续存续，信托财产不作为遗产。

（2）如果受益人是法人，被清算，则实际上信托目的已无法实现，根据《信托法》第 54 条的规定，信托终止，信托财产按信托文件的规定归于清算财产或信托文件指定的其他人。

（四）信托财产损益的独立性

在信托存续期间，受托人在处理信托过程中产生的收益和其他信托利益，归于信托财产，非受托人过失或其他人过失或侵权导致的信托财产的损失由信托财产承担。

讲解归纳与举例

【单选题】商事信托财产的范围不包括？

- A.物权
- B.承租权
- C.知识产权
- D.人身权

【答案】D

【解析】信托财产必须是财产或财产性权利，人身权不具有金钱价值，不能成为信托财产。

第 4 节 信托当事人

一、信托当事人概述

信托有三方当事人，即委托人、受托人和受益人

1.信托当事人任何一方依法可以为多人

2.信托当事人依法可以竞合

3.受益人无须参与信托的设立

4.受益人无须设立时存在

二、受托人

（一）受托人概述

信托关系中的受托人，是指接受委托人的委托，为受益人的利益或者特定目的，对信托财产进行管理或者处分的人。

1.受托人的资格

我国《信托法》第 24 条规定，受托人应当是具有完全民事行为能力的自然人、法人。法律、行政法规对受托人的条件另有规定的，从其规定。

2.共同受托人

同一信托可以同时存在两个或两个以上的受托人，称为共同受托人。

（二）受托人的权利

依据权利所包含的利益类型的不同，可以将其划分为“与履责相关的权利”和“与自身利益相关的权利”两类。

1.与履责相关的权利——履责权

- （1）信托财产的名义所有权。
- （2）信托财产的管理和处分权。
- （3）对信托财产不当强制执行的异议权。
- （4）代表信托起诉和应诉权。

2.与自身利益相关的权利——私益权

- （1）报酬请求权。
- （2）补偿的权利。

3.受托人的辞任权

根据《信托法》的规定，若是私益信托，受托人征得委托人和受益人双方同意后，可以辞任，以解除信托文件的束缚。

（三）受托人的义务

在信托法律关系中，受托人负有的义务统称为信义义务。

1.信托文件的遵守义务

2.忠实义务：禁止牟利、禁止转为固有财产

3.谨慎义务

4.分别管理义务

5.亲自管理义务

6.记录、报告和保密义务

7.清算义务

（四）受托人职责的终止

1.受托人死亡或者被依法宣告死亡

2.受托人被依法宣告为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人

3.受托人被依法撤销、被宣告破产、解散或者法定资格丧失

4.受托人辞任或者被解任

5.法律、行政法规规定的其他情况

（五）受托人的责任

1.受托人的内部责任

（1）受托人的有限责任：受托人以信托财产为限向受益人承担支付信托利益的义务。

（2）受托人的赔偿责任。受托人在有过失情形下应当承担赔偿责任。

2.受托人的外部责任：受托人因处理信托事务所支出的费用、对第三人所负债务，以信托财产承担。

3.共同受托人的连带责任

三、委托人

（一）委托人的权利

1.委托人的法定权利

（1）知情权

（2）信托财产管理方法调整的要求权

（3）信托财产处分行为撤销的申请权

（4）对受托人的解任权

（5）剩余信托利益的归复权

（6）信托的解除权

（7）受益人的变更权和受益权的处分权

（8）信托财产损害的救济权

（9）受益权损害的救济权

2.委托人的保留权利

（1）委托人保留权利的原则

信托是委托人创设的，按照意思自治原则，委托人可以在信托文件中为自己保留一定的权利。但委托人保留的权利在客观上存在限制，即不能使委托人像信托财产的所有者那样任意处分信托财产。

（2）委托人保留权利的范围

第一，管理权的保留。

第二，受益人或受益权变更权的保留。

第三，受托人解任权的保留。

（二）委托人的义务

1.转移信托财产的义务

2.支付报酬和提供补偿的义务

讲解归纳与举例

【单选题】下列哪项不属于信托当事人？

A.委托人 B.受托人 C.受益人 D.代理人

【答案】D

【解析】信托有三方当事人，即委托人、受托人和受益人。

第5节 信托的变更与终止

一、信托的变更

（一）信托变更的含义与依据

1.信托变更的含义

信托的变更，是指信托有效设立后，当出现约定或者法定的变更事由时，信托当事人依法对信托文件所规定的事项进行的改变和调整。

2.信托变更的依据

（1）约定变更。

（2）法定变更。

（二）信托的约定变更

在约定变更的情况下，作为变更依据的约定，可以有两种形式：一是信托文件关于变更的规定；二是信托当事人另行变更的意思表示。

1.信托文件规定的变更

如果信托文件对有关信托事项做出了明确的变更规定，只要该规定不违反法律，信托当事人可以依据该规定对相应的信托事项进行变更。

2.信托当事人的另行变更

仅有委托人和受托人的意思表示行为是不够的，还需要有受益人的意思表示。

（三）信托的法定变更

对于信托文件所规定的事项，如果信托当事人没有变更的约定，原则上不得变更，只有出现法定的变更事由时，才允许依法变更。

1.信托财产管理方法的法定变更

2.受托人的法定变更

3.受益人和受益权的法定变更

（1）受益人有重大侵权行为。

（2）受益权的继受。

二、信托的终止

信托的终止，是指因出现法定或者约定的事由而使信托关系归于消灭。

（一）信托的连续性

1.委托人或受托人欠缺的情形

2.信托不因委托人或受托人的欠缺而终止

（1）信托不因委托人的欠缺而终止。

（2）信托不因受托人的欠缺而终止。

（3）例外规定。

（二）信托终止的事由

根据《信托法》第 53 条的规定，信托终止的事由有六种：

（1）信托文件规定的终止事由发生；

（2）信托当事人协商同意；

（3）信托的存续违反信托目的；

（4）信托目的已经实现或者不能实现；

（5）信托被撤销；

（6）信托被解除。

（三）信托终止的法律后果信托终止的法律后果包括：

- (1) 信托效力的消灭;
- (2) 信托财产权利归属人的确认;
- (3) 法定信托的成立;
- (4) 信托财产的强制执行;
- (5) 受托人报酬和补偿权的行使;
- (6) 信托的清算;
- (7) 受托人责任的解除。

第6节 投资基金

一、投资基金的概念

投资基金是一种利益共享、风险共担的集合投资制度。

它通过集合特定的或不特定的投资者,将原本由投资者分散持有的资金集中起来,委托具有专门知识和经验的投资专家经营操作,使中小投资者得以在享受基金投资丰厚报酬的同时,减少投资风险。

二、投资基金的特征

(一) 集合投资

投资基金由不特定多数人的零散资金汇集而成。

(二) 专业理财

投资基金一般通过委托具有专门知识和经验的投资专家,对资金进行经营操作。

(三) 组合投资、分散风险

现代经济学理论表明,投资者进行组合投资、增加所持财产的多样性,能够显著地分散、降低投资风险。

(四) 利益共享、风险共担

投资基金的投资者在按照所持基金份额的多少分享投资收益时,也要按照相同的比例承担风险、损失。

三、投资基金的种类

(一) 公募基金和私募基金

根据基金募集方式的不同,投资基金的种类可以分为公募基金和私募基金。

公募基金是以公开发行人方式向社会公众投资者募集资金的投资基金,具有发行范围广、发行数量大、流动性强的特点。

根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》第2条的规定,私募基金是指在中华人民

共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金。

（二）公司型投资基金和契约性投资基金

根据投资基金设立的法律基础不同，投资基金的种类可以分为公司型投资基金和契约型投资基金。

公司型投资基金是具有共同投资目标的投资者依据公司法组成以盈利为目的、投资于特定对象（如各种有价证券、货币）的股份制投资公司。

契约型投资基金也称信托型投资基金，是根据一定的信托契约原理，由基金发起人和基金管理人、基金托管人订立基金契约而组建的投资基金。

（三）证券投资基金和产业投资基金

根据基金财产投资对象的不同，投资基金的种类可以分为证券投资基金和产业投资基金。证券投资基金以证券投资作为主要的投资目标。

产业投资基金是指一种对未上市企业进行股权投资和提供经营管理服务的利益共享、风险共担的集合投资制度。

（四）封闭型基金和开放型基金

根据基金份额变现方式的不同，投资基金的种类可以分为封闭型基金和开放型基金。封闭型基金，即资本形成固定，且在一定期限内不能要求偿还的一种基金。

开放型基金，即资本形成不完全固定，其已发行基金可以按净资产价值赎回的一种基金形式。

四、投资基金的法律关系主体

（一）基金管理人

1.基金管理人的资格

该法第 13 条规定：“设立管理公开募集基金的基金管理公司，应当具备下列条件，并经国务院证券监督管理机构批准：

（一）有符合本法和《中华人民共和国公司法》规定的章程；

（二）注册资本不低于一亿元人民币，且必须为实缴货币资本；

（三）主要股东应当具有经营金融业务或者管理金融机构的良好业绩、良好的财务状况和社会信誉，资产规模达到国务院规定的标准，最近三年没有违法记录；

（四）取得基金从业资格的人员达到法定人数；

（五）董事、监事、高级管理人员具备相应的任职条件；

（六）有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金管理业务有关的其他设施；

(七)有良好的内部治理结构、完善的内部稽核监控制度、风险控制制度;

(八)法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。”

2.基金管理人的职责

《证券投资基金法》第 19 条规定:“公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责:

(一)依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;

(二)办理基金备案手续;

(三)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

(四)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

(五)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(六)编制中期和年度基金报告;

(七)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

(八)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

(九)按照规定召集基金份额持有人大会;

(十)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

(十一)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

(十二)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。”

(二)基金托管人

1.基金托管人的资格:

(一)净资产和风险控制指标符合有关规定;

(二)设有专门的基金托管部门;

(三)取得基金从业资格的专职人员达到法定人数;

(四)有安全保管基金财产的条件;

(五)有安全高效的清算、交割系统;

(六)有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金托管业务有关的其他设施;

(七)有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度;

(八)法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构规定的其他条件。”

2.基金托管人的职责

《证券投资基金法》第 36 条规定:“基金托管人应当履行下列职责:

(一)安全保管基金财产;

- (二) 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
- (三) 对所托管的不同基金财产分别设置账户, 确保基金财产的完整与独立;
- (四) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
- (五) 按照基金合同的约定, 根据基金管理人的投资指令, 及时办理清算、交割事宜;
- (六) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
- (七) 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;
- (八) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
- (九) 按照规定召集基金份额持有人大会;
- (十) 按照规定监督基金管理人的投资运作;
- (十一) 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。”

(三) 投资基金的投资者

1.投资者的资格

合格投资者, 是指达到规定资产规模或者收入水平, 并且具备相应的风险识别能力和风险承受能力、其基金份额认购金额不低于规定限额的单位和个人。合格投资者的具体标准由国务院证券监督管理机构规定。

2.投资者的权利

《证券投资基金法》第 46 条规定: “基金份额持有人享有下列权利:

- (一) 分享基金财产收益;
- (二) 参与分配清算后的剩余基金财产;
- (三) 依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
- (四) 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
- (五) 对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
- (六) 对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为;
- (七) 基金合同约定的其他权利。

讲解归纳与举例

【单选题】投资基金的法律关系主体不包括以下哪项?

- A.基金管理人
- B.基金托管人
- C.投资者
- D.受益人

【答案】D

【解析】证券投资基金法律关系的主体包括：基金管理人、基金托管人、投资基金的投资者

第 11 章 破产法

本章重难点分析

- 1.把握破产及破产法在广义、狭义中的不同含义，理解破产程序中的相关主体概念和特征。
- 2.掌握破产费用和共益债务的拨付与清偿规则，理解破产程序中的别除权、撤销权、取回权、抵销权的区别和联系。
- 3.把握破产重整、破产和解与破产清算的关系。理解三种制度具体的内容和相关程序

第 1 节 破产法概述

一、破产与破产法的概念

一般所谓破产，是指法律意义上的破产，具体包括狭义和广义两种。

狭义上的破产，特指清算型破产，它是指当债务人不能清偿到期债务时，由法院根据当事人的申请对破产案件予以受理后，将破产财产公平分配给全体债权人的清算程序。

广义上的破产，则除狭义破产外，还包括预防型破产，它是指当债务人不能清偿到期债务时，由法院根据当事人的申请（有的立法例中法院可依职权），对债务人实施的挽救性程序以及就债务人的全部财产实行的概括性清算程序的统称。

狭义上的破产法，是指在债务人出现破产原因时，宣告其破产并对债务人的全部财产进行清算的法律制度的总称；

广义上的破产法，则是指在债务人出现破产原因时，宣告其破产并对债务人的全部财产进行清算，或者为避免债务人进入破产清算程序而建立起来的破产预防法律制度的总称。

二、破产申请与受理

（一）破产程序开始的要件

破产程序开始的要件，简称“破产要件”，是指启动或者进入一项破产程序所必须具备的条件。广义上的破产程序开始的要件通常可分为破产程序要件和破产实体要件。

1.破产能力

破产能力，是指债务人能够适用破产程序解决债务清偿问题的资格，亦即民事主体得被宣告破产的资格。

2.破产原因

破产原因，是指认定债务人丧失债务清偿能力，法院据以启动破产程序，宣告债务人破产的法律标准，即引起破产程序发生的原因。

（二）破产申请

破产申请，是破产申请人依法向法院提出，要求宣告债务人破产以清偿债务的请求。破产申请人，是指有权向法院提出破产申请的人。

依《企业破产法》第7条及第134条的规定，破产申请的提出分为以下四种情形：

（1）债务人提出破产申请。债务人有《企业破产法》第2条规定的情形的，可以向人民法院提出重整、和解或者破产清算申请。

（2）债权人提出破产申请。债务人不能清偿到期债务的，债权人可以向人民法院提出对债务人进行重整或者破产清算的申请。

（3）依法负有清算责任的人提出破产申请。企业法人已解散但未清算或者未清算完毕，资产不足以清偿债务的，依法负有清算责任的人应当向人民法院申请破产清算。企业法人解散时，按照法律规定应当成立清算组依法进行清算。

（4）国务院金融监督管理机构提出破产申请。

依我国《企业破产法》第8条的规定，提出破产申请，应当提交破产申请书和有关证据。人民法院受理破产申请前，申请人可以请求撤回申请。

（三）破产案件的管辖

破产案件的管辖，是指各级人民法院及同级人民法院之间受理破产案件的分工权限。

我国《企业破产法》第3条明确规定：“破产案件由债务人住所地人民法院管辖。”债务人住所地是指债务人的主要办事机构所在地。债务人无办事机构的，由其注册地人民法院管辖。

（四）破产申请的受理

1.破产申请受理的程序

破产程序的开始不以破产申请的提出为标志，破产申请只有经人民法院受理后，才正式启动破产程序。债权人提出破产申请的，人民法院应当自收到申请之日起5日内通知债务人。债务人对申请有异议的，应当自收到人民法院的通知之日起7日内向人民法院提出。人民法院应当自异议期满之日起10日内裁定是否受理。债务人对申请提出异议的，人民法院应当自收到破产申请之日起15日内裁定是否受理。特殊情况需要延长裁定受理的期限的，经上一级人民法院批准，可以延长15日。

2.破产申请受理的法律效力

- （1）债务人的有关人员应当承担法定义务；
- （2）债务人对个别债权人的债务清偿无效；

- (3) 债务人的债务人或者财产持有人应当向管理人清偿债务或者交付财产；
- (4) 管理人有权决定解除或者继续履行债务人和对方当事人均未履行完毕的合同；
- (5) 有关债务人财产的保全措施应当解除，执行程序应当中止；
- (6) 已经开始而尚未终结的有关债务人的民事诉讼或者仲裁应当中止；
- (7) 受理破产的人民法院对于有关债务人的民事诉讼进行专属管辖。

三、破产管理人

(一) 破产管理人的概念

破产管理人，是指依照破产法的规定，在破产重整、破产和解与破产清算程序中负责债务人财产管理和其他事项的专门机构。

(二) 破产管理人的选任

1. 破产管理人的选任方式

我国《企业破产法》第 22 条规定：破产管理人由人民法院指定；债权人会议认为管理人不能依法、公正执行职务或者有其他不能胜任职务情形的，可以申请人民法院予以更换。

2. 破产管理人的选任范围与任职资格

我国破产管理人可以是清算组或者相应的社会中介机构，也可以是自然人。

《企业破产法》第 24 条第 3 款规定，具有下列情形之一的自然人、清算组织或者社会中介机构，不得担任破产管理人：

- (1) 因故意犯罪受过刑事处罚；
- (2) 曾被吊销相关专业执业证书；
- (3) 与本案有利害关系；
- (4) 人民法院认为不宜担任管理人的其他情形。

(三) 破产管理人的职责与监督

1. 破产管理人的职责

我国《企业破产法》第 25 条围绕破产财产的保管、清理、估价、处理和分配等对破产管理人的职责做了明确规定。

2. 破产管理人的权利与义务

我国《企业破产法》第 27、29 条规定：破产管理人应当勤勉尽责，忠实执行职务；破产管理人没有正当理由不得辞去职务；破产管理人辞去职务应当经人民法院许可。

3. 对破产管理人的监督

我国《企业破产法》第 23 条规定：“管理人依照本法规定执行职务，向人民法院报告工

作，并接受债权人会议和债权人委员会的监督。管理人应当列席债权人会议，向债权人会议报告职务执行情况，并回答询问。”

四、破产债权的申报

债权申报，是指债权人在人民法院受理破产申请后，依照法定程序主张并证明其债权的存在，以便参加破产程序的法律行为。

（一）债权申报规则

1.破产程序中的债权人与债权申报的受理主体。

破产债权人，是指在人民法院受理破产申请时对债务人享有债权的人。依我国《企业破产法》第 48 条第 1 款的规定，债权申报的受理主体是破产管理人。

2.债权的申报期限

债权人申报债权，应当遵守法律规定的期限。债权人未在法律规定的期限申报债权，只能依补充申报程序行使权利。

3.债权申报的要求

依我国《企业破产法》第 49 条的规定，一般情况下，债权人在申报债权时应当符合以下要求：

- （1）应当说明债权的数额和有无财产担保的情况；
- （2）申报债权必须以书面形式提出；
- （3）债权人申报债权应当提交有关的证据；
- （4）申报的债权是连带债权的，应当说明。

4.债权的补充申报

在人民法院确定的债权申报期限内，债权人未申报债权的，可以在破产财产最后分配前补充申报；但是，此前已进行的分配，不再对其补充分配。

（二）债权表的编制与核查

1.债权表的编制

破产管理人收到债权申报材料后，应当登记造册，对申报的债权的真实性进行初步审查，并编制债权表。

2.债权表的核查

破产管理人在编制债权表过程中应尽审查义务。

五、债权人会议

债权人会议，是在破产程序进行中，为便于全体债权人参与破产程序，以实现其破产程

序参与权，维护全体债权人的共同利益，由全体登记在册的债权人组成的表达债权人意志和统一债权人行动的议事机构。

（一）债权人会议的组成与运行

依法申报债权的债权人为债权人会议的成员，有权参加债权人会议，享有表决权。债权人可以委托代理人出席债权人会议，行使表决权。

债权人会议设主席一人，由人民法院从有表决权的债权人中指定。债权人会议主席主持债权人会议。债权人会议可设列席人员。

依我国《企业破产法》第 126 条的规定，有义务列席债权人会议的债务人的有关人员，经人民法院传唤，无正当理由拒不列席债权人会议的，人民法院可以拘传，并依法处以罚款；债务人的有关人员违反该法规定，拒不陈述、回答，或者作虚假陈述、回答的，人民法院可以依法处以罚款。

（二）债权人委员会

我国《企业破产法》第 67 条明确规定：“债权人会议可以决定设立债权人委员会。”

债权人委员会由债权人会议选任的债权人代表和 1 名债务人的职工代表或者工会代表组成。债权人委员会成员不得超过 9 人。债权人委员会成员应当经人民法院书面决定认可。

讲解归纳与举例

【单选题】我国法律规定，破产案件由哪个法院管辖？

- A.债务人住所地人民法院
- B.债务人财产所在地人民法院
- C.债权人住所地人民法院
- D.债权人户籍所在地人民法院

【答案】A

【解析】我国《企业破产法》第 3 条明确规定：“破产案件由债务人住所地人民法院管辖。”债务人住所地是指债务人的主要办事机构所在地。债务人无办事机构的，由其注册地人民法院管辖。

第 2 节 破产财产的清理

一、概述

（一）破产财产的概念与性质

债务人财产，是指破产申请受理时属于债务人的全部财产，以及破产申请受理后至破产程序终结前债务人取得的财产。债务人财产在我国指的是破产财产。

（二）破产财产的范围

依我国《企业破产法》第 30 条的规定，破产财产的范围包括以下两个部分：

- （1）破产申请受理时属于债务人的全部财产；
- （2）破产申请受理后至破产程序终结前债务人取得的财产，即破产法理论中的“新得财产”。

二、破产债权、破产费用与共益债务

（一）破产债权

1.破产债权的概念与特征

破产债权，是指人民法院受理破产申请时对债务人享有的依法申报并获得确认的，债务人进入破产清算程序之后有权参与分配的债权。

破产债权具有以下法律特征，同时亦为其构成要件：

- （1）须为基于破产程序开始前的原因成立；
- （2）须为财产上的请求权；
- （3）须为可以强制执行的债权；
- （4）须为经依法申报并获确认、有权在破产财产中受偿的债权。

2.破产债权的范围

我国的破产立法并没有对破产债权的具体范围进行明确列举。

（二）破产费用

破产费用，是指法院在受理破产案件时收取的案件受理费以及破产程序进行中为全体债权人利益和程序进行所必需而支付的各项费用的总称。

破产费用的范围包括：

- （1）破产案件的诉讼费用；
- （2）债务人财产的管理、变价和分配所需费用；
- （3）破产管理人执行职务的费用、报酬和聘用工作人员的费用。

（三）共益债务

共益债务，是指在破产程序开始后，为了全体债权人的共同利益以及破产程序的顺利进行而负担的债务。

依我国《企业破产法》第 42 条的规定，共益债务的范围具体包括：

- （1）因破产管理人或者债务人请求对方当事人履行双方均未履行完毕的合同所产生的债务；
- （2）债务人财产受无因管理所产生的债务；
- （3）因债务人不当得利所产生的债务；

- (4) 为债务人的继续营业而应支付的劳动报酬和社会保险费用以及由此产生的其他债务；
- (5) 破产管理人或者相关人员执行职务致人损害所产生的债务；
- (6) 债务人财产致人损害所产生的债务。

(四) 破产费用和共益债务的拨付与清偿规则

第一，破产费用和共益债务由债务人财产随时清偿。

第二，破产费用优先清偿。

第三，按比例清偿。

第四，债务人财产不足以支付破产费用时破产程序的处理。

三、破产程序中的别除权、撤销权、追回权

(一) 破产别除权

破产别除权，是指债权人不依破产清算程序，就属于破产人的特定财产个别优先受偿的权利。

(二) 破产撤销权

破产撤销权，是指破产管理人拥有的，对于债务人在临近破产程序开始的期间内实施的有害于债权人利益的行为，于破产程序开始后予以撤销并将撤销利益归于破产财产的权利。依《企业破产法》第 31、32 条的规定，破产撤销权的适用范围主要有以下行为：

- (1) 无偿转让财产；
- (2) 以明显不合理的价格进行交易；
- (3) 对原来没有财产担保的债务提供财产担保；
- (4) 对未到期的债务提前清偿；
- (5) 放弃债权；
- (6) 在人民法院受理破产申请前 6 个月，债务人在具备破产原因时仍对个别债权人进行清偿的，除非个别清偿使债务人财产受益，管理人有权请求人民法院对该个别清偿行为予以撤销。

(三) 破产追回权

破产追回权，是指在破产程序中，破产管理人对于其行使撤销权与主张债务人实施行为无效而取得的债务人的财产以及其他应归属于债务人的财产予以追回的权利。

第一，破产管理人行使破产撤销权而应取得的债务人的财产。

第二，破产管理人主张债务人实施的行为无效而应取得的债务人的财产。

第三，人民法院受理破产申请后，债务人的出资人尚未完全履行出资义务的，破产管理

人应当要求该出资人缴纳所认缴的出资，而不受出资期限的限制。

第四，债务人的董事、监事和高级管理人员利用职权从企业获取的非正常收入和侵占的企业财产，破产管理人应当追回。

四、破产取回权

（一）破产取回权的概念与特征

破产取回权，是指在破产程序中，对不属于债务人的财产，其所有人或者其他权利人不依照破产程序，通过破产管理人将该财产予以取回的权利。

- （1）破产取回权的行使具有绝对性和无条件性；
- （2）破产取回权的标的物是破产人占有的不属于破产人所有的财产；
- （3）破产取回权人对取回权的标的物享有所有权或者支配权；
- （4）破产取回权的行使不依破产程序，但必须以破产管理人为相对人。

（二）破产取回权的种类

依标的物占有情形的不同，可将破产取回权分为一般取回权和特殊取回权。

1.一般取回权

一般取回权，是指不属于破产财产法定范围内的财产，已经为破产管理人实际占有，取回权人所享有的不依破产程序即可取回的请求权。这种取回权以破产人或者破产管理人现在占有取回权标的物为特征。

2.特殊取回权

特殊取回权，通常是指出卖人取回权、行纪人取回权和代偿取回权。其中，具有典型意义的是出卖人取回权。

五、破产抵销权

（一）破产抵销权的概念与特征

破产抵销权，是指债权人在破产案件受理前对债务人负有债务的，无论其债权与所负债务种类是否相同，也不论该债权、债务是否附有期限或条件，均可以用该债权抵销其对债务人所负债务的权利。

我国《企业破产法》第40条第1句规定：“债权人在破产申请受理前对债务人负有债务的，可以向管理人主张抵销。”

（二）破产抵销权的禁止

破产抵销权使得债权人的债权与其对债务人所负债务同归消灭，实际上导致债权获得完全的清偿，从而避免了和其他债权人一样接受破产财产分配获得比例清偿的损失。

《企业破产法》第 40 条规定，有下列情形之一的，不得抵销：

（1）债务人的债务人在破产案件受理后取得他人对债务人的债权的。

（2）债权人已知债务人有不能清偿到期债务或者破产申请的事实，对债务人负担债务的；但是，债权人因为法律规定或者有破产申请 1 年前所发生的原因而负担债务的除外。

（3）债务人的债务人已知债务人有不能清偿到期债务或者破产申请的事实，对债务人取得债权的；但是，债务人的债务人因为法律规定或者有破产申请 1 年前所发生的原因而取得债权的除外。

讲解归纳与举例

【单选题】下列哪种情形债权人可以行使破产别除权？

- A. 债务人无偿转让财产
- B. 债务人低价转让财产
- C. 债务人转移财产
- D. 债权人对债务人的财产享有担保物权

【答案】D

【解析】破产别除权，是指债权人不依破产清算程序，就属于破产人的特定财产个别优先受偿的权利。

第 3 节 破产重整制度

一、破产重整制度的概念与特征

破产重整制度，是指经由利害关系人申请，在法院的主持和利害关系人的参与下，对具有重整原因和重整能力的债务人进行生产经营上的整顿和债权债务关系上的清理，以使其摆脱财务困境，重获经营能力的破产预防制度。

破产重整制度具有以下基本特征：

第一，重整的原因比较宽泛。

第二，程序的启动更多地体现了私法自治的色彩。

第三，担保物权受到限制。

第四，目标的多元化与重整措施的多样化。

二、重整程序的启动

（一）重整申请的提出

依我国《企业破产法》第 70 条的规定，有权提出重整申请的人包括债务人、债权人以及债务人的出资人。

1.债务人申请重整

（1）当债务人不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力，或者有明显丧失清偿能力可能时，可以向人民法院申请进行重整；

（2）债权人申请对债务人进行破产清算的，在人民法院受理破产案件后、宣告债务人破产前，债务人为了避免破产倒闭，可以向人民法院申请进行重整。

2.债权人申请重整

当债务人不能清偿对债权人的到期债务时，债权人即可直接向人民法院提出对债务人进行重整的申请。

3.债务人的出资人申请重整

（1）申请的时期必须是在债权人申请对债务人进行破产清算时，在人民法院受理破产案件后、宣告债务人破产前；

（2）只有占债务人注册资本 1/10 以上的出资人才有资格向人民法院申请对债务人进行重整。

（二）重整申请的受理

人民法院经审查认为重整申请符合法律规定的，应当裁定债务人重整，并予以公告。

（三）重整程序的效力

（1）在重整期间，经债务人申请，人民法院批准，债务人可以在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。已接管债务人财产和营业事务的管理人应当向债务人移交财产和营业事务，管理人的职权由债务人行使。

（2）破产管理人负责管理财产和营业事务的，可以聘任债务人的经营管理人员负责营业事务。

（3）在重整期间，对债务人的特定财产享有的担保权暂停行使。但是，担保物有损坏或者价值明显减少的可能，足以危害担保权人权利的，担保权人可以向人民法院请求恢复行使担保权。债务人或者管理人为继续营业而借款的，可以为该借款设定担保。

（4）债务人合法占有的他人财产，该财产的权利人在重整期间要求取回的，应当符合事先约定的条件。

（5）在重整期间，债务人的出资人不得请求投资收益分配。在重整期间，债务人的董事、监事、高级管理人员不得向第三人转让其持有的债务人的股权，但是，经人民法院同意的除外。

三、重整程序的终止

第一，在重整期间，有下列情形之一的，经破产管理人或者利害关系人请求，人民法院

应当裁定终止重整程序，并宣告债务人破产：

- （1）债务人的经营状况和财产状况继续恶化，缺乏挽救的可能性；
- （2）债务人有欺诈、恶意减少债务人财产或者其他显著不利于债权人的行为；
- （3）债务人的行为致使管理人无法执行职务。

第二，债务人或者破产管理人未按期提出重整计划草案的，人民法院应当裁定终止重整程序，并宣告债务人破产。

第三，重整计划草案未获得通过且未依照《企业破产法》第 87 条的规定获得批准，或者已通过的重整计划未获得批准的，人民法院应当裁定终止重整程序，并宣告债务人破产。

第四，债务人不能执行或者不执行重整计划的，人民法院经管理人或者利害关系人请求，应当裁定终止重整计划的执行，并宣告债务人破产。

四、重整计划的制定、表决与批准

重整计划，是指由重整人制定的，以维持债务人继续营业、谋求债务人复兴为目的，以清理债权债务关系为内容的多方协议。

（一）重整计划的制定

- 1.重整计划的提交期限：应当自人民法院裁定债务人重整之日起 6 个月内
- 2.制定和提交重整计划的主体只能是债务人或者破产管理人，向人民法院和债权人会议同时提交。
- 3.重整计划草案的内容

（二）重整计划的表决

我国《企业破产法》采强制性分组标准，将重整债权分为 4 个表决组。

（三）重整计划的批准

重整计划的批准是指法院对经过债权人会议表决通过的重整计划予以批准，从而赋予重整计划以法律效力的行为。

在破产重整程序中，法院还可以对重整计划进行强制批准。

五、重整计划的执行与效力

（一）重整计划的执行

我国《企业破产法》第 89 条也明确规定：重整计划由债务人负责执行；人民法院裁定批准重整计划后，已接管财产和营业事务的破产管理人应当向债务人移交财产和营业事务。

（二）重整计划的效力

经人民法院裁定批准的重整计划，对债务人和全体债权人均有约束力。债权人未依照《企

业破产法》的规定申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利；在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。

（三）法院裁定终止重整计划执行的后果

重整计划对债权债务关系做了调整，如果法院裁定终止重整计划执行，该调整则失去效力。但若重整计划已经部分执行，则法律应对债权人已受偿部分的效力做出规定。

（四）重整计划执行完毕免除债务人的清偿责任

《企业破产法》第 94 条明确规定：“按照重整计划减免的债务，自重整计划执行完毕时起，债务人不再承担清偿责任。”

第 4 节 破产和解制度

一、破产和解申请提出与审查

破产和解制度，是指破产程序开始后，经由债务人与债权人会议达成协议，就债务人延期清偿债务、减免债务等事项达成协议，以中止破产程序，挽救、复苏企业的法律制度。

（一）破产和解申请的提出

破产和解申请，是债务人向法院请求同债权人会议进行和解的意思表示。我国规定，债务人申请和解，应当提出和解协议草案。

（二）破产和解申请的审查

人民法院经审查认为和解申请符合该法规定的，应当裁定和解，予以公告，并召集债权人会议讨论和解协议草案。

二、和解协议的表决与效力

（一）和解协议的表决

我国《企业破产法》第 97 条对和解协议的议决采取了双重表决权的原则，即债权人会议通过和解协议的决议，由出席会议的有表决权的债权人过半数同意，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的 $\frac{2}{3}$ 以上。

（二）和解协议的效力

1. 债权人会议通过和解协议的，由人民法院裁定认可，终止和解程序，并予以公告。
2. 经人民法院裁定认可的和解协议，对债务人和全体和解债权人均有约束力。
3. 对于因债务人的欺诈或者其他违法行为而成立的和解协议，人民法院应当裁定无效，并宣告债务人破产。
4. 债务人不能执行或者不执行和解协议的，人民法院经和解债权人请求，应当裁定终止和解协议的执行，并宣告债务人破产。

5.人民法院受理破产申请后，债务人与全体债权人就债权、债务的处理自行达成协议的，可以请求人民法院裁定认可，并终结破产程序。对于按照和解协议减免的债务，自和解协议执行完毕时起，债务人不再承担清偿责任。

讲解归纳与举例

【名词解释题】破产和解

【参考答案】破产和解制度，是指破产程序开始后，经由债务人与债权人会议达成协议，就债务人延期清偿债务、减免债务等事项达成协议，以中止破产程序，挽救、复苏企业的法律制度。

第5节 破产清算制度

一、破产清算制度概述

（一）破产清算制度的概念

破产清算制度，是指当债务人不能清偿到期债务时，由法院根据债权人或债务人的申请，依法宣告债务人破产，并将其全部财产公平分配给全体债权人的法律制度。

与广义上的破产程序不同，破产清算程序特指清算型破产程序与狭义上的破产程序，而不包含破产重整与破产和解这两项预防性破产程序。

（二）破产重整、破产和解与破产清算的关系

进入破产程序后，破产和解程序优于破产清算程序，破产重整程序又优于破产和解程序；进入破产重整程序后，正在进行的破产和解程序或者破产清算程序应当中止；如果破产清算、和解、重整三种申请同时出现，人民法院应当优先受理破产重整申请；当重整失败或者和解不能时，最终还要通过破产清算程序清理债务。

具有以下区别：

第一，法律功能不同。

第二，申请人不同。破产重整程序申请人比较广泛，包括债务人、债权人和债务人的出资人。破产和解程序的申请人限于债务人。破产清算程序的申请人则为债权人与债务人。

第三，有担保权的债权的法律地位不同。

二、破产宣告的做出

破产宣告，是指受理破产案件的法院审查并宣告债务人破产，并使债务人进入破产清算程序的司法裁判行为。破产宣告即意味着直接进入破产清算程序或间接进入破产清算程序，使债务人不可挽回地走向破产清算，破产企业还将因此被注销。

我国《企业破产法》第108条规定：“破产宣告前，有下列情形之一的，人民法院应当

裁定终结破产程序，并予以公告：

（一）第三人为债务人提供足额担保或者为债务人清偿全部到期债务的；

（二）债务人已清偿全部到期债务的；

债务人被宣告破产后，债务人称为破产人，债务人财产称为破产财产，人民法院受理破产申请时对债务人享有的债权称为破产债权。

三、破产财产的变价

破产财产的变价，是指破产管理人将非货币的破产财产，通过合法方式加以出让，使之转化为货币形态，以便进行破产财产分配的过程。

（一）破产财产的变价方案

债权人会议通过破产财产变价方案，应当由出席会议有表决权的债权人的过半数通过，并且其所代表的债权额应当占无财产担保的债权额的 $\frac{1}{2}$ 以上。如果债权人会议未能通过破产财产变价方案，则由人民法院做出裁定。由债权人会议通过或者人民法院裁定的破产财产变价方案，由破产管理人执行。

（二）破产财产的变价方式

依我国《企业破产法》第 112 条的规定，破产财产的变价方式主要有以下三种：

（1）拍卖；

（2）对破产企业进行全部或者部分变价出售；

（3）依照国家规定不能拍卖或者限制转让的财产，应当依照国家规定的方式处理

四、破产财产的分配

破产财产的分配，是指基于债权人公平受偿的原则，将破产财产按各债权人的应受偿顺序和应受偿比例在债权人之间进行的清偿程序。

（一）破产财产的清偿顺序

我国《企业破产法》第 113 条规定，破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后，依照下列顺序清偿：

第一，破产人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金。

第二，破产人欠缴的除前述规定以外的社会保险费用和破产人所欠税款。第三，其他的普通债权。

（二）破产财产分配的方式

在我国司法实践中，破产财产的分配主要包括货币分配、实物分配与债权分配三种方式。

以货币分配方式为主，实物分配与债权分配主要适用于破产财产不易或不能变价转化为货币的情形，或者依债权人会议做出将破产财产直接分配于债权人的决议的情形。

（三）破产财产分配方案

破产财产分配方案应当载明的事项有：

- （1）参加破产财产分配的债权人名称或者姓名、住所；
- （2）参加破产财产分配的债权额；
- （3）可供分配的破产财产数额；
- （4）破产财产分配的顺序、比例及数额；
- （5）实施破产财产分配的方法。

（四）破产财产的分配

1.破产财产分配方案的执行

破产财产分配方案经人民法院裁定认可后，由破产管理人执行。

2.对附条件债权的分配

对于附生效条件或者解除条件的债权，管理人应当将其分配额提存。

3.对未受领的破产财产分配额的处理

债权人未受领的破产财产分配额，管理人应当提存。债权人自最后分配公告之日起满二个月仍不领取的，视为放弃受领分配的权利，管理人或者人民法院应当将提存的分配额分配给其他债权人。

4.对诉讼或者仲裁未决债权的处理

破产财产分配时，对于诉讼或者仲裁未决的债权，管理人应当将其分配额提存。自破产程序终结之日起满二年仍不能受领分配的，人民法院应当将提存的分配额分配给其他债权人。

五、破产程序的终结

根据我国《企业破产法》的规定，破产程序终结的原因主要有以下五种：

- 1.因财产不足以支付破产费用而终结
- 2.因全体债权人同意而终结
- 3.因出现破产宣告障碍而终结
- 4.因没有财产可供分配而终结
- 5.因破产财产分配完毕而终结

（二）破产程序终结的效力

1.对于破产人的效力

从法院对企业法人破产程序终结的裁定生效之日起，破产程序终结，其法人主体资格则在破产管理人依法办理注销登记后消灭，其所负债务也当然免除。

2.对于破产债权人的效力

由于破产终结后破产企业的主体资格消灭，债权人未得到分配的债权，于破产终结裁定做出后视为消灭。

3.对破产管理人的效力

企业法人依法登记成立的，企业法人破产也应当办理注销登记。

4.追加分配

我国《企业破产法》第 123 条对追加分配做了明确规定。

5.对破产人的保证人和其他连带债务人的效力

破产人的保证人和其他连带债务人，在破产程序终结后，对债权人依照破产清算程序未受清偿的债权，依法继续承担清偿责任。

讲解归纳与举例

【论述题】论述破产财产的清偿顺序

【答案】我国《企业破产法》第 113 条规定，破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后，依照下列顺序清偿：

第一，破产人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金。

第二，破产人欠缴的除前述规定以外的社会保险费用和破产人所欠税款。

第三，其他的普通债权。若破产财产不能满足同一顺序债权的清偿要求，则按照比例分配。